Supremo Tribunal Federal

AUDIÊNCIA PÚBLICA

DIREITO AO ESQUECIMENTO NA ESFERA CÍVEL

RE 1.010.606

RELATOR MINISTRO DIAS TOFFOLI

Sumário - Expositores

O SENHOR ROBERTO ALGRANTI FILHO (ADVOGADO DOS RECORRENTES) 23

O SENHOR GUSTAVO BINENBOJM (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO - ABERT) 34

A SENHORA TAÍS BORJA GASPARIAN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO) 44

O SENHOR DANIEL SARMENTO (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS - ANJ E ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS - ANER) 54

A SENHORA CÍNTIA ROSA PEREIRA DE LIMA (FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO) 63

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS COSTA NETTO (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO) 72

O PROFESSOR RENATO OPICE BLUM (INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA - INSPER) 87

PROFESSOR DOUTOR ANDERSON SCHREIBER (INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL - IBDCIVIL) 107

O SENHOR MARCEL LEONARDI (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) 118

O SENHOR GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA (INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS - IBCCRIM) 133

O SENHOR CARLOS AFFONSO PEREIRA DE SOUZA (INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO - ITS RIO) 145

O SENHOR ANDRÉ ZONARO GIACCHETTA (YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA) 157

O SENHOR CONSELHEIRO CORIOLANO AURÉLIO DE CAMARGO SANTOS (SECCIONAL DE SÃO PAULO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL) 166

O SENHOR PABLO DE CAMARGO CERDEIRA (CENTRO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DA ESCOLA DE DIREITO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS DO RIO DE JANEIRO) 170

O SENHOR ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (GRUPO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS) 181

A SENHORA MARIANA CUNHA E MELO DE ALMEIDA REGO (PROFESSORA E PESQUISADORA) 191

PRIMEIRA PARTE

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) – Bom dia a todos! Podemos nos assentar, por favor.

Bom dia a todos! Senhor Ministro Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli; Doutor Odim Brandão, Subprocurador-Geral da República; Senhores Expositores; Senhores Advogados, Jornalistas, convidados, em nome do Supremo Tribunal Federal, eu agradeço a presença de todos, em especial dos Senhores Expositores nesta Vigésima Segunda Audiência Pública sobre Aplicabilidade do Direito ao Esquecimento na Esfera Civil.

E eu, de pronto, agradeço, de uma forma muito especial, o relator do recurso extraordinário no qual se reconheceu a repercussão geral, Ministro Dias Toffoli, que convida a sociedade a vir trazer subsídios necessários para que todos os Ministros do Supremo tenham um melhor conhecimento e mais informações para o julgamento desta causa.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem realizado essas audiências exatamente no sentido de assegurar que os especialistas possam nos ajudar, com maior conhecimento, ter um julgamento mais justo sobre um tema tão sensível como este.

Eu vou pedir licença ao Ministro Dias Toffoli para não fazer referência a algum jurista, a algum especialista até da área técnica, mas, para fazer referência ao que se tem tratado na poesia, vou fazer aqui referência à obra do Carlos Drummond de Andrade, que tem o seu ápice em *Boitempo*, quando ele se refere a esquecer para lembrar. E tem-se exatamente, segundo as palavras poéticas que eu aqui não vou repetir, mas que, às vezes, se esquece para lembrar e, às vezes, lembra-se para esquecer. E é exatamente este um dos temas que tem permeado não apenas à esfera civil, objeto específico desta audiência, mas até mesmo em direitos outros fundamentais.

Hoje, Ministro Dias Toffoli, faz exatamente três dias que, num debate com os Coordenadores dos 27 Tribunais de Justiça, coordenadores do campo específico do Combate à Violência Doméstica, dizia que pedia ao Supremo Tribunal e ao Conselho Nacional de Justiça, mesmo, que nós discutíssemos a questão das audiências concentradas, porque, às vezes, a vítima, quer na área criminal, quer até em busca de medidas protetivas, no caso específico do Combate à Violência Doméstica, violência contra mulher e encontra as crianças, que ela não quer repetir 5, 6 vezes, em várias audiências, primeiro na polícia, depois perante o órgão do Ministério Público, e, depois, em várias ocasiões perante o Judiciário, que ela tenha que relembrar a cada tempo. Chega num momento que ela diz: "eu prefiro não ter mais nada; eu só não quero ter que me lembrar e contar isso de novo". Isto

tem sido uma constante. E o Direito tem hoje pedido que: quem não quiser se lembrar para ter o direito de esquecer tem esse direito, e que o Direito dê as condições para que cada um faça esse esquecimento.

E eu me propus, no Conselho Nacional de Justiça, a fazer um debate exatamente na questão específicas da violência contra mulher e encontra criança, porque, se nós não tivermos audiências concentradas, eu vou exigir, para poder aplicar o Direito, que a pessoa se lembre e conte várias vezes. E isso tem sido hoje um dos motivos pelos quais nós não conseguimos chegar ao final de um julgamento. Depois de um certo momento, a vítima ou a testemunha não comparece mais. E, aí, não se tem sequer a possibilidade de levar ao final um determinado julgamento.

Portanto, é preciso que o Direito se repente e o Poder Judiciário também.

Por isso, não apenas eu agradeço, mais uma vez, em nome do Supremo, a presença dos Senhores Expositores, mas agradeço, de uma forma especial, ao Ministro Dias Toffoli, que teve esta muito boa lembrança de trazer à Audiência Pública este tema que é tão peculiar.

Eu vou passar a palavra ao Senhor Ministro Dias Toffoli. Após o seu pronunciamento, eu vou pedir licença a todos para que eu possa me ausentar.

Quero que todos saibam que tudo que for, aqui, passado é gravado, registrado e entregue, pelo Ministro-Relator, aos dez outros Ministros, de tal forma que, no julgamento, todos nós teremos tido oportunidade de ouvir tudo que aqui foi dito e discutido. E, portanto, todos os onze Ministros têm acesso a esta audiência que não fica apenas neste registro momentâneo pela transmissão, mas ele é entregue a cada um dos Julgadores.

Muito obrigada, portanto, a todos! Passo a palavra ao eminente Ministro Dias Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Muito obrigado, Senhora Presidente, Ministra **Cármen Lúcia**, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A presença de Vossa Excelência muito honra e engrandece esta audiência pública. Agradeço penhoradamente a vinda de Vossa Excelência, com tantos compromissos que tem, para fazer a abertura e mostrar a importância e a dimensão deste tema para este Supremo Tribunal Federal. A presença de Vossa Excelência chancela a dimensão do caso que estamos, aqui, a debater.

Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral da República Dr. Odim Brandão, que nos acompanha ao longo desta sessão; Senhoras e Senhores Advogados; Senhoras e Senhores Expositores, Senhora Secretária, a audiência toda aqui presente, a imprensa.

A eminente Ministra **Cármen Lúcia** já fez a referência mais importante no sentido de as senhoras e senhores saberem que, mesmo que não estejamos os onze Ministros aqui, todo este material será encartado aos autos e será encaminhado a todos os eminentes integrantes da Corte antes de se pautar o tema para julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Então, saibam, senhoras e senhores, que, além de quem aqui passar, de quem estiver assistindo - muitas vezes, por exemplo, eu assisto, trabalhando no gabinete, à TV Justiça e acompanho a Audiência Pública da qual não sou relator, fazendo meus deveres, que são muitos no dia a dia do nosso trabalho, aqui, no Supremo Tribunal Federal, e acompanho também os debates, como aconteceu recentemente numa audiência pública a respeito do funcionamento das redes sociais, que ocorreu na semana passada, em casos de relatoria da Ministra **Rosa Weber** e do Ministro Luiz **Edson Fachin** -, tenham certeza, então, senhoras e senhores, ao longo do dia de hoje, vários dos Colegas estarão acompanhando na TV Justiça esta sessão, no circuito interno de televisão que temos, aqui, no Supremo Tribunal Federal, tal qual as assessorias dos gabinetes também acompanham. Enfim, toda a sociedade estará acompanhando este tema.

Senhora Presidente, eu gostaria de dizer que, seguindo o roteiro, vou fazer a leitura do relatório do caso específico, antes de dar a palavra aos eminentes expositores.

Trata-se de um caso que chega como uma causa concreta, mas, ao se dar repercussão geral ao tema, as senhoras e os senhores sabem que isso passa a ser algo que terá, com a decisão do Supremo, uma dimensão geral, indicando a todo o Judiciário qual é a orientação sobre o aspecto constitucional.

No caso específico:

> "Nelson Curi e outros insurgem-se contra acórdão prolatado pela Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
>
> > 'INDENIZATÓRIA. PROGRAMA 'LINHA DIRETA JUSTIÇA'. AUSÊNCIA DE DANO.
> >
> > Ação indenizatória objetivando a compensação pecuniária e a reparação material em razão do uso, não autorizado, da imagem da falecida irmã dos Autores, em programa denominado 'Linha Direta Justiça'.
> >
> > 1- Preliminar - o juiz não está obrigado a apreciar todas as questões desejadas pelas partes, se por uma delas, mais abrangente e adotada, as demais ficam prejudicadas.
> >
> > 2-A Constituição Federal garante a livre expressão da atividade de comunicação, independente de censura ou licença, franqueando a obrigação de indenizar apenas quando o uso da imagem ou informações é utilizada para denegrir ou atingir a honra da pessoa retratada, ou ainda, quando essa imagem/nome for utilizada para fins comerciais.
> >
> > Os fatos expostos no programa eram do conhecimento público e, no passado, foram amplamente divulgados pela imprensa. A matéria foi, é discutida e noticiada ao longo dos últimos cinquenta anos, inclusive, nos meios acadêmicos.
> >
> > A Ré cumpriu com sua função social de informar, alertar e abrir o debate sobre o controvertido caso. Os meios de comunicação também têm este dever, que se sobrepõe ao interesse individual de alguns, que querem e desejam esquecer o passado.
> >
> > O esquecimento não é o caminho salvador para tudo. Muitas vezes é necessário reviver o passado para que as

> novas gerações fiquem alertadas e repensem alguns procedimentos de conduta do presente.
>
> Também ninguém nega que a Ré seja uma pessoa jurídica cujo fim é o lucro. Ela precisa sobreviver porque gera riquezas, produz empregos e tudo mais que é notório no mundo capitalista. O que se pergunta é se o uso do nome, da imagem da falecida, ou a reprodução midiática dos acontecimentos, trouxe um aumento do seu lucro e isto me parece que não houve, ou se houve, não há dados nos autos.
>
> Recurso desprovido, por maioria, nos termos do voto do Desembargador Relator.'"

Essa é a ementa do acordo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

E, por falar em esquecimento, esqueci de citar o número do recurso extraordinário. Faço-o agora. Depois, retomarei a leitura do relatório. Estamos a debater, nesta audiência pública, a repercussão geral dada pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.010.606/RJ, sendo recorrentes Nelson Curi, Roberto Curi, Waldir Curi, Maurício Curi; recorrida a Globo Comunicação e Participações S/A; e *amica curiae* a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI).

Retorno, já com a lembrança do pregão do caso, à leitura do relatório. Então, após a leitura da ementa, eu digo que foram:

> "Opostos dois embargos declaratórios pelos autores, ora recorrentes, nenhum deles foi acolhido, tendo, no último deles, sido imposta multa de 1% sobre o valor da causa.
>
> Em face do referido acórdão estadual foram aviados recursos especial e extraordinário, aos quais, em sede de juízo prévio

de admissibilidade, negou-se seguimento. Foram, então, interpostos agravos no intuito de destrancar os reclamos, que subiram às Cortes Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo e, na sequência desproveu o especial, em síntese, sob a seguinte fundamentação [leio a síntese da fundamentação do julgado no recurso especial no Superior Tribunal de Justiça]:

> 'RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA VS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LITÍGIO DE SOLUÇÃO TRANSVERSAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM REDE NACIONAL. LINHA DIRETA-JUSTIÇA. HOMICÍDIO DE REPERCUSSÃO NACIONAL OCORRIDO NO ANO DE 1958. CASO "AIDA CURI". VEICULAÇÃO, MEIO SÉCULO DEPOIS DO FATO, DO NOME E IMAGEM DA VÍTIMA. NÃO CONSENTIMENTO DOS FAMILIARES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. ACOLHIMENTO. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO DA HISTORICIDADE DO FATO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO NOME DA VÍTIMA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. SÚMULA N. 403/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
>
> 1. Avulta a responsabilidade do Superior Tribunal de Justiça em demandas cuja solução é transversal, interdisciplinar, e que abrange, necessariamente, uma controvérsia constitucional oblíqua, antecedente, ou inerente apenas à fundamentação do acolhimento ou rejeição de ponto situado no âmbito do contencioso infraconstitucional, questões essas que, em princípio, não são apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal.
>
> 2. Nos presentes autos, o cerne da controvérsia passa pela ausência de contemporaneidade da notícia de fatos passados, a qual, segundo o entendimento dos autores, reabriu antigas feridas já superadas quanto à morte de sua irmã, Aida Curi, no distante ano de 1958. Buscam a proclamação do seu direito ao esquecimento, de não ter revivida, contra a vontade deles, a dor antes experimentada por ocasião da morte de Aida

Curi, assim também pela publicidade conferida ao caso décadas passadas.

3. Assim como os condenados que cumpriram pena e os absolvidos que se envolveram em processo-crime (REsp. n. 1.334/097/RJ), as vítimas de crimes e seus familiares têm direito ao esquecimento – se assim desejarem –, direito esse consistente em não se submeterem a desnecessárias lembranças de fatos passados que lhes causaram, por si, inesquecíveis feridas. Caso contrário, chegar-se-ia à antipática e desumana solução de reconhecer esse direito ao ofensor (que está relacionado com sua ressocialização) e retirá-lo dos ofendidos, permitindo que os canais de informação se enriqueçam mediante a indefinida exploração das desgraças privadas pelas quais passaram.

4. Não obstante isso, assim como o direito ao esquecimento do ofensor – condenado e já penalizado – deve ser ponderado pela questão da historicidade do fato narrado, assim também o direito dos ofendidos deve observar esse mesmo parâmetro. Em um crime de repercussão nacional, a vítima – por torpeza do destino – frequentemente se torna elemento indissociável do delito, circunstância que, na generalidade das vezes, inviabiliza a narrativa do crime caso se pretenda omitir a figura do ofendido.

5. Com efeito, o direito ao esquecimento que ora se reconhece para todos, ofensor e ofendidos, não alcança o caso dos autos, em que se reviveu, décadas depois do crime, acontecimento que entrou para o domínio público, de modo que se tornaria impraticável a atividade da imprensa para o desiderato de retratar o caso Aida Curi, sem Aida Curi.

6. É evidente ser possível, caso a caso, a ponderação acerca de como o crime tornou-se histórico, podendo o julgador reconhecer que, desde sempre, o que houve foi uma exacerbada exploração midiática, e permitir novamente essa exploração significaria conformar-se com um segundo abuso só porque o primeiro já ocorrera. Porém, no caso em exame, não ficou reconhecida essa artificiosidade ou o abuso antecedente na cobertura do crime, inserindo-se, portanto, nas exceções decorrentes da ampla publicidade a que podem se sujeitar alguns delitos.

7. Não fosse por isso, o reconhecimento, em tese, de um direito de esquecimento não conduz necessariamente ao dever de indenizar. Em matéria de responsabilidade civil, a

> violação de direitos encontra-se na seara da ilicitude, cuja existência não dispensa também a ocorrência de dano, com nexo causal, para chegar-se, finalmente, ao dever de indenizar. No caso de familiares de vítimas de crimes passados, que só querem esquecer a dor pela qual passaram em determinado momento da vida, há uma infeliz constatação: na medida em que o tempo passa e vai se adquirindo um 'direito ao esquecimento', na contramão, a dor vai diminuindo, de modo que, relembrar o fato trágico da vida, a depender do tempo transcorrido, embora possa gerar desconforto, não causa o mesmo abalo de antes.
>
> 8. A reportagem contra a qual se insurgiram os autores foi ao ar 50 (cinquenta) anos depois da morte de Aida Curi, circunstância da qual se conclui não ter havido abalo moral apto a gerar responsabilidade civil. Nesse particular, fazendo-se a indispensável ponderação de valores, o acolhimento do direito ao esquecimento, no caso, com a consequente indenização, consubstancia desproporcional corte à liberdade de imprensa, se comparado ao desconforto gerado pela lembrança.
>
> 9. Por outro lado, mostra-se inaplicável, no caso concreto, a Súmula n. 403/STJ. As instâncias ordinárias reconheceram que a imagem da falecida não foi utilizada de forma degradante ou desrespeitosa. Ademais, segundo a moldura fática traçada nas instâncias ordinárias – assim também ao que alegam os próprios recorrentes –, não se vislumbra o uso comercial indevido da imagem da falecida, com os contornos que tem dado a jurisprudência para franquear a via da indenização.
>
> 10. Recurso especial não provido'."

Em síntese, Senhora Presidente, verificamos que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade do direito ao esquecimento, mas, ponderando o caso concreto, entendeu por sua inaplicabilidade.

> "Diante da negativa do STJ, vieram os autos ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que tenha lugar a apreciação do apelo extremo, aviado com fulcro na alínea a do permissivo e fundado na

pretensa afronta aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e incisos III e X e 220, § 1º[,] da Constituição da República.

Esclareço, antes de mais nada, que a presente lide teve início com o ajuizamento de ação ordinária por meio da qual os autores, ora recorrentes, pretendem obter a reparação de supostos danos morais e materiais decorrentes da exibição, por parte da recorrida, do programa televisivo 'Linha Direta', especificamente pela veiculação de episódio que teve por objeto o assassinato de Aída Curi, bem como seus desdobramentos, as respectivas investigações policiais e a apreciação do caso levada a cabo pelo Poder Judiciário. O cerne da exordial são o direito ao esquecimento, a proteção à dignidade da pessoa humana e o resguardo da inviolabilidade da personalidade, dos direitos à imagem, à honra, à vida privada e à intimidade frente aos órgãos de mídia e de imprensa, a liberdade de expressão, o direito à informação e o interesse público.

Registro, porque pertinente, que, em primeira instância, a demanda foi julgada improcedente *in totum*. Houve apelação, sendo mantida pelo Tribunal a quo, nos termos delineados na ementa acima transcrita, a convicção exarada pelo juízo singular. Dito isso, passo às razões de recurso extraordinário.

De início, narram os recorrentes que sua irmã, Aida Curi, foi brutalmente estuprada, violentada e morta no ano de 1958, tendo a família sofrido intenso massacre dos órgãos de imprensa à época, em razão da cobertura ferrenha de cada passo das investigações e do processo criminal subsequente. Aferem que não obstante a dor provocada pelo crime em si, foram literalmente perseguidos pela imprensa por toda a década que se seguiu, ficando toda a família da vítima cruelmente estigmatizada.

Ocorre que, passados mais de 50 (cinquenta) anos, com a dor e o sofrimento já muito amenizados, a recorrida teria veiculado em rede nacional programa televisivo não só explorando a história de Aida Curi, como também utilizando a imagem real dela e dos recorrentes, a despeito da notificação enviada previamente por estes últimos, na qual opunham-se à veiculação do caso.

Relatam que:

> 'fez-se uma verdadeira obra cinematográfica sobre a família dos recorrentes e sobre o evento lutoso, baseado num 'roteiro marrom' elaborado para atrair audiência popular mediante o uso de cenas impactantes de extrema violência retratando minúcias do estupro de Aida

> Curi e mostrando ela ser arremessada viva de um alto edifício em Copacabana, Rio de Janeiro.' (folha 995)

Isso posto, afirmam que lutam pelo reconhecimento do seu direito de esquecer tal tragédia, amparando-se, para tanto, no direito ao esquecimento, instituto já reconhecido e defendido pela Suprema Corte Alemã, bem como e doutrinas e julgamentos isolados no Brasil.

Assentam ainda que, ante o julgamento da ADPF 130, faz-se inadiável a manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, de modo a fornecer contornos mais nítidos e precisos à 'mensagem à nação' oriunda dos votos proferidos naquele julgamento, analisando-se, a par disso, uma vertente da proteção da dignidade da pessoa humana ainda não apreciada por esta Corte, sobretudo porque vista, agora, da perspectiva da vítima.

Sustentam os recorrentes que tanto a sentença, como o acórdão da apelação conferem retorcida e errônea interpretação à garantia da liberdade de expressão, utilizando-a como 'verdadeira carta de alforria genérica e absoluta em favor do órgão de mídia recorrido'(folha 1.003), o qual, a tomar-se por parâmetro o decidido nos julgados, encontrar-se-ia imune às consequências de seus atos, mesmo quando ilicitamente prejudiciais a terceiros e configuradores do exercício abusivo do direito de se expressar livremente. Adotar tal entendimento, tergiversa, implicaria conferir à liberdade de expressão caráter absoluto e sobrelevá-la às garantias individuais, a despeito das limitações previstas no artigo 220, caput e parágrafo 1º da Carta da República.

A liberdade de expressão, sustentam, não é absoluta, devendo respeito às garantias inerentes à personalidade, afigurando-se cabível, inclusive, indenização em caso de violação das mesmas. Tal seria, aduzem, a conclusão tirada a partir do decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 130, ocasião na qual,

> '[n]os históricos votos proferidos em seu julgamento, se por um lado os preclaros Ministros asseveraram a enorme relevância da liberdade de expressão para a democracia, e a impossibilidade de haver censura prévia, por outro, todos se preocuparam em firmar o devido contrapeso, ou seja, em deixar muito claro que tal liberdade não poderia excluir o direito de se acessar a justiça para fins indenizatórios por quem se considerar prejudicado pelo exercício daquela garantia.

> Ratificou-se o entendimento, então, que o certo é compatibilizar as garantias individuais com a da liberdade de expressão, e não permitir que a última subjugue as primeiras.' (folha 1.004)

Em seguida, os recorrentes passam a discorrer acerca dos requisitos necessários à caracterização da atividade de imprensa, ressaltando que, para que possa ser qualificada como jornalística uma determinada atividade, *'seu conteúdo deve preencher, impreterivelmente, o requisito da contemporaneidade, sem o qual não se configura o interesse social justificador da (relativa) imunização do exercício da liberdade de expressão.'* (folha 1.006)

Ausente tal requisito, a atividade em questão ostentará cunho inquestionavelmente comercial, ensejando a reparação, vez que ausentes, nas palavras da Desembargadora autora do voto vencido, Dra. Jacqueline L. Montenegro, a sobriedade do noticiário, a novidade, a capacidade real de interferir na forma de pensar ou de enxerga o ocorrido pela sociedade.

A respeito, assinalam os autores que o simples fato de algo ser de conhecimento público e notório não incinera os direitos personalíssimos dos envolvidos – entender de forma contrária conduziria à autorização do locupletamento, sem que o ofendido tivesse direito a buscar o ressarcimento correspondente. Acentuam, adicionalmente, que o fato de terem sido vítimas de violência no passado não os torna menos dignos de proteção legal no momento presente – e que anuir com tal forma desigual de tratamento fere concomitantemente as garantias da dignidade da pessoa humana e da isonomia. A notoriedade, em suma, não possuiria o condão de livrar a recorrida do seu dever de respeitar o patrimônio dos recorrentes, ressarcindo-os pela utilização ilegal do mesmo. Eventual interesse público – o qual, *in casu*, seria inexistente – não justifica exploração comercial do patrimônio personalíssimo.

No tocante ao direito ao esquecimento, articulam que mesmo uma rápida lembrança do drama vivido em tempos outros não passa impune, causando sempre profunda dor e um sentimento de perda irreparável. Mencionam o julgamento favorável ao autor no 'caso Lebach'- em que um criminoso que havia cumprido a pena pedia uma liminar para impedir a transmissão televisiva de um documentário sobre o seu crime -, julgado pelo Tribunal Constitucional Alemão e adotado pelo Ministro Gilmar Mendes em suas razões de decidir na ADPF n.º 130.

Reiteram, aqui, argumento levantado naquela ocasião: na averiguação do conflito entre liberdade de expressão e garantias individuais, deve-se invocar o princípio da proporcionalidade e exigir que a matéria a ser divulgada seja atual para poder sobrepor-se ao direito individual. Argumentam que tal orientação tem sido acolhida por diversos doutrinadores e tribunais em todo o mundo e que inclusive o próprio TJRJ conta com precedente no qual se acolheu a tese do direito ao esquecimento. Acrescentam, ademais que:

> 'se o criminoso tem o direito ao esquecimento, impõe-se reconhecê-lo à vítima estigmatizada por um crime que, por dolorosos anos, foi carnivoramente dissecado e explorado pela imprensa (que já lucrou muito com o evento lutoso), sempre pairando nos olhares desviados do meio social dos recorrentes.'(folha 1.012)

Concluem tal capítulo dizendo que *'tudo se resume no respeito à moral, ao nome, à imagem e à dignidade humana dos apelantes, respeito este fulminado pelo despotismo da apelada'*.

Por último, os recorrentes tecem considerações acerca da alegada ilegalidade do programa televisivo e do consequente direito à indenização por danos materiais.

Aduzem que a jurisprudência possui firme posicionamento no sentido de que o uso indevido de imagem gera o direito à indenização de seu titular e que sendo incontroversa a utilização ilegal da imagem de Aída Curi, de rigor concluir-se pelo direito de sua família a ser indenizada pelos lucros obtidos mediante tal violação - violação esta a qual ocorreria, inclusive, em caso de representação da pessoa por atores sem a devida autorização. Defendem que afastar referido direito à reparação significa permitir a afronta à vida privada, à intimidade, à honra, à imagem e à dignidade humana.

Sustentam os recorrentes que, mesmo que o programa ostentasse efetivamente cunho jornalístico, ainda assim possuiriam direito ao ressarcimento pleiteado, porquanto aquele teria sido conduzido de maneira deveras desrespeitosa e abusiva, *'indo muito além da invasão de sua privacidade e da exploração da trágica história pessoal de cada um deles.'* (folha 1.017)

Com base em toda essa argumentação, requerem, ao cabo seja provido o presente recurso extraordinário, *'reconhecendo-se que o v. acórdão combatido (proferido em sede de apelação) contrariou os artigos 1º, III, 5º, caput, III e X; 220, § 1º, in fine, todos da Constituição Federal,*

julgando-se procedentes todos os pedidos elencados na petição inicial, inclusive, mas não só, com de arbitramento de indenização por dano moral e de condenação da recorrida a pagar aos recorrentes indenização no valor fixado no laudo pericial contábil, sem prejuízo da indenização pelo uso da imagem, nome e história dos recorrentes, mesmo se a exploração destes atributos da personalidade tiver ocorrido depois da sentença, até o trânsito em julgado.'(folha 1.019)

Em contrarrazões, a recorrida, Globo Comunicação e Participações S/A, suscita preliminarmente (i) a ausência de repercussão geral; (ii) a impossibilidade de revisão de fatos e provas e consequente incidência da Súmula n.º 279 do STF; (iii) a ausência de prequestionamento dos artigos 1º, inciso III e 5º, caput e inciso III da Carta Maior; (iv) a inocorrência de violação frontal a dispositivo da Constituição da República no que pertine ao direito ao esquecimento; (v) a deficiência de fundamentação no tocante à suposta violação ao artigo 5º, caput e inciso III do texto constitucional; (vi) a aplicabilidade, in casu, da Súmula n.º 284/STF.

A respeito do programa 'Linha Direta', esclarece a recorrida que:

> 'só exibia matérias sobre casos já conhecidos do público, fartamente noticiados e discutidos pela sociedade. O programa não tinha por objetivo invadir a vida privada e a intimidade e quem quer que seja. Muito pelo contrário, seu conteúdo se limitava à abordagem de fatos já públicos e históricos, todos relacionados a crimes notórios e aos respectivos julgamentos dos acusados. '(folha 1.106)

E que:

> '[n]a hipótese dos autos, grande parte do programa foi composta de informações e imagens de arquivos, constantes de matérias jornalísticas da época e de obras posteriormente publicadas sobre o caso, inclusive livros, como os que foram escritos pelo quarto recorrente, 'Aída Curi, A Jovem Heroína de Copacabana' e 'Aída Curi: O Preço Foi a Própria Vida.'(folha 1.108)

Argumenta que em razão do caráter brutal e rumoroso do crime, o caso até hoje é amplamente discutido no país, vez que envolve questões as quais integram a realidade e o universo de interesses de toda a coletividade, tais como a violência contra as

mulheres, a impunidade e a responsabilidade penal de menores. Alega, nesse sentido, que os fatos relacionados ao assassinato de Aída Curi são de interesse geral da coletividade, sendo um direito de todos o acesso à história, a fim de que seja conhecida e lembrada, possibilitando-se, assim, sua melhor compreensão, bem como sua não repetição.

Sustenta a recorrida que os direitos à intimidade e à imagem não se sobrepõem ao interesse coletivo de sociedade de ter acesso às informações sobre o fato histórico e que, além disso, a Lei Maior consagra a plena liberdade de expressão – o que exsurgiria, de forma clara, de seus artigos 5º, incisos IV, IX, XIV e 220, §§ 1º e 2º.

Tergiversa, ainda, que o artigo 188, inciso I do Código Civil afasta a possibilidade de se enquadrar como ilícito ato praticado no regular exercício da atividade jornalística e que, na hipótese, divulgou única e exclusivamente fatos verdadeiros e de interesse público, não necessitando de autorização expressa dos recorrentes para a exibição do programa.

Afirma que ao caso concreto aplica-se o princípio da proporcionalidade, pelo qual, caracterizado o conflito entre direitos personalíssimos e a liberdade de imprensa, deverá prevalecer esta última sempre que os fatos forem de interesse geral e possuírem relevância social, tais como aqueles que ensejaram a presente ação.

No referente ao requisito da atualidade da notícia, pondera que:

> '[a] atividade jornalística, evidentemente, engloba não só a busca de notícias atuais, como também, a divulgação de fatos passados de interesse da coletividade, ainda mais quando tratam de temas que ainda suscitam debates na sociedade, exatamente a hipótese do documentário objeto da lide.'(folha 1.112)

Quanto ao direito ao esquecimento, aduz a recorrida que o mesmo não encontra respaldo constitucional, nem mesmo como reflexo do genérico princípio da dignidade humana, sendo, ademais, completamente incompatível com a plena liberdade de informação assegurada pela Constituição Federal.

Assegura que em outros países, sua aplicação dá-se de maneira excepcional, visando, em regra, possibilitar a reintegração social de criminosos, sobretudo depois de cumpridas suas penas – hipótese a qual em nada se adequa àquela delineada neste processo, vez que o objetivo é unicamente proteger a vida futura de uma pessoa

de graves ameaças de violência, perseguição e preconceito decorrentes de atos passados pelos quais, teoricamente, já pagou e se recuperou.

Defende a recorrida, adicionalmente, que nada há no programa objeto da lide capaz de causar dano moral aos recorrentes. Nesse ponto, alega, não seria possível sentirem-se estes últimos atingidos por aquele, vez que o episódio foi narrado tal como aconteceu, nada sendo exibido de ofensivo à memória de Aída Curi ou a sua família.

A indenização por dano moral, por sua vez, restaria excluída, dado que, ainda que difícil a lembrança, a dor vivenciada é permanente, não sendo causada ou agravada pelo fato de o crime ser reproduzido em rede de televisão. Acrescenta ao longo do tempo o caso em tela foi recorrentemente citado na imprensa e nos meios de comunicação, tendo inspirado até mesmo livros – inclusive de autoria de um dos recorrentes - e que, por sua importância, continuará a ser lembrado, consistindo, pois, em uma realidade com a qual os recorrentes têm de conviver e que não é apta a gerar dano moral.

No que toca ao dano material, a recorrida aponta ser inexistente. Isso porque os recorrentes, em sua visão, não perderam ou deixaram de ganhar algo com a exibição do programa – e mesmo que tivessem sofrido o alegado dano, este não ostentaria qualquer relação com o eventual lucro auferido pela TV Globo, razão pela qual tal critério afigura-se descabido para o arbitramento de hipotética indenização.

A recorrida anexa ainda aos autos parecer da lavra do ilustre jurista Daniel Sarmento, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no qual o jurisconsulto corrobora as ilações trazidas nas contrarrazões recursais e adiciona outras.

A parte ré requer, ao fim, o não conhecimento do recurso ou, na eventualidade de assim não se entender, o desprovimento do extraordinário.

Após atenta análise dos autos, convencido de que a questão posta em discussão nesta lide apresenta densidade constitucional e extrapola os interesses subjetivos das partes, reconheci a repercussão geral da matéria. Em sessão realizada por meio eletrônico, o Plenário confirmou esse entendimento, tendo a ementa sido redigida nos seguintes termos:

'DIREITO CONSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA TELEVISIVO QUE ABORDA CRIME

OCORRIDO HÁ VÁRIAS DÉCADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR FAMILIARES DA VÍTIMA. ALEGADOS DANOS MORAIS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. DEBATE ACERCA DA HARMONIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DO DIREITO À INFORMAÇÃO COM AQUELES QUE PROTEGEM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A INVIOLABILIDADE DA HONRA E DA INTIMIDADE. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.'

O assunto foi inscrito como Tema nº 786 da Gestão da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte descrição: aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares.

Ante a confirmação da transcendência do assunto por parte do Tribunal Pleno, dei provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário e determinei a abertura de vista ao Ministério Público, para fins de elaboração de parecer, tendo os autos do ARE nº 833.248-RJ (originário) sido reautuado como o presente RE nº 1.010.606.

É o relatório."

Ainda quanto ao relatório e tendo aqui a presença do Dr. Odim Brandão, o parecer do Ministério Público é assinado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, e tem a seguinte ementa:

"CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 786. DIREITO A ESQUECIMENTO. APLICABILIDADE NA ESFERA CIVIL QUANDO INVOCADO PELA VÍTIMA OU POR SEUS FAMILIARES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA TELEVISIVO. VEICULAÇÃO DE FATOS RELACIONADOS À MORTE DA IRMÃ DOS RECORRENTES NOS ANOS 1950.

1. Tese de Repercussão Geral – Tema 786: Não é possível, com base no denominado direito a esquecimento, ainda não

reconhecido ou demarcado no âmbito civil por norma alguma do ordenamento jurídico brasileiro, limitar o direito fundamental à liberdade de expressão por censura ou exigência de autorização prévia. Tampouco existe direito subjetivo a indenização pela só lembrança de fatos pretéritos.

2. Há vasta gama variáveis envolvidas com a aplicabilidade do direito a esquecimento, a demonstrar que dificilmente caberia disciplina jurisprudencial desse tema. É próprio de litígios individuais envolver peculiaridades do caso, e, para reconhecimento desse direito, cada situação precisa ser examinada especificamente, com pouco espaço para transcendência dos efeitos da coisa julgada, mesmo em processo de repercussão geral.

3. Consectário do direito a esquecimento é a vedação de acesso à informação não só por parte da sociedade em geral, mas também de estudiosos como sociólogos, historiadores e cientistas políticos. Impedir circulação e divulgação de informações elimina a possibilidade de que esses atores sociais tenham acesso a fatos que permitam à sociedade conhecer seu passado, revisitá-lo e sobre ele refletir.

4. É cabível acolher pretensão indenizatória quando divulgação de informação de terceiro resulte em violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem (art. 5º, X, da Constituição da República), sendo dispensável para tal finalidade reconhecimento de suposto direito a esquecimento.

5. É inviável acolher pretensão indenizatória, quando o acórdão recorrido conclui, com base no conjunto fático-probatório, por inocorrência de violação a direitos fundamentais devido a veiculação, por emissora de televisão, de fatos relacionados à morte da irmã dos recorrentes, nos anos 1950.

6. Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário."

Diante da dimensão do tema, determinei, por despacho, a realização desta audiência pública.

Mais uma vez, agradecendo a presença de todos os expositores - penso, Senhora Presidente, que já falei demais -, passo a palavra a Vossa Excelência.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Eu agradeço, mais uma vez, ao Ministro Dias Toffoli, ao Senhor Subprocurador, Doutor Odim, e especialmente aos Expositores, que se deslocam para fazer com que este Supremo Tribunal Federal possa ter os subsídios necessários para um julgamento mais justo, mais adequado, não apenas para as partes, mas, neste caso, reconhecida a repercussão geral, para toda a sociedade brasileira.

Muito obrigada a todos!

Eu peço licença, Senhor Vice-Presidente, para que eu me ausente em razão de outros compromissos. Desejo uma excelente audiência!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Excuso-me pela extensão do relatório, mas penso que era importante delimitar, trazendo todos os argumentos envolvidos, para que tenhamos, então, a partir dessa delimitação, a dimensão exata do caso concreto. Como todos podem perceber, evidentemente, ele tem uma repercussão bastante grande para todos.

Eu vou, agora, seguir aqui pelo cerimonial. Abertos os trabalhos desta audiência pública, já delimitado seu objeto, lido este relatório, eu pergunto ao Subprocurador-Geral Dr. Odim Brandão se prefere falar agora ou mais adiante?

O SENHOR ODIM BRANDÃO (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Eu agradeço a gentileza da licença, mas pediria que me fosse reservada a palavra apenas ao final.

Muito obrigado!

SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço ao Dr. Odim! A primeira inscrita, a Senhora Ministra Advogada-Geral da União Dra. Grace Mendonça não poderá estar presente, tendo justificado sua ausência.

Vamos, então, iniciar com os eminentes expositores, a quem, mais uma vez, renovo os agradecimentos desta Corte e deste relator.

E, para a primeira manifestação, convido o representante dos recorrentes do recurso extraordinário, Dr. Roberto Algranti Filho, Bacharel em Direito e especializado em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Dispõe Vossa Senhoria de quinze minutos para sua manifestação.

O SENHOR ROBERTO ALGRANTI FILHO (ADVOGADO DOS RECORRENTES) - Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, a quem agradeço a oportunidade não só de estar aqui, mas do próprio debate, que, independentemente do caso concreto, terá uma validade incrível para enriquecer o conhecimento de todos a respeito de um tema tão sensível e tão relevante, eminente Subprocurador, caros expositores e demais presentes, meu bom-dia!

Eu vou evitar ao máximo falar do caso concreto. Acho que essa não é oportunidade para isso. Vou falar só das questões técnicas. E, dada a

exiguidade do tempo, é absolutamente impossível e inviável se aprofundar em tudo o que caberia dizer neste momento.

Tentarei chegar, o mais rápido possível, ao tema específico, que é o direito a esquecimento da vítima, e, dentro desse tema específico, buscar um elemento que tenho visto faltar no debate - acredito que, se não for o mais relevante, talvez seja um dos mais relevantes -, é a questão da saúde de quem é atingido por determinada veiculação, por determinada divulgação. Saúde, o dano à saúde que isso pode eventualmente causar. Como certamente várias pessoas vão falar sobre o direito ao esquecimento, em gênero, em espécie, vou tentar chegar mais rápido possível a essa questão.

Quanto ao direito a esquecimento, como disse Vossa Excelência, ao relatar, ele, segundo os recorrentes, encontra abrigo em diversos dispositivos constitucionais, assim como, a meu ver, em diversos julgados do Supremo Tribunal Federal.

Faço menção, por rápida amostragem, ao *habeas corpus* relacionado ao livro de conteúdo nazista, no qual, com todas as letras, deixou-se muito claro o que, de certa forma, é obvio. Mas é sempre bom deixar claro, que o direito subjetivo à liberdade de expressão encontra seu limite na ilicitude. Em relação a isso é que vou tentar chegar o mais breve possível à questão da saúde.

Faço, ainda, menção ao caso em que se garantiu o direito à felicidade, o direito à autoestima, os quais também são temas muito próprios para essa questão.

Faço menção, também, de que - até para deixar isso mais evidente - o tema não é novo. O tema é antigo, pelo menos na jurisprudência internacional, havendo já julgamentos desde 1931, em que, muito embora não se tenha utilizado a expressão "direito ao esquecimento", fala sobre o direito ao esquecimento. Há um caso do Tribunal, da Corte de Apelação da Califórnia, que é muito exemplar em relação a isso, de uma ex-prostituta que acusada de crimes, que depois se ressocializar, de mudar a sua vida, mudar o seu domicílio, deparou-se com um documentário e teve reconhecido o seu direito à não veiculação, tal como nós desejamos. Existe o caso que Vossa Excelência mencionou, o "caso Lebach", de 1969, já faz algum tempo, em que se pode ter um paralelo com o nosso, porque, em primeira instância, também foi negado. Teve que se chegar ao Tribunal Constitucional alemão para o criminoso, já depois de cumprir sua pena e querendo a sua ressocialização, ter o seu direito a obstar essa veiculação. Recentemente, houve casos na França e na Itália. Em janeiro desse ano, um caso muito interessante no Canadá, sobre o uso abusivo de informações pessoais de jurisdicionados canadenses, muito interessante - não temos tempo para nos aprofundar em relação

a isso. E o emblemático, pela atualidade do caso, o "Google Spain", que também teve muita repercussão.

Diante disso tudo, é importante agregar também o elemento da atualidade, da nossa realidade, em que, nessa sociedade de informação, as informações circulam com uma velocidade impressionante. Sem nenhum exagero, é possível que uma informação degradante sobre uma pessoa, sobre a qual possa vir a ser reconhecido o direito ao esquecimento, seja circulada na rede social às 8h; às 9h, sua cidade conhece; às 10h, o estado; e, ao final do dia, sabe-se lá, o mundo. É uma questão que torna o assunto direito ao esquecimento mais importante, mais importante até porque, a meu ver, não existe na legislação ordinária - temos que procurar realmente, na Constituição Federal, o abrigo - nenhum instrumento capaz de gerenciar, de instrumentalizar essa proteção ao direito subjetivo à privacidade, mais ainda, à intimidade, e mais ainda, como vou dizer, à saúde, à preservação da saúde.

É muito importante se levar em consideração essa nova realidade. E é muito importante se considerar que a legislação não tem remédios para isso. O direito de resposta não tem nenhuma aplicação ao caso, até porque quem não quer veicular determinada informação não vai dar resposta sobre a informação. Responsabilidade civil é uma consequência, não é um remédio; também não nos ajuda a tratar do assunto.

Existem algumas autorregulações, algumas questões infraconstitucionais que poderiam, em tese, ajudar, até mesmo se falando em questão de ética do jornalismo. O próprio Código de Ética Jornalista veda a veiculação de informação mórbida, manda preservar a privacidade dos fatos, mas os fatos mostram que não é bem isso que acontece.

Em relação ao direito ao esquecimento da vítima, que é o nosso caso específico - e aqui o tempo já urge -, ele tem algumas especificidades muito importantes, muito relevantes.

Sabemos - e isso de forma alguma se questiona - que o direito ao esquecimento não abarca fatos históricos. Compreendamos fatos históricos como aqueles que, de fato, são relevantes para a memória nacional. Faço um parêntesis rápido e sem nenhuma ironia: Aída Curi não é Getúlio Vargas - fecho parêntesis.

Então, não tenho nenhum receio de que o direito ao esquecimento vai interferir na questão histórica. Tenho certeza de que não vai interferir, também, por ser um requisito da sua configuração, nas notícias relevantes, atuais, de interesse público - não interesse do público, mas de interesse público -, nas informações que, de certa forma - e temos visto isso amiúde -, nos dias atuais, sirvam de controle das atividades políticas, de esclarecimento. Não tenho receio de que vá obstaculizar nada disso. Porém, feita essa ressalva, em relação à vítima, ela tem uma peculiaridade importante. É que ela não renunciou a

sua privacidade, nem em maior, nem em menor grau. Ela não renunciou a sua privacidade. Ela é uma vítima do crime, é uma vítima do destino e, até hoje, é uma vítima da imprensa, das mídias, por enquanto em caráter perpétuo. Entretanto, ela não abre mão da sua privacidade. Isso é muito diferente de várias outras circunstâncias em que a pessoa se dá ao público - a pessoa é um artista, um político -, e, em maior ou menor grau, abre mão da sua privacidade. Então, a vítima não abre. Isso é muito importante ficar claro em relação ao tema específico dessa audiência.

Em relação à vítima, aí finalmente consigo chegar ao tema que eu gostaria de focar, até porque não há tempo para muitos outros: a questão da saúde. Eu vejo muito pouco em doutrinas, nas peças dos outros processos, em decisões que se fale do tema saúde.

Falando-se em direito ao esquecimento, *lato sensu*, ou, nesse caso, da vítima, como não falar da saúde? E existe uma doença chamada estresse pós-traumático, que atualmente a literatura médica tem começado a se debruçar sobre isso, mas que, nesse caso, é de muita relevância, muita relevância! E para que isso não pareça retórico - de retórico não tem nada -, eu vou pedir vênia para ler rapidamente um trecho sobre o parecer, eu tiro isso da Revista Brasileira de Psiquiatria, uma definição do que o estresse pós-traumático, e adentrando nisso,

nós vamos fazer, mais à frente, o paralelo com tema dessa audiência para se mostrar coerente.

O que diz a sua revista sobre estresse pós-traumático? Peço atenção. Isso não é retórico, é muito importante. "*Essa restrição, na amplitude dos afetos, denomina-se entorpecimento psíquico. Pacientes passam a ter dificuldade em rir, chorar, amar, ter ternura, compadecer-se ou sentir atração sexual, parecem 'mortos para vida'. Como se pode ver, o preço pago pelas anestesias dos sentimentos dolorosos é alto. Esses pacientes podem também sentir-se desconectados de si mesmos, de seu ambiente, até de seu futuro, tendo uma sensação de 'futuro abreviado'. Pode parecer-lhes não haver o porvir, param de fazer planos de carreira, de viagem, de tudo. Resta somente um presente tenso, constantemente invadido pelas memórias incômodas do passado*".

E, por obra do destino, voltou à imprensa recentemente um caso, que eu não cito aqui como exemplo de direito ao esquecimento, só menciono para fazer mais um ponto nessa questão da saúde. Vou evitar ou falar o nome, mas é um caso em que uma irmã matou os pais e o irmão tem aparecido na mídia por circunstâncias de ter sido achado desorientado, na rua e etc. Ele falou, em uma entrevista, uma coisa muito interessante, que ele se sentia ferido - ferido -, quando a imprensa tratava do tema ou dos assassinos do seu pai, e menciona também que ele gostaria de mudar de país, para que ninguém o reconhecesse, dado o peso do

seu sobrenome; o seu sobrenome carrega a questão da tragédia, assim como, no caso concreto, rapidamente, o sobrenome dos meus clientes.

E, aí, eu volto ao início da exposição, quando eu falo sobre o *habeas corpus*, sobre a frase de que a liberdade de expressão encontra seu limite no ilícito. E faço a seguinte ponderação: No nosso sistema constitucional, seria razoável considerar que uma veiculação de uma notícia que não seja contemporânea, não tenho interesse público evidente, não se trate de um fato histórico, mas verdadeiramente histórico? Crimes como o de Aída - houve o crime de Aída e houve vários, o de Aída teve sua repercussão, por questões de onde foi feito, por quem foi cometido etc. -, *data vênia*, não é histórico. Histórico são Dom Pedro II e pessoas desse naipe.

Eu pergunto: Dentro dessas circunstâncias, seria razoável conceber a licitude de uma veiculação de uma tragédia, como a da minha cliente ou de outras pessoas, se isso comprovadamente lhe causa esses danos à saúde, se isso lhe transforma no morto para vida, se isso causa sua absoluta incapacidade de se manter social, de fazer planos para vida? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não!

Então, fala-se muito dos requisitos ao direito do esquecimento, restrições e características, mas eu vi muito pouco essa questão, a análise da questão da saúde da vítima. Se ela não é, não seria lícito matar para vida quem quer que

seja por uma notícia de interesse mórbido, uma notícia de interesse do público, uma notícia que eventualmente sirva para vender jornal, para vender publicidade, mas que não agrega nada de novo à sociedade.

Essa ponderação considero crucial para análise específica do direito ao esquecimento da vítima. E, a meu ver, ele é muito mais dramático, muito mais sensível do que o próprio direito ao esquecimento, em gênero, que, às vezes, é do próprio criminoso que, apesar de que eu considero ter o direito a reconhecimento, agiu comissivamente.

E, concluindo, eu primeiro digo que, dentro desse contexto, não considero correto o que eu chamo de falsos medos. O direto ao esquecimento tem sido tratado como um tabu. Não considero o seu tratamento como meramente técnico, muitas vezes pela imprensa, e, até, por alguns artigos doutrinários. Não acredito que ele vá cercear a liberdade de expressão, que ele vá servir de censura. Acredito, sim - e aí faço uma menção a François Ost -, que ele vá servir como uma referência - uma referência. Ele não é obstáculo. Ele é uma referência para aqueles que exercem sua atividade de boa-fé para saber até onde vai a licitude, porque a licitude para - repito - a partir do momento em que se causa um dano terrível à pessoa noticiada pela matéria. Então, considero uma referência, não um obstáculo.

Também acredito que, por ser uma referência - e aí parto até do pensamento de Kant -, existe a questão da previsibilidade. A segurança jurídica

exige um certo grau de previsibilidade. E, nesse sentido, a referência dá essa previsibilidade a todos esses operadores de mídia de imprensa.

Nada será apagado. Fatos não se apagam, o que se limita é a sua divulgação - o que se limita é sua divulgação. Considero esta frase "Vamos apagar os fatos" também de conteúdo retórico. Não acredito que isso seja um primor nessa discussão.

E, concluindo, Excelência, temos o cuidado para não tratar o direito ao esquecimento de uma forma binária. Não é sim ou não! Entre o "zero" e o "um", há um mundo. Há um mundo de circunstâncias que caberá aos magistrados, em todos seus níveis e instâncias, sopesarem. A invocação do direito ao esquecimento, por quem quer que seja, não é uma coisa automática que gerará o cerceamento de uma divulgação. E, a meu ver, a minha humilde sensação é de que - sem nenhum medo de prepotência, estou sendo muito sincero nesta afirmação - o direito ao esquecimento, em gênero ou espécie, é inevitável. É uma questão de tempo. Isso poderá acontecer agora, o julgamento com repercussão geral que Vossa Excelência mencionou. Isso poderá acontecer por obra do Legislativo, eventualmente. Poderá acontecer, sabe-se lá, é o sentimento de isolamento que venhamos a ter no futuro não tão longínquo em relação ao que o mundo pensa e faz sobre o assunto. Contudo, eu considero que há, sim, a oportunidade. Essa oportunidade é valiosa, independentemente do resultado, mas o debate vale por si.

Eu acredito que estamos no momento histórico. É um tema histórico. É a semente de algo muito maior relacionado à proteção das pessoas, à humanização da interpretação do direito, à aplicação das garantias constitucionais dentro de uma nova realidade que não controlamos e que atualmente nos controla. Essa é a oportunidade de não irmos a reboque de elementos externos ou do Legislativo. Creio, sim, que isso vá acontecer. É um direito que não olha para trás; é um direito que olha para o futuro; é um direito que não só vai vingar a proteção das pessoas hoje, mas sobretudo das novas gerações, sobretudo das novas gerações. Não sei quando haverá uma nova oportunidade de se prestigiar a proteção das pessoas, diante desse mundo que não controlamos, da superinformação, superinformacionismo, e outras questões que, infelizmente, não dá para tratar, mas que faz do direito ao esquecimento um instrumento da mais alta relevância. E esse é o momento, a meu ver, oportuno para não irmos a reboque.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço ao Dr. Roberto Algranti Filho pela exposição. Sua Senhoria falou em nome dos recorrentes.

Neste momento, tem a palavra o Prof. Dr. Gustavo Binenbojm, Doutor e Mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro, *Master of Laws* pela *Yale Law School*, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor emérito da Escola da Magistratura daquele Estado. Vossa Senhoria falará pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), e também terá o prazo de quinze minutos.

O SENHOR GUSTAVO BINENBOJM (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO - ABERT) - Bom-dia a todos. Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral da República, Doutor Odim Brandão, senhores servidores, senhores magistrados que servem ao Supremo Tribunal Federal, colegas advogados, eminentes expositores, senhoras e senhores.

Em nome das emissoras de televisão e rádio de todo o Brasil, gostaria de iniciar por uma saudação a essa feliz iniciativa do Ministro Dias Toffoli em designar esta audiência pública para discussão de um tema tão relevante que, a meu ver, definirá o futuro das liberdades de expressão e imprensa, assim como do direito à informação no Brasil. Diria até que é um tema fundamental para a definição da qualidade da democracia que teremos, no Brasil, nas próximas décadas.

E o pano de fundo desse tema, se me permitem um exercício de síntese, é o seguinte: O mero desejo de alguém de não ser lembrado por fatos embaraçosos, desabonadores, ou simplesmente desagradáveis, que tenham acontecido no passado, pode servir de fundamento jurídico para limitar, restringir, ou até suprimir, o exercício de liberdades constitucionais, como são as liberdades de expressão, de imprensa e o próprio direito à informação, na sua tríplice dimensão do direito de informar, direito de se informar e o direito de ser informado? A posição oficial dos veículos de rádio e televisão no Brasil é a de que não existe esse direito. O caso concreto revela, a meu ver, um caso fácil, um caso duro para família - e falo isso com genuíno sentimento de respeito aos familiares da vítima -, mas um caso de repercussão geral, em que as informações veiculadas são verdadeiras - e isso é incontroverso -, em que as informações divulgadas foram obtidas por meios lícitos, um caso que envolve uma pesquisa, inclusive histórica, sobre o sexismo no Brasil, sobre a atuação dos órgãos de persecução penal, sobre a simulação de um crime que acontece, muitas vezes no caso de crimes sexuais, de uma mulher violentada e, depois, submetida a um homicídio que pretendia simular um suicídio. Esse é um caso julgado improcedente em todas as instâncias, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, porque é evidente que, aqui, há um direito da imprensa de veicular essas informações públicas, há um direito do público de se informar sobre esse episódio realmente histórico, lamentavelmente histórico, da

nossa historiografia policial, e, evidentemente, aqui se tem uma pretensão indenizatória, substitutiva a uma pretensão inibitória da liberdade de imprensa. Mas a nossa preocupação - e essa é a razão de o caso ter tomado repercussão geral, corretamente determinada pela Suprema Corte brasileira - é a de importação da crítica, de um modismo e, a meu ver, de uma manipulação totalmente inadequada de precedentes já ultrapassados nos seus países de origem.

É sempre bom lembrar que o Brasil caminhou muito para alcançar o *status* atual de uma democracia respeitada internacionalmente que, pelo menos no que se refere às liberdades comunicativas, tem, no seu Supremo Tribunal Federal, um verdadeiro guardião, que proclamou, naquele histórico caso da ADPF 130 - que sepultou a velha Lei de Imprensa do regime militar -, a primazia *prima facie* das liberdades de expressão, de imprensa e, sobretudo, do direito à informação, e exigiu razões relevantíssimas previstas constitucionalmente, como contravalores que pudessem, de alguma forma, restringir essas liberdades.

Pois bem. O que se tem aqui? Em primeiro lugar, a invocação de um direito que é conceitualmente incerto. É incontroverso que a Constituição brasileira, desde 1988 - e emendada tantas vezes -, não contempla expressamente - nem a legislação infraconstitucional - esse direito ao olvido, como se fora uma espécie de direito à amnésia coletiva, à queima dos arquivos da sociedade. É,

portanto, um direito impreciso, vago, imprestável, inservível, a meu ver, a se elevar à condição de um contravalor justificável para limitar direitos preferenciais, como são os direitos à liberdade de expressão e de informação.

Em segundo lugar, esse suposto direito não está implícito em nenhum outro direito fundamental. Costuma-se invocar o direito à privacidade e à intimidade como fundamentos dos quais se desdobraria um direito ao esquecimento. É preciso, nesse ponto, registrar que a informação verdadeira obtida por meios lícitos é assegurada constitucionalmente, e ninguém pode invocar, por exemplo, o direito à privacidade ou à intimidade pela divulgação de uma informação verdadeira obtida por meios lícitos na imprensa, em um livro ou em um documentário áudio e visual.

É sempre bom lembrar também que a Constituição, em uma garantia assegurada pelo Supremo em inúmeros precedentes, prevê no seu art. 5º, incisos IV, IX e XIV, o direito à plena liberdade e à divulgação da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. No precedente histórico que foi o julgamento da ADI 4.815, em que se discutia a liberdade biográfica, o direito de biografar pessoas contra sua própria vontade ou de seus familiares, a Suprema Corte unanimemente afirmou que, embora previsto no art. 20 do Código Civil - e ali sim havia uma previsão legal expressa -, não há o direito a não se autorizar a publicação sobre quem quer que

seja, quer pelo retratado nessa publicação, quer pelos seus familiares; muito menos um direito decorrente do transcurso do tempo de alguém em impedir a publicação por quem quer que seja.

Além disso, é também falaciosa a ideia de que a liberdade, o direito à informação - e aqui acho a afirmação quase heterodoxa -, refere-se apenas a fatos contemporâneos. Ao contrário, esse direito envolve também fatos pretéritos. A veiculação, a discussão, a crítica sobre fatos passados são matérias essenciais para a construção da memória coletiva e da historiografia social, como aliás são asseguradas também na Constituição, nos artigos 215 e 216.

É sempre bom lembrar que a Constituição não estabelece nenhum prazo decadencial ou prescricional que incida sobre o direito à informação. O simples decurso do tempo não produz, como fato jurídico, o direito à perda da liberdade informativa. E o mero desejo de não ser lembrado por esses fatos desabonadores, desagradáveis e embaraçosos desafia ainda um outro problema muito delicado, que é o da imprecisão conceitual e da indefinição dos limites do que seria esse suposto direito.

Eu pergunto: Quanto tempo terá que se passar para alguém ter o direito de impedir uma publicação sobre um fato relativo à sua biografia? Quais são as circunstâncias históricas ou de interesse público que devem envolver o direito ao esquecimento? Certamente, cada especialista nesta sala terá uma opinião,

cada juiz brasileiro terá uma visão, e a minha visão é de que essa é uma poção letal para o direito à informação, na sociedade brasileira e em qualquer lugar do mundo. Todas as supremas cortes do mundo - desde a Suprema Corte norte-americana, passando pelo Tribunal Constitucional alemão, pela Corte Europeia de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos - são uníssonas em afirmar que o caráter preferencial da liberdade de informação só pode ser relativizado, embora não sejam direitos absolutos, só pode ser delimitado por razões estritamente definidas e precisas, que impeçam a instauração de um regime de ampla discricionariedade por parte das cortes e por parte dos governos, porque seria a abertura de uma Caixa de Pandora. E, aqui, com todo o respeito às demandas individuais, há uma dificuldade da sociedade brasileira e dos operadores do Direito de perceberem que demandas individuais, quando consideradas no seu conjunto sistêmico, têm o potencial de desestabilizar e até destruir um sistema.

É claro, cada qual, individualmente, tem as suas razões, cada pessoa "sabe a dor e a delícia de ser o que é", e invoca, por meio dos seus advogados, a sua dor e o seu sentimento; mas é impossível construir-se uma sociedade verdadeiramente livre, do ponto de vista informacional, uma cidadania devidamente informada e apta a discutir e a deliberar sobre assuntos de interesses

de todos se nós adotarmos um padrão tão amplo, tão subjetivo e tão discricionário como o que algumas cortes brasileiras têm adotado.

Eu discordo, e discordo veementemente, do paradigma do interesse público que o Superior Tribunal de Justiça adotou num caso semelhante a este, em que não se tratava de uma vítima de um crime de grande notoriedade, mas de um cidadão injustamente denunciado pelo Ministério Público, no conhecido e histórico caso da Chacina da Candelária, e que foi absolvido pela Justiça brasileira, pela Justiça do meu Estado; um caso que, pelo seu rigor na sua discrição, tem também uma importância histórica, inclusive sobre as falhas do sistema de persecução penal no país e a forma como aquele homem inocente foi perseguido. Naquele caso, entendeu-se que não havia interesse público; no caso de Aída Curi, o STJ entendeu que havia. Ora, esse é um parâmetro por demais vago, por demais pastoso, por demais impreciso para servir de *standard* para a limitação da liberdade de informação, no Brasil ou em qualquer país do mundo.

O eminente colega que me antecedeu mencionou alguns precedentes internacionais, e eu rapidamente passaria em revista a eles para demonstrar o contrário; para demonstrar que a ideia do direito ao olvido surgiu do segundo pós-guerra, quase que psicologicamente como uma tentativa de absolvição coletiva pelos crimes cometidos naquele período e se projetou em casos individuais a partir dessa construção psicológica. Mas, mais recentemente, no berço

dessa história, como a França, que criou o *Droit à l'oubli*, na Alemanha mais recentemente, e diria, no conjunto da jurisprudência europeia, criou-se uma consciência no sentido de que é a liberdade de informação que deve ter prevalência.

Menciono, em primeiro lugar, o julgamento do caso Lebach II, mencionado aqui da tribuna, em que, em relação aos mesmos fatos, em relação ao mesmo crime, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, em 1999, decidiu que a liberdade de informação prevaleceria, liberando a veiculação do filme em relação ao criminoso, um criminoso condenado pela Justiça, que já havia, sim, cumprido a sua pena, mas que nem por isso tem o direito a apagar da história o fato acontecido.

Menciono ainda o famoso caso de Walter Seidlmayr, julgado em 2009, em que o Tribunal Constitucional da Alemanha vedou o apagamento da história diante da pretensão do autor de desabilitar *links*, desabilitar notícias na *internet* que tratavam dos crimes por ele cometidos.

Na França, a Corte de Cassação Francesa impediu que fossem censurados trechos de um livro no caso *Mme Monanges v. Kern*, julgado em 1990, trechos sobre atitudes condenáveis praticadas pela autora naquele país durante a Segunda Guerra Mundial no bojo do governo colaboracionista de Vichy, acontecido na França no período da Guerra.

E, finalmente, ressalto o caso tão mencionado e tão pouco lido no Brasil, julgado em 2014 pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, do espanhol Mario Costeja Gonzales, em que se afirma ali um direito à desabilitação das ocorrências em um provedor de busca, e o Tribunal, ao fazê-lo, considerou que a notícia do leilão de um imóvel do autor estaria superada pelo fato de que a dívida já estaria quitada. Me parece que a decisão é infeliz, mas a decisão tem alguns *disclaimers* importantes. O primeiro, o de que se entendeu ali não haver interesse público, e isso revela, a meu ver, a problematicidade desse parâmetro tão amplo, mas sobretudo o fato de que se considerou que provedor de busca na *internet* não é veículo de imprensa. E o Tribunal diz que se fosse veículo de imprensa, a decisão teria sido em sentido contrário.

Encaminhando-me já para o fim, Presidente, eu gostaria apenas de sintetizar a posição da ABERT e concluir, dizendo que, no nosso entender, o direito ao esquecimento é um suposto direito não contemplado em nenhuma norma constitucional ou infraconstitucional do país, não é um direito implícito nas dobras de nenhum outro direito fundamental. O direito à informação não está sujeito a prazo decadencial ou prescricional e, portanto, não está limitado no tempo. E o direito à construção da memória coletiva e da historiografia social envolve a discussão, a crítica e a encenação de fatos sobre o passado com a divulgação do conhecimento que atinge as novas gerações.

Na entrada do Museu do Holocausto de Washington, fundado em 1996 pelo presidente Bill Clinton, há uma inscrição bíblica traduzida para o inglês, cuja dicção é *you are my witnesses*, tu és a minha testemunha. E o que se lê abaixo dessa inscrição eu encontrei também num julgado do Supremo Tribunal Federal, ADPF nº 153, em que a eminente Ministra-Presidente, Ministra Cármen Lúcia disse o seguinte:

> "É certo que todo povo tem direito de conhecer toda a verdade da sua história. Todo povo tem o direito de saber, mesmo dos seus piores momentos. Saber para lembrar, lembrar para não esquecer e não esquecer para não repetir erros que custaram vidas e que marcam os que foram sacrificados (...)."

Num museu como aquele que retrata tanto as vítimas como os criminosos - vítimas, dentre elas, ascendentes meus - é que se constrói o futuro da humanidade a partir da verdade, da lembrança e do aprendizado coletivo.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço ao Dr. Gustavo Binenbojm.

As senhoras e os senhores estão percebendo que não estou sendo muito rígido no tempo, confiante no bom senso dos eminentes expositores, dando-lhes o tempo de concluir suas exposições e seus raciocínios - nossa intenção é ouvi-los. O tempo é uma referência - não quero ficar interferindo no raciocínio -, mas se me virem fazendo algum sinal, é exatamente para que nos encaminhemos para o final.

Convido a Dra. Taís Borja Gasparian, graduada em Direito e mestra em Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, Professora de Direito Digital na Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. A Dra. Taís falará pela Associação Brasileiro de Jornalismo Investigativo, a ABRAJI, tendo também o prazo de quinze minutos.

A SENHORA TAÍS BORJA GASPARIAN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO) - Senhor Ministro, Senhor Representante da Procuradoria-Geral da República, senhores advogados, professores.

Eu gostaria de iniciar aqui a minha apresentação, claro, agradecendo a convocação dessa audiência pública, mas sobretudo para dizer que o tema 786, que nos reúne aqui, ele diz respeito à liberdade de informação, mas não apenas à liberdade de informação, que seria interessante ser preservada para, por exemplo, os associados da ABERT ou associados da ANJ, ou associados da ANER, ou *sites*, ou *blogs*. Ele diz respeito aos direitos dos cidadãos, dos cidadãos de obterem informação, de terem acesso a uma informação. É isso o que nós estamos discutindo hoje.

A ABRAJI, é claro, e eu, pessoalmente, entendo, compreendo a dor da família Aída Curi. Claro, nós compreendemos essa dor e nos solidarizamos com essa dor, mas há valores maiores que devem ser defendidos por este Supremo

Tribunal Federal. E, por isso, que o pronunciamento da ABRAJI, aqui - eu já me antecipo - será completamente contrário à adoção do direito ao esquecimento no ordenamento jurídico ou pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

Isso, porque, em primeiro lugar, não há, Excelência, um conceito do que seja exatamente o direito ao esquecimento. Já vimos, em alguns julgados que foram até mencionados, citados pelos meus antecessores, que o direito ao esquecimento se referiria à remoção de um arquivo ou à remoção de um registro. Remoção, essa, que muitas vezes se refere a um fato passado, é verdade, mas muitas vezes também se refere a fatos presentes, fatos que acabaram de ser noticiados. Então, aquelas pessoas que se sentiram de alguma forma prejudicadas ou atingidas por aqueles fatos requerem a remoção daquele registro. Então, por um lado, o direito do esquecimento seria a remoção de um arquivo.

Por outro lado, o direito ao esquecimento muitas vezes também está vinculado à proibição, à vedação de uma veiculação futura, que é o caso dos autos, Excelência. O caso dos autos é o filme que já foi veiculado, não se encontra em nenhum registro. Se qualquer um de nós, aqui nesta sala, quisermos acessar o registro do filme que foi passado pelo Linha Direta, não vamos encontrar esse registro. Não está. Então, não se trata de uma remoção de arquivo, mas, sim, da proibição de uma veiculação futura.

Os autores, com o devido respeito, pretendem que o filme não seja mais veiculado, aquele filme, e que não se toque mais no assunto do horrível assassinato de Aída Curi, que foi um assassinato público e que abalou o Rio de Janeiro, lá, nos idos de 1958. Então, pretendem eles que o filme não passe mais. Excelências, meus caros colegas, essa pretensão é censura. Essa pretensão é censura e ela se vincula, Ministro Toffoli, muito mais ao caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.815, que é a ADI do caso das biografias, ou então à ADPF 130, que ab-rogou a Lei de Imprensa, lá da época do governo militar. Essa pretensão atual é um outro tipo de direito ao esquecimento, que não se fale, que não se veicule uma informação no futuro. O que é extremamente grave, é extremamente perigoso, e nisso que eu falo que existem valores maiores que precisam ser preservados. É o caráter inibitório, como falou o meu colega Gustavo Binenbojm, ele falou justamente do caráter inibitório da pretensão autoral, aqui, no caso. E, na verdade, porque os autores, ao iniciarem o processo, na verdade - o direito ao esquecimento vem depois, a alegação de direito ao esquecimento vem lá nas razões de apelação, não existia isso na petição inicial -, o que buscavam os autores era apenas uma indenização por não ter havido uma autorização. Eu me pergunto também, Excelências, se tivesse havido autorização naquele momento? Se tivesse havido um pagamento por essa indenização? Haveria alguma coisa a ser esquecida? Teriam, os autores, então, se tivesse havido autorização, teriam os autores requerido o

direito ao esquecimento à época? Tem que perceber direitinho que, na verdade, os parâmetros, aqui, foram mudados no decorrer do processo. Não se consegue depreender exatamente, então, o que seja o direito ao esquecimento, Excelência. Há, inclusive, quem defenda que o direito ao esquecimento seja a desindexação de informações das ferramentas de busca, que quando se faz uma busca, não apareça nos resultados da busca aquela informação.

Então, nós temos, aqui, pelo menos agora, e que eu me lembre, que consigo delinear, três tipos de direito ao esquecimento: o da remoção, o da proibição de veiculação futura e o da desindexação. Não há, não temos um parâmetro, não temos um contorno do que seria o direito ao esquecimento. Os tribunais do país, apesar disso, eles têm proferido decisões, decisões erráticas, decisões que cada hora são num sentido e decisões, então, que não se referem, se fecham num conceito do direito ao esquecimento, ou seja, que também é prejudicial. Daí, também, a importância do que nós estamos discutindo.

Os meus colegas que me antecederam já mencionaram que o sistema jurídico brasileiro não prevê um direito genérico de ser esquecido, no sentido de que uma pessoa tem que limitar a difusão da informação. Falaram, aqui, não apenas do inciso XIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito à informação, mas também lembrar que a Constituição Federal permite que os cidadãos exijam a informação. E que a informação, o direito à

informação, só pode ser suspenso em um caso extremamente grave, estado de sítio, numa situação completamente excepcional. Então, fora isso, a Constituição Federal não admite qualquer direito ao esquecimento, que venha a ser esse direito ao esquecimento.

A ABRAJI tem o temor, Excelência, que, em nome do legítimo interesse de atender ao pedido dos autores, por um lado, e tentar, por outro, compor e ponderar os princípios constitucionais da informação, do acesso à informação, com aqueles da privacidade, nome e imagem, que esse Supremo Tribunal venha, por algum modo, restringir o direito à liberdade de informação.

Apenas à história, senhores, caberia a distinção do que deve ou não deve ser lembrado. Não somos nós que vamos decidir. Aliás, eu me pergunto: A qual título, uma pessoa, um governo ou mesmo um tribunal, Excelência, poderá decidir o que será e o que não será lembrado no futuro. A quem os cidadãos teriam outorgado esse direito de decidir o que será ou o que não será lembrado no futuro do seu povo, da sua comunidade e da sua história? É muito grave! Nós estamos falando de uma questão e de um valor muito maior do que o interesse legítimo - é claro -, mas particular da família de Aída Curi. A *internet* é um templo da memória. Já se disse que remover arquivos - e estou falando só de um dos tipos de conceito de direito ao esquecimento - seria o mesmo que queimar livros.

Eu trouxe uma pequena apresentação, Excelência, de um projeto da ABRAJI (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), o Projeto "Ctrl+X". Esse projeto é um começo de tentativa de fazer algum mapeamento sobre as ações da Justiça que visam à restrição de divulgações de informações em diversos níveis - remoção de conteúdo, abstenção de divulgação de uma informação, apreensão de publicações, inclusive suspensão de transmissão de rádio e TV.

Nós percebemos, Excelência, duas coisas. Em primeiro lugar, há um aumento das ações que buscam a remoção de conteúdo da *internet*, e esse aumento, Excelência, por incrível que pareça - não sei se é tão incrível, não sei se também isso é tanta surpresa assim -, dá-se, sobretudo, por políticos e partidos políticos. Os senhores podem notar, em 2012, 2014, 2016 - eu não estou me referindo ao anterior, de 2010, porque ele ainda estava no começo desse levantamento do "Ctrl+X", e, em 2016, os números ainda não estão fechados porque tem um *gap* entre conseguir essa informação -, o aumento ano a ano, ou eleição a eleição, período eleitoral a período eleitoral, do número de políticos e partidos políticos que pretendem remover conteúdo da *internet*, em oposição às outras pessoas, aos cidadãos, que também podem ter essa mesma pretensão.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) – Dra. Taís, só uma pergunta, porque eu não vejo no *slide*. Isso são ações judiciais?

A SENHORA TAÍS BORJA GASPARIAN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO) - Sim, desculpa, eu não fui clara nisso! Sim, ações judiciais, é o mapeamento de ações judiciais no país.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Porque, muitas vezes, também há o pedido administrativo feito diretamente ao órgão da rede social.

A SENHORA TAÍS BORJA GASPARIAN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO) - Não, não, isso daqui são só ações judiciais, é um levantamento que o "Ctrl+X"... "O Ctrl" + X, eu acho que mostrei aqui no *slide* anterior...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Esse projeto, então, é em relação a processos no Poder Judiciário?

A SENHORA TAÍS BORJA GASPARIAN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO) - Poder Judiciário no Brasil todo. Eles fazem um levantamento com as empresas e também, é claro, acompanham no Judiciário. Isso daí eu fiz uma comparação, Excelência - quer dizer, o Ctrl + X fez -, eu fiz essa retirada para mostrar também em relação aos anos não eleitorais. Então, o que é grave perceber é que não apenas quem mais busca a remoção de conteúdo são os partidos políticos e os políticos, mas, pior, eles buscam

isso nos anos eleitorais, quando justamente, Excelência, as pessoas poderiam, deveriam ter acesso a essas informações! Nesses anos eleitorais é que as pessoas têm que ter acesso à informação, aos seus candidatos. Aliás, nós temos visto o quanto de informação a gente deveria ter.

Então, é só para esclarecer, Excelência, mais um dado aqui, é a diferença das eleições municipais de 2012 e 2016. Houve um aumento, nessas duas eleições municipais - e estamos falando das eleições municipais porque são as eleições que têm mais candidatos, não é eleição presidencial -, de 35% em 2016 com relação a 2012 e, em 2016, o período de propaganda eleitoral foi a metade, muito mais curto do que o de 2016, porque tinha reduzido de 90 para 45 dias, e, mesmo assim, ainda houve um aumento de 35% dos políticos e partidos políticos que requereram o direito à remoção de conteúdo.

Bom, isso tudo é para chamar a atenção do oportunismo e também da instrumentalização do Judiciário que se pode ter nessas situações. É para isso que eu pretendo, que a ABRAJI pretende chamar à atenção, que pode ser. É claro, tem um direito pessoal da família de Aída Curi, mas, por outro lado, há um valor muito maior: se o direito ao esquecimento, Excelência, for de algum modo acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, dará vazão a esse tipo de solicitação, e que, muitas vezes, acabarão sendo aceitas, como disse o meu colega Gustavo.

Daí a importância, Excelência, de que seja prestigiado o direito à informação. A ABRAJI, inclusive - o que eu vou falar aqui pode causar espanto -, defende que mesmo informações erradas não sejam removidas. As informações erradas devem ser corrigidas, complementadas e, eventualmente, até indenizadas, se for informação que tiver sido errada, mas não removida dos arquivos, porque a existência dessas informações, quando elas forem corrigidas e complementadas, eventualmente, serve e servirá, no futuro, para nós percebemos o quanto que, eventualmente, os veículos, *blogs*, erraram. É importante a gente saber essa informação, então, mesmo a informação errada tem que ser complementada, tem que ser corrigida, mas pode ser corrigida na *internet*, pode-se colocar *link*, pode-se colocar uma nota de que aquela informação foi considerada errada e daí a versão correta, mas não removida, não retirada. Isso daí parece-me desculpa, é completamente abusivo.

Mesmo - eu imagino que isso daqui seja tratado pelos meus colegas da tarde - a questão da reabilitação, Ministro. A questão da reabilitação, o direito do réu condenado e reabilitado não alcança a imprensa, não pode alcançar a imprensa. Eu sei que há muitas correntes que defendem isso, mas o que a lei assegura ao réu condenado e reabilitado é o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Isso significa apenas que a condenação não deve ser mencionada em folha de antecedentes ou certidões, isso não pode ser aplicado estendido para a

imprensa! Esse instituto não alcança a imprensa, mesmo porque a reabilitação pode ser revogada. E a informação apagada vai voltar para os arquivos, não me parece razoável que esse argumento também seja colocado.

Tudo isso, Excelência, e encerrando - eu já vi que meu tempo terminou -, só para demonstrar que interesse, poder e exclusão são ingredientes nefastos à memória de um povo. Os arquivos e os acervos servem para estabelecer uma identidade coletiva, e também servem de prova de fatos que, muitas vezes, Excelência, como temos diversos exemplos históricos, são deliberadamente esquecidos pela versão oficial da história.

É essa a posição da ABRAJI.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço à Dra. Taís Borges Gasparian, que falou pela *amica curiae* ABRAJI. Eu sugeriria a Vossa Senhoria, e o próprio Ministério Público assim se manifestou agora enquanto Vossa Senhoria apresentava esses dados, que fizesse a juntada dos dados dessa pesquisa CTRL+X, exatamente para que faça parte dos registros da audiência pública e do processo.

E, mais uma vez, eu relembro que, finalizada esta audiência pública, os materiais trazidos e as exposições serão encartadas ao processo. Obviamente, darei, depois, novamente, a possibilidade de manifestação das partes

e da Procuradoria-Geral da República, para que opine novamente, já tendo em vista os debates realizados na audiência pública.

Convido agora para falar em nome da Associação Nacional de Jornais e Associação Nacional de Editores de Revistas, o Prof. Dr. Daniel Sarmento, mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-doutor pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, advogado e professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

O SENHOR DANIEL SARMENTO (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS - ANJ E ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS - ANER) - Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, a quem eu parabenizo pela feliz iniciativa de convocar audiência pública sobre esse tema tão importante. Excelentíssimo Doutor Odim Brandão, representante do Ministério Público Federal, senhores expositores, senhoras e senhores advogados, servidores e jornalistas.

A Associação Nacional dos Jornais e a Associação Nacional dos Editores de Revistas, que são entidades representativas de segmentos extremamente importantes da imprensa brasileira, manifestam-se contrariamente ao reconhecimento do direito ao esquecimento como um limite às liberdades

comunicativas: liberdade de expressão, liberdade de informação e liberdade de imprensa.

Essas liberdades públicas - liberdade de expressão, de informação e de imprensa - desfrutam, na ordem jurídica brasileira, de uma posição preferencial, como já vem reconhecendo o Supremo Tribunal Federal e na linha, também, da jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, da Corte Constitucional colombiana, espanhola, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Europeia de Direitos Humanos. E por que se fala da existência dessa posição preferencial dessas liberdades públicas? No caso brasileiro, em primeiro lugar, em razão da nossa história. A Constituição de 88 foi erigida, em boa parte, como resposta a uma história da qual nós não temos muita razão em celebrar, de censura e de constante limitação às liberdades públicas.

Uma história que começa já na carta escrita por Pero Vaz de Caminha, cuja divulgação foi censurada, na época, por um padre. História que prossegue em quase todas as fases da nossa trajetória, chega ao governo militar e foi contra isso que se insurgiu a Carta de 88, o constituinte brasileiro. Mas, sobretudo, em razão dos valores que justificam e alimentam essas liberdades públicas: a democracia - e não há democracia sem a possibilidade de debates públicos, sem acesso a informações de fontes diversificadas, sem a possibilidade de criticar autoridades, sem entrechoque de opiniões - e a própria dignidade humana,

que foi invocada em favor do direito ao esquecimento. O ser humano é, acima de tudo, um ser que se comunica, que necessita exprimir as suas ideias. Cada pessoa tem boa parte da sua própria identidade forjada pelos livros que leu, pelos filmes que assistiu e pelas interações comunicativas que travou com outros, pela busca da verdade. A premissa é de que a melhor forma de se alcançar a verdade é num debate público, em que todos possam ter a possibilidade de se exprimir, e porque essas liberdades, ao fim e ao cabo, são instrumentos para a garantia de todos os direitos. A possibilidade de, por exemplo, criticar autoridades, a possibilidade de protestar, é uma salvaguarda do direito à saúde, que foi citado aqui, quer dizer, protestar, por exemplo, contra o descaso com a saúde. A garantia do direito à vida, enfim, a garantia de todos os direitos fundamentais, em boa parte, está ligada a essas liberdades públicas.

Não há nenhuma razão pela qual se deva restringir essas liberdades ou afirmar que elas têm força exclusivamente em relação a fatos, eventos e informações contemporâneas. Fazê-lo significa negar a importância da própria história.

Eu encontrei uma passagem interessante, que é a primeira frase do primeiro livro de história de que se tem notícia, o livro de Heródoto chamado "Histórias". O livro começa assim: essas são as pesquisas de Heródoto de Halicarnasso, que ele publica na esperança de preservar do esquecimento a

lembrança do que os homens fizeram. Esquecimento é o antônimo de história. E por que é preciso que haja uma história? História não é apenas uma questão de cultura geral; história não é apenas conhecer o passado; a história é essencial para não repetir os erros que uma sociedade já cometeu. As práticas e as instituições não são que nem Atenas: parida já com as suas armas na cabeça de Deus; elas são forjadas historicamente.

Então, para conhecer as práticas instituições, tal como elas hoje existem, a história é absolutamente indispensável. E história não é apenas a recordação dos feitos dos grandes homens ou das grandes mulheres, das guerras, dos eventos - vamos dizer assim -, que são, às vezes, recordados naqueles livros, enfim, que a gente lia nos livros de história de 30 anos, de 40 anos atrás. Hoje fala-se de uma nova história. A nova história, enfim, é um movimento que foi deflagrado especialmente na França, a partir da *École de Annales*, que parte da afirmação de que também são fatos históricos a vida das pessoas comuns; que também é importante para a história reconstituir os hábitos: alimentação, a sexualidade. Então, cingir a relevância da história, a recordação desses fatos envolvendo, por exemplo, grandes autoridades públicas é uma compreensão absolutamente limitadora da história, que não é compatível com conhecimento historiográfico contemporâneo.

E essa é uma preocupação especialmente relevante num país que nem o nosso, num país que nem o Brasil em que, historicamente, a nossa questão nunca foi de excesso de memória, mas amnésia coletiva; num país em que é muito mais frequente empurrar-se os problemas do passado para debaixo do tapete, para que eles não sejam enfrentados, do que a inundação com informações. Portanto, inclusive diante das necessidades nacionais, não parece razoável erigir-se esse direito ao esquecimento como um obstáculo às liberdades de expressão, às liberdades de informação e de imprensa.

Direito, a gramática do direito pressupõe a potencialidade de universalização. Quando se fala de um direito, isso significa dizer que todas as pessoas, na mesma situação, podem invocá-lo. Ora, em cada evento, na sociedade, há sempre alguém que não vai gostar; há sempre alguém que preferia que aquilo fosse esquecido, que aquilo não fosse lembrado. Então, essa ideia de que, com o passar do tempo, é possível impedir o acesso a fatos desagradáveis, a fatos desabonadores, a fatos embaraçosos, se ela se universaliza como direito, isso significa simplesmente apagar-se a história, inviabilizar-se o estudo da história; significa, simplesmente, impedir que a liberdade de expressão, de informação e de imprensa, enfim, incida sobre um dos aspectos mais relevantes no seu campo de aplicação.

Como foi destacado aqui já, pelo professor Gustavo Binenbojm, os precedentes que vêm sendo invocados em nome do reconhecimento do direito ao esquecimento, muitos deles já foram superados, inclusive nos seus próprios países de origem. Nos Estados Unidos - eu li a erudita decisão do Ministro Salomão -, citou-se precedentes que o Judiciário Norte-americano, a Suprema Corte Norte-americana explicitamente já disse que não estão mais valendo. Na Alemanha, o grande caso recordado, o caso *Le Bahr*, depois houve o caso *Le Bahr II*, em que se permitiu exatamente aquilo que o *Le Bahr I* não tinha autorizado.

Como foi recordado aqui, no caso Mario Costeja González, que envolveu o *Google*, não estava em discussão a liberdade de expressão, uma das premissas foi: "Olha, nós estamos decidindo dessa forma, porque isso não é exercício de liberdade de expressão e liberdade de imprensa". E recentemente foi editado, inclusive, um regulamento, no âmbito da União Europeia, Regulamento 679, de 2016, sobre tratamento de dados de pessoas, que foi elaborado, tendo em conta essa demanda sobre o direito do esquecimento, e ele, no seu artigo 17, item 3, diz expressamente: "Esse direito não se aplica, não incide em matérias que envolvam o exercício de liberdade de expressão e de informação". Portanto, o cenário do Direito Comparado não é esse que, muitas vezes, se retrata.

Há outro ponto importante para destacar - eu já me aproximo do fim da minha exposição - que diz respeito à responsabilidade civil. O direito ao

esquecimento, muitas vezes, é invocado para se impedir determinadas publicações, para se desindexar, enfim, de provedores de busca, determinadas ligações. Mas ele também vem sendo exercitado, e o caso concreto que ensejou essa audiência pública é exemplo disso, no afã de se obter reparações pecuniárias, por vezes, por danos, ou por danos morais cumulados com danos materiais.

É muito importante lembrar que a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade de informação, elas não apenas importam em vedação à censura prévia; elas também se projetam ulteriormente no que concerne à responsabilidade civil, como vem enfatizando, inclusive, o Supremo Tribunal Federal.

Aqui, é preciso não (ininteligível) do risco dos chamados *chilling effect*, ou efeito resfriador do discurso, por quê? Reparações de danos, a disseminação do regime de reparação de danos pode desestimular que os meios de comunicação, os veículos de imprensa, as pessoas exerçam a sua liberdade de expressão temerosos que, sobretudo o manejo de conceitos muito vagos, como é esse do direito ao esquecimento, possa redundar na imposição de perdas e danos.

Esse é um conceito extremamente importante que foi, enfim, difundido especialmente numa decisão da Suprema Corte Norte-Americana, no caso *Sullivan vs. New York Times*, talvez o mais importante precedente de liberdade de imprensa no Direito Comparado, que era exatamente sobre o risco de que

regime ulteriores de responsabilização inviabilizem ou dificultem o exercício das liberdades públicas.

Isso não significa dizer que não seja possível, em nenhuma hipótese, a reparação de danos em caso de abuso no exercício das liberdades comunicativas. Mas é essencial para tanto que se configure o abuso, quer dizer, difundir, divulgar, discutir fatos do passado, ainda que desabonadores, ainda que constrangedores, não constitui, só por si, abuso de forma alguma: trata-se de exercício regular de direito e que, portanto, não pode e não deve gerar direito à reparação de danos.

Um último ponto, Ministro Dias Toffoli, que eu gostaria de ressaltar, vem muito na linha de decisões que Vossa Excelência vem proferindo, criticando uma certa a banalização dos princípios da ponderação, por vezes até uma certa carnavalização, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, ao temor de que, enfim, categorias tão vagas possam, manejadas na prática, gerar absoluta insegurança jurídica em detrimento especialmente da sociedade que, ao fim e ao cabo, é a principal beneficiária dessas liberdades públicas.

É fundamental, especialmente no contexto de uma sociedade, em que ainda infelizmente viceja uma cultura censória, em que ainda infelizmente viceja uma cultura não igualitária no que concerne à tutela do direito da personalidade, que não se remeta, de modo vago, a uma ponderação futura em que

cada caso é um caso, e que os juízes resolvam, por meio da proporcionalidade, se há ou não direito ao esquecimento.

É fundamental que o Supremo Tribunal Federal estabeleça um parâmetro claro, impedindo que esse suposto direito ao esquecimento seja invocado para impedir a divulgação e a discussão, enfim, de fatos verídicos, reais, apenas porque acontecidos no passado.

O Supremo Tribunal Federal vem sendo, em que pese a presença dessa cultura censória na sociedade brasileira, um aliado importante das liberdades comunicativas, proferindo decisões belíssimas nessa área.

Enfim, a Associação Nacional dos Jornalistas e a Associação Nacional das Editoras de Revistas têm a convicção de que, nesse caso, não será diferente.

Jorge Orwell, na sua obra 1984, numa passagem que se referia ao autoritarismo dos líderes de Oceânia, disse o seguinte: "Aquele que controla o passado, controla o futuro; aquele que controla o presente, controla o passado". Não é possível que, no regime constitucional, que valoriza tanto as liberdades públicas, se conceda a autoridades a possibilidade de dizer que, passado, podemos discutir que informações podem ser rememoradas pela cidade brasileira.

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço ao Dr. Daniel Sarmento. Registro que também estava deferida a participação, no período da manhã, do Instituto Lavoro, com a exposição da Dra. Karina Balduino Leite. O instituto encaminhou informação justificando a impossibilidade de a pessoa indicada comparecer no dia de hoje.

Convido para falar a Profª Drª Cíntia Rosa Pereira de Lima, graduada pela Faculdade de Direito da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; pós-doutora em Direito Civil pela *Universitad Del Studi Di Camerino*, na Itália, e professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, pela qual falará. Sua exposição também tem quinze minutos.

A SENHORA CÍNTIA ROSA PEREIRA DE LIMA (FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO) - Bom dia.

Saúdo o Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator Dias Toffoli pela belíssima iniciativa em debater um tema de tamanha relevância e complexidade; Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral da República, Doutor Odim Brandão; senhoras e senhores servidores; senhoras e senhores aqui presentes;

aos meus colegas expositores, especialistas sobre um tema que me é tão caro, direito ao esquecimento, e que hoje estamos todos a debater.

Eu venho representar a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, na qual sou professora livre-docente de Direito Civil, onde desenvolvo a minha linha de pesquisa - Direito *Internet*. Em razão dessa minha linha de pesquisa, realizei um pós-doutorado sobre direito ao esquecimento na *Universitad Del Studi de Camerino*, na Itália, em 2013/2014, com fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, instituição que venho a público agora agradecer pelos constantes fomentos à pesquisa, sendo esses fundamentais para o avanço da pesquisa científica no Brasil. Dessa pesquisa de pós-doutorado, resultaram três publicações nacionais e uma publicação na Itália, onde apresentei, inclusive fiz uma conferência, intitulada *La dinamicità del diritto allo blio il pericolo del sua non flessibilità come diretti dalla Supremo Tribunale Federal Brasiliano.* Esse congresso foi da *Catedral Unesco, "Diritti umani eviolenza: governo e governanza"*, organizado pela professora Maria Cristina de Cicco, da *Universitad Del Studi Di Camerino*, foi um congresso intitulado *"Diritto alla verità, alla memoria, all'oblio"*. E, lá, já tendo sido reconhecida a repercussão geral do caso, eu destacava os perigos de uma fixação, de um entendimento para um conceito propositalmente vago, amplo, que é o direito ao esquecimento. E, nesse sentido, corroboro com a preocupação do Excelentíssimo

Senhor Procurador-Geral da República, que esse seria um caso para ser analisado casuisticamente, fazendo a ponderação para os fatos em concreto.

Tendo em vista o despacho convocatório, em que uma das preocupações era realmente o conceito jurídico do direito ao esquecimento, e se a vítima somente poderia pleitear, ou se os familiares da vítima poderiam também pleitear, eu vou dividir as minhas contribuições em três partes. Primeiro, eu quero destacar os desafios sobre a tutela privada de direitos de personalidade na sociedade informacional. A segunda parte é sobre direito ao esquecimento, na qual eu quero destacar um conceito que foi objeto das minhas publicações sobre o tema e as limitações no exercício desse direito. E, por fim, na terceira parte - já que foi objeto de manifestações anteriores -, quero fazer a distinção entre o direito ao esquecimento e o direito à desindexação. Então, eu quero fazer a diferença da natureza jurídica do direito à desindexação, que, por vezes, tem por base o direito ao esquecimento, mas tem natureza jurídica distinta, como pretendo demonstrar.

Na primeira parte, eu quero destacar que a tutela privatística dos direitos de personalidade enfrenta o desafio que o saudoso professor Orlando Gomes já apontava nas suas doutrinas, que é o conceito limitado de bem. Então, não necessariamente a tutela de um direito de personalidade tem a finalidade econômica, patrimonial. A finalidade, sim, é o desenvolvimento pleno da condição humana, tendo em vista a dignidade que a própria Constituição garante no Brasil.

Nesse sentido, Pietro Perlingieri, na Itália, fala que o fundamento para a tutela privada dos direitos de personalidade é único: o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Mas as suas manifestações são as mais variadas possíveis. Então, muito embora os artigos 11 a 21 do Código Civil não tenham mencionado expressamente um direito ao esquecimento, ainda assim ele pode ser considerado, pois a menção desses artigos é apenas exemplificativa. Assim, em um caso concreto, esses direitos para o desenvolvimento da personalidade humana devem ser assim tutelados; valendo-me, inclusive, da conclusão de Capelo de Sousa de que o direito de personalidade deve ser considerado como um insofismável direito subjetivo privado, e, dessa forma, devem ser tutelados.

Na segunda parte da minha exposição, sobre o direito ao esquecimento, eu sustentei que é um direito autônomo de personalidade. Por vezes, o direito ao esquecimento tem a sua gênese, a sua origem na *riservatezza*, na expressão italiana, ou *privacy*, na inglesa. Mas ele não é só privacidade e nem só proteção de dados pessoais decorrentes da autodeterminação informacional. Ele vai além disso.

Valendo-me de uma expressão da síntese de Maximiliano Mezzanotti, o direito ao esquecimento teria um *corpus* de identidade pessoal - ou seja, o direito de ser si mesmo - e tem um *animus* de direito à privacidade; porque

geralmente o que se busca é que as pessoas não se imiscuam em determinadas situações da vida particular.

Então, eu já sustentei, em alguns trabalhos, que o direito ao esquecimento é um direito autônomo de personalidade por meio do qual o indivíduo pode excluir ou fazer com que essas informações não sejam acionadas de maneira trivial. Mas esse direito, assim como tantos outros direitos, não é absoluto; ele sofre limitações. Na Itália e em alguns outros países - mas eu vou falar especialmente da Itália, pois foi onde realizei a minha pesquisa de pós-doutorado - , as limitações, primeiro, dão-se no decurso de um tempo razoável, e, consequentemente, há perda de utilidade dessa informação para a sociedade.

Também não se pode pretender, com o direito ao esquecimento, reescrever-se a história. Não é isso que se busca: reescrever-se a história ou alterar-se a verdade dos fatos. O que se busca é não ter a identidade de um determinado indivíduo estigmatizada por fatos ocorridos no passado que deixaram de ter uma relevância pública.

E, por fim, há a necessária ponderação entre direitos de personalidade e a liberdade de expressão. Até porque, já foi aqui objeto, o artigo 220, § 1º, da Constituição Federal menciona uma limitação à liberdade de expressão: a tutela de direitos de personalidade.

Enfim, eu queria fazer uma distinção; porque para a correta compreensão do conceito de direito ao esquecimento é fundamental entender direito à desindexação. O direito à desindexação é, na verdade, uma listagem de informações que são coletadas ou armazenadas em diversos provedores de conteúdo, e essas ferramentas de busca elencam as informações. Cito, então, o caso Gonzáles *X Google*, que veio à tona. E, inicialmente, eu ia defender a minha livre docência "direito ao esquecimento", mas tive que mudar porque, justamente quando voltei da Itália, a tecnologia tinha avançado tanto que o tema já era notório, e precisei escrever outra tese, mas eu havia estudado bastante o caso. Lá se questionava se as ferramentas de busca realizam atividades consideradas como tratamento de dados pessoais; se sim, se o titular desses dados teria direito de se opor a esse tratamento. Por fim, qual a legislação aplicável, já que o *Google* tem sede nos Estados Unidos e o caso foi julgado, inicialmente, pela Agência Espanhola de Proteção de Dados e, depois, culminou com o julgamento do tribunal da Corte de Justiça da União Europeia.

Esse caso foi paradigmático porque, sim, o Tribunal entendeu que as ferramentas de busca realizam atividades consideradas pela Lei da Proteção de Dados Pessoais - que antes era a Diretiva 95/46, hoje é o Regulamento Geral 679, de 26 de abril do ano passado. O Tribunal entendeu que o titular dos dados teria direito de se opor, porque faz parte de um dos direitos de todo sistema de proteção

de dados. E, por fim, aplica-se a legislação porque a atividade de tratamento de dados, seja a coleta ou mesmo parte do tratamento, foi realizada em território europeu, portanto, teria competência tanto o Tribunal de Justiça Europeu quanto a legislação aplicável, o Direito Comunitário Europeu.

Pizzetti Franco define o direito à desindexação como o direito de não ver facilmente encontrada uma notícia que não seja mais atual. Ele destaca que a utilidade dessas ferramentas de busca é elencar essas notícias de maneira a facilitar, para os usuários, o encontro dessas informações, mas, quando essas informações deixam de ser atuais - porque as ferramentas de busca não fazem um controle qualitativo desses dados -, ficam à mercê do titular dos dados que queira corrigir, retificar ou complementar essas informações.

Finalizando a minha intervenção, o Professor da Universidade de Oxford, Viktor Mayer-Schönberger, tem um livro muito interessante, *Delete* - que é apagar. Por ocasião do julgamento *Google vs Gonzáles*, ele veio, foi entrevistado - inclusive essa entrevista publicada no Estadão - e concluiu que a *internet* precisa nos permitir esquecer. E ele destaca que o esquecimento é fundamental para a evolução do ser humano e para o perdão.

Assim como a *internet*, a televisão é um meio de comunicação em massa, e aí eu questiono, valendo-me dessa frase: a televisão também tem que nos permitir esquecer alguns fatos, ainda mais quando, num caso concreto, a

ponderação entre esses direitos de personalidade e liberdade de expressão impõem pela proteção dos primeiros.

Sobre o direito à desindexação, muito embora de uma maneira mais restrita, mas, ainda assim, no Marco Civil da *Internet*, o artigo 7º, inciso X, garante:

> "X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, (...)" - por isso eu digo que é um pouco mais restrito.
> Mas o projeto de lei de proteção de dados que ora tramita na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 5.276-a, estabelece como direito a "eliminação, a qualquer momento, de dados pessoais". Inclusive por questão de *compliance* internacional, no Direito Comunitário Europeu, essa foi uma determinação, por isso a *Google*, por exemplo, tem um formulário para excluir conteúdos, basta o indivíduo preencher esse formulário informando o endereço da página em que consta esse conteúdo, e ele pode ser excluído. É por uma questão de *compliance*, em razão da circulação transfronteiriça de dados pessoais. O mesmo padrão de proteção de dados que a *Google* pratica na União Europeia, ela tem que replicar em outros países.

Então, aqui, a minha ponderação é pela necessária análise casuística do direito ao esquecimento, que muitas vezes é usado como fundamento para desindexação, e pontuar desde já que este julgado não seja um julgado que vai

fundamentar necessariamente as ferramentas de busca, porque essa análise, aí a natureza jurídica, não é um direito de personalidade, mas decorrente da proteção de dados. Então, a desindexação decorre do sistema de proteção de dados, autodeterminação informacional.

O direito ao esquecimento é uma ponderação de valores, caracterizado como um *corpus* de identidade pessoal, *animus* de privacidade, portanto, uma natureza jurídica e formas de tutela distintas.

No mais, me coloco à disposição para ulteriores esclarecimentos e debates, sendo essas as minhas colaborações.

Obrigada!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço à Profª Drª Cíntia Rosa Pereira de Lima.

Nós estamos verificando que, com o desenrolar das manifestações, vai-se realizando exatamente o propósito da audiência pública de proporcionar uma visão ampla e geral sobre o assunto. Iniciamos com os requerentes. O Prof. Gustavo Binenbojm, segundo a falar, embora tenha falado pela ABERT, é procurador nos autos. Então, evidentemente, as duas primeiras manifestações foram mais voltadas ao caso específico. Depois, falou a Taís como *amica curiae*. O Prof. Daniel Sarmento, como li no relatório, proferiu parecer também. E, agora, passamos a ouvir outros especialistas, que vão trazer visões para

além do caso específico, para além da repercussão geral. E é para isso mesmo que a Audiência Pública é convocada.

Agora eu convido para fazer sua exposição o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Carlos Costa Netto, do Tribunal de Justiça de São Paulo, meu Estado, que é mestre e doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, e é um grande especialista em Direito da Personalidade. Agradeço sua presença.

Também Vossa Senhoria terá 15 minutos para sua exposição.

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS COSTA NETTO (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO) - Agradeço a Vossa Excelência, Ministro Dias Toffoli, pela oportunidade desta Audiência Pública.

Como desembargador, na verdade, eu assumi a minha posição pelo quinto constitucional. E eu fui advogado, durante quase 35 anos, na matéria Direito de Autor. O Direito de Autor acaba discutindo matérias de Direito da Personalidade. Então, até muito honrosamente, a sua assessoria me colocou como especialista em Direito da Personalidade. Na verdade, a minha especialização é Direito de Autor, mas, inclusive, um dos direitos da Personalidade é o Direito Moral de Autor, que Pontes de Miranda até chamava de Direito Autoral de Personalidade, porque cabe ao Autor garantir a intangibilidade da autoria, a paternidade da obra e a integridade da sua obra. Então, são elementos tão

importantes que foram alçados à categoria de direitos da Personalidade. Então, com esse caminho inicial, eu acabei me interessando muito pelo assunto. E eu diria, na verdade, que eu sou mais um curioso na matéria do que os grandes especialistas que me antecederam.

Nesse sentido, eu gostaria de ressaltar que, talvez, como uma indicação bibliográfica, a leitura de Adriano De Cupis, que, nos anos 40, tratou praticamente, precursoramente, a matéria no Direito italiano, e, no Direito português, o Rabindranath Capelo de Sousa é um grande especialista na matéria de Direitos da Personalidade, que eu acho que é muito caro aqui isso ser estudado com profundidade. E, no Brasil, também temos o precursor Antônio Chaves, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Carlos Alberto Bittar, que tem inclusive uma monografia publicada sobre a matéria Direitos da Personalidade; Rubens Limongi França, que tem um artigo realmente muito importante nessa matéria; E, por fim, a Professora Silmara Juny Chinellato, que é titular, catedrática de Direito Civil da Universidade de São Paulo, e que a tese de titularidade dela foi justamente Direitos de Autor e Direitos de Personalidade, frente ao Código Civil.

Então, são elementos importantes a serem trazidos na discussão dessa matéria, que também foi alçada à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, muito relevante a posição de Vossa Excelência nesse sentido, porque existem realmente alguns caminhos aí que estão sendo traçados, e é importante que

o Supremo discuta, como discutiu também as biografias, com muita pertinência, e essa matéria.

O primeiro que me chamou... Então, o direito ao esquecimento, eu vou abordar no fim, mas eu vou traçar o direito da personalidade para mostrar a relevância dessas questões no Direito.

E o interessante que os direitos da personalidade, eles surgiram, esse interesse, com a Segunda Grande Guerra Mundial. Por quê? Porque existiam regimes. Nós temos regimes de direita, de esquerda, o stalinismo, o fascismo, o nazismo. E realmente foi muito equacionado a partir do término dessas guerras como proteger o cidadão naquilo que ele, não só na questão do interesse público que ele pudesse ter, mas naquilo que seria mais importante dentro da sua sobrevivência como pessoa, que se fala em dignidade humana. Quais seriam esses elementos que nenhum regime poderia invadir e minimizar? E, aí, pensou-se realmente em um elenco de alguns direitos da personalidade, que eram: o direito à vida, o direito - vejam só os Senhores - às partes destacadas do corpo - coisas que só as pessoas mesmo pudessem realmente ceder a sociedade, senão seria uma invasão do mínimo que elas teriam na sua circunferência de Direito Privado.

E, entre esses bens fundamentais, foi incluído, como eu falei, o direito moral de autor, que seria o direito da pessoa exigir que uma obra, se está sendo publicada em nome de outra pessoa, se é dela, de ela assumir a autoria. Ou

também quando uma obra é totalmente transformada, de se evitar que essa transformação, que essa mutilação ocorra. Mas também o direito moral, o direito do autor, de imagem, à honra e à privacidade, à intimidade. Esses três direitos não foram incluídos como direitos fundamentais, direitos de personalidade à toa. Eles foram incluídos porque se verificou que existiria realmente bens que deveriam ser, pela sua natureza, intransmissíveis e inalienáveis. Qualquer documento, qualquer papel, qualquer ato que essa pessoa fizesse não implicaria em limitação, em mitigação desses direitos, pela importância, pela relevância dela. E a nossa Constituição vigente, ela não olvidou disso. Tanto que o artigo 1º fala em dignidade humana. E, numa cláusula pétrea, já que vamos falar especificamente aí de questão de direito de imagem, de vida privada e direito à honra, os três estão reunidos no artigo 5º, X, da Constituição Federal.

Então, se a dignidade humana já abre como primeiro, como um princípio fundamental na Constituição Federal, o artigo 10, ele diz, em cláusulas pétreas, como o artigo 5º, são garantias de direitos fundamentais, ela diz que, então, o direito à honra, à imagem e à vida privada são direitos a serem preservados.

E o que seria, aí, o direito de imagem, que mais até ao direito, ao que foi falado, da intimidade ou vida privada, ou mesmo é... O direito da imagem também envolve muito o direito à honra. Até por isso que eles estão colocados no mesmo mandamento constitucional, por que a imagem seria importante nesse caso

concreto? E o que seria, afinal, o direito de imagem? Direito de imagem tem basicamente duas vertentes: é a vertente a tributo e a vertente a retrato. A vertente a tributo é também chamada *lato sensu*, porque a imagem, como a pessoa se coloca no meio social. E a imagem retrato, ela é mais fixada na fisionomia da pessoa, normalmente o rosto ou características que a individualizam como pessoa. Então, dentro dessas duas vertentes, pelo que eu pesquisei, é que está sendo discutida essa questão. A questão da utilização da imagem a tributo, que, aí, basicamente, é o nome da pessoa; o nome da pessoa traz justamente essa imagem *lato sensu*, e as características pessoais, fisionômicas da pessoa, que mostram quem era a pessoa, que marcam aquela pessoa na sociedade. Esses direitos da personalidade é que estão sendo relevantes, como também o direito à vida privada, que eu mencionei, mas, basicamente, esse que eu gostaria de comentar.

Qual é a limitação desse direito de imagem? Esse direito de imagem ele é absoluto? Não, ele tem limitações. Qual é a limitação? A limitação é quando existe... isso vem da pessoa dizendo: "Olha, eu estou limitando o meu direito de imagem". Como ela diz isso? Quando ela assume uma função pública. Quando a pessoa sai da esfera da vida privada e assume uma função pública, ela já está naturalmente mitigando esse direito de imagem. Então, essa é uma forma, a forma considerada não expressa. E a forma expressa é quando ela autoriza, às vezes até numa questão, às vezes, uma pessoa que trabalha com publicidade autoriza

utilização da imagem dela num determinado... Então, essas duas possibilidades são possibilidades válidas para que o direito de imagem, então, possa sair, então, dessa órbita da vida privada e vai para ser autorizado.

Aí, também tem caso, por exemplo, e numa, vamos dizer, num ambiente como este, uma fotografia que é também exposta etc., não é? Quem vem a um evento público ou se acompanha uma personalidade pública, também indiretamente, ela está saindo da sua vida privada, do seu direito à imagem *stricto sensu*, está, de alguma forma, permitindo, que, num determinado contexto, e um contexto que deve ter razoabilidade, que aquela sua imagem seja divulgada, pelo menos, da forma em que está participando de eventos.

Então, existem realmente algumas atenuantes em relação ao direito de imagem. E uma delas é justamente quando há o interesse público, que é o caso efetivo. O interesse público ou do público, como falam, etc., de qualquer forma, o interesse da comunidade. Aí, então, nós temos as colidências constitucionais, que foram muito bem abordadas aqui, que é o artigo 5º, X, um direito da personalidade, honra, imagem e vida privada; e o artigo 5º, IX, a liberdade de expressão intelectual, artística e científica, e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, aqui é que nós temos, segundo o meu entender, a colidência constitucional, mais do que, talvez, o acesso à informação, que acredito que seja mais específico; aquela pessoa que precisa de

uma informação pessoal importante para sua vida ou pesquisa acadêmica, o que for. Na verdade, eu acredito que a colidência seja entre dois incisos.

Os relatos de fato são habitualmente garantidos pela regra da Constituição da liberdade de expressão. No plano intelectual, artístico ou científico, em que hipóteses? Nas hipóteses de relatos históricos, registros de acontecimentos, resenhas, crônicas e críticas jornalísticas e biografias, até como foi decidido. No plano das comunicações, basicamente, o noticiário de atualidades, pela imprensa. Esse é o sentido principal e imediato da comunicação.

Excluem-se dessa limitação - e, aí, por norma infraconstuticional mais relevante, que é o Código Civil do Miguel Reale, atualmente vigente - o artigo 18 do Código Civil, que diz que exclui disso a propaganda comercial - quando for propaganda comercial, está excluindo -, quando atingir a honra, a boa fama ou respeitabilidade civil, nesse caso, que extrapole o âmbito dos atos criticáveis praticados pelo titular e se destinarem a fins comerciais, que é o artigo 20.

Como que isso, vamos dizer, uma pessoa que, como eu falei, ela, na verdade, autorizou, implicitamente, a utilização da sua imagem, porque é uma pessoa pública. Vamos imaginar, por exemplo, o Presidente Fernando Henrique Cardoso - é uma pessoa pública, a imagem dele, na verdade, está indiretamente autorizada. Agora, pode-se pegar o Presidente Fernando Henrique Cardoso e colocá-lo num comercial, por exemplo, de um sabonete? Não pode, porque há

limites nessa autorização, e ela não pode abranger fins de propaganda comercial, por mais que a pessoa, indiretamente, tenha autorizado a difusão dessa imagem. Há limites.

A honra, a boa fama e a respeitabilidade podem ser atingidas sem que haja, claro, um fato que seja apurável, mas simplesmente algo que implique esse desabono? Também não, é regra do Código Civil. E também para fins comerciais. Podem pegá-lo, por exemplo, e usá-lo para fins comerciais mais diretos. É claro que a imprensa, normalmente, tem fins comerciais, mas a imprensa está num outro patamar. Na verdade, esses fins comerciais, segundo eu entendo, são os que não sejam basicamente aqueles que pertencem à imprensa em geral - no caso daquela autorização indireta da personalidade pública, não no caso, claro, de alguém que não tenha dado autorização indireta nenhuma. E para isso aí serve essa aplicação do Código Civil.

Então, a questão que eu vejo que é de máxima relevância é: até quando a inexorabilidade de fatos justifica o prevalecimento da liberdade de expressão aos direitos de personalidade? Existe um tempo? Porque, vamos dizer, a difusão dos veículos de comunicação, como disseram, é regra constitucional, mas eles estão marcados no tempo ou eles podem, *ad perpetuam*, estabelecer que essa liberdade de expressão da comunicação vai prevalecer ao direito de personalidade,

de imagem, de honra do titular desse direito de personalidade? Ele tem um tempo ou ele é perpétuo? Essa é a questão que está sendo debatida.

Então, uma questão muito importante, que é muito simples para que nós comecemos a falar sobre isso: o direito ao esquecimento é relacionado à pessoa, não aos fatos; o direito de personalidade é da pessoa, não dos fatos. Ninguém pode alterar os fatos. Os fatos existem e, de alguma forma, eles são divulgados, ou não. O que interessa é esquecimento em relação à pessoa; a pessoa que quer ser esquecida. Os fatos, ela sabe que são inexoráveis. Não é possível esquecer fatos. Então, esse é o temperamento, no meu entender, que deve ser importante.

Primeiro: o tempo decorrido, e o tempo decorrido, acredito que tem que ser, para uma vítima, um tempo inferior ao que é dado ao criminoso em si. Se o criminoso em si, quando ele cumpre a sua pena até o final, a partir daí, ele merece ter de volta os seus direitos de personalidade, quer dizer, além da liberdade que é, então, reconferida pelo Estado àquele que cumpre a pena, ele tem direito a recuperar também os demais direitos de personalidade dele - que é o direito à honra, à imagem. Ele tem esse direito de recuperar. Então, o direito de esquecimento pode ter esse enfoque de recuperação de um direito de personalidade que, temporariamente, lhe foi retirado. Pode ter esse enfoque. E esse enfoque pode ser muito bem-alicerçado nos elementos constitucionais que foram falados.

Em relação àquele que é então inocentado de um inquérito - isso, é claro, quando esse, vamos dizer, decreto de inocência é ocorrido -, a partir daí, já é devolvido os direitos de imagem dele, de personalidade. Ele era uma pessoa pública por causa daquele evento. Uma vez que aquele evento deixa de existir, aquela justificativa, não existe mais essa autorização indireta para que a imagem dele seja utilizada, sem que haja elementos de autorização.

Então, nesse sentido, nós teríamos a restauração dos direitos da personalidade de uma forma completa àquele que paga pela sua pena para a sociedade. Se lhe devolvem a liberdade - que é um dos maiores direitos -, imagina que, também, os direitos de personalidade devem ser devolvidos.

E, se é feito isso ao acusado à pena, quanto mais a vítima. A vítima, pelo caso concreto - pelo que eu pude aferir - foi exposta, o seu nome e a sua imagem foram transmitidos num noticiário, que não era sequer um documentário, com cores vivas de sensacionalismo -, pelo menos, é isso, se eu estiver errado, mas é isso que eu entendi pelos autos. Quer dizer, então, a vítima não tem mais o seu direito da imagem. Pode-se falar: "Bem, se ela não teve isso reconhecido na época é porque tinha o direito de comunicação do momento daquilo que estava acontecendo, muito forte, e aquilo acabou, realmente, extravasando qualquer possibilidade de controle de direito de imagem; até o interesse público, naquele momento, era muito mais evidente.

Mas, com o passar do tempo, não é justo que se recobre a alguém os direitos da personalidade? Os direitos da personalidade não têm essa relevância de prioritários em relação a quaisquer elementos que possam vir do Estado, ou de comunidades, ou mesmo de imprensa? Quer dizer, o direito de personalidade não pode ser realmente, não existe mais censura prévia - isso foi colocado de maneira firme pela Ministra Cármen Lúcia no seu relatório, nas biografias. Não existe a censura prévia, mas, no momento em que aquilo é publicado, e aquilo insere, agrava, tem ilícitos praticados, esses ilícitos têm que ser reconhecidos pelo Judiciário.

Então, Excelência, desculpe-me, passei do tempo?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Podemos ouvi mais um pouco Vossa Senhoria.

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS COSTA NETTO (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO) - Excelência, algo que é muito importante. Vossa Excelência como magistrado, e eu, há algum tempo, também, é interessante ver como isso pode ser também abordado pelo Judiciário de uma forma que hoje a jurisprudência tem feito, realmente, precedentes que nos inspiram.

E realmente me inspirou muito um precedente do Ministro Salomão do STJ. No mesmo dia em que deu essa decisão, 28 de maio de 2013, sobre

Aída Curi, ele deu também sobre o caso da Candelária. Eu vou me permitir ler só o final da ementa da Candelária, que parece que nós estamos falando deste caso, mas estamos falando na Candelária. No mesmo dia, Sua Excelência, deu um relatório a favor do direito esquecimento e, no mesmo dia, contra. Então, o contra, todos sabemos, está nos autos. Eu gostaria de ler o a favor, que foi justamente o caso da Candelária. Vou pedir a paciência de vocês para a leitura disso e, aí, eu encerro imediatamente. Então, Sua Excelência, Luís Felipe Salomão, do STJ, diz, em sua ementa do caso da Candelária - que até quem quiser anotar é o REsp nº 1.334.097/RJ. Ele diz:

> "O interesse público que orbita o fenômeno criminal tende a desaparecer na medida em que também se esgota a resposta penal conferida ao fato criminoso, a qual, certamente, encontra seu último suspiro, com a extinção da pena ou com a absolvição, ambas consumadas irreversivelmente. E é nesse interregno temporal que se perfaz também a vida útil da informação criminal, ou seja, enquanto durar a causa que a legitimava. Após essa vida útil da informação seu uso só pode ambicionar, ou um interesse histórico, ou uma pretensão subalterna, estigmatizante, tendente a perpetuar no tempo as misérias humanas."

Prossegue Sua Excelência:

> "Ressalvam-se do direito ao esquecimento os fatos genuinamente históricos - historicidade essa que deve ser analisada em concreto -, cujo interesse público e social deve sobreviver à passagem do tempo, desde que a narrativa desvinculada dos envolvidos se fizer impraticável." Olha que interessante: "desde que a narrativa desvinculada dos envolvidos se fizer impraticável".
>
> "No caso concreto, a despeito de a Chacina da Candelária ter se tornado - com muita razão - um fato histórico, que expôs as chagas do País ao mundo, tornando-se símbolo da precária proteção estatal conferida aos direitos humanos da criança e do adolescente em situação de risco, o certo é que a fatídica história seria bem contada e

> de forma fidedigna sem que para isso a imagem e o nome do autor precisassem ser expostos em rede nacional. Nem a liberdade de imprensa seria tolhida, nem a honra do autor seria maculada, caso se ocultassem o nome e a fisionomia do recorrido, ponderação de valores que, no caso, seria a melhor solução ao conflito. ”

Ou seja, aqui é justamente os direitos de imagem, do nome e da fisionomia. É isso que está, segundo o meu entendimento, em discussão. Mais que discutir fundamentos do direito de esquecimento - que foram muito bem-colocados -, é como preservar, pelo menos um pouco, a vítima desses acontecimentos, que realmente são irrefutáveis. Eles aconteceram, ninguém vai apagar. Mas como minorar um pouco esse sofrimento? Seria exatamente pela omissão do nome e da fisionomia, que são os direitos de imagem, que são direitos da personalidade, que mereciam ser (ininteligível). Então, finalizando, o direito ao esquecimento é da pessoa e não dos fatos.

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Desembargador, Vossa Excelência trouxe essa abordagem bastante interessante e, ao fim, ao mencionar essas decisões do Ministro Luís Felipe Salomão - e, aí, vai me levar a uma pergunta de opinião a Vossa Excelência, de magistrado para magistrado, porque, pelo que eu li no relatório inicial e pela menção à ementa do STJ, o Ministro Luís Felipe Salomão reconheceu a existência do direito ao

esquecimento e, na casuística, entendeu não aplicável. A Professora Cíntia, que falou agora há pouco, inclusive, citou o parecer do Procurador-Geral da República que, depois, terá a oportunidade novamente de se manifestar e, evidentemente, alterar ou não o posicionamento. Realmente, como está na ementa que li, à qual a Professora Cíntia foi fiel, a opinião da Procuradoria foi no sentido de não se estabelecer no Supremo uma linha de decisão que fosse geral, de modo que esses casos fossem olhados casuisticamente, de acordo com a realidade de cada caso concreto.

Já Vossa Excelência, pelo que depreendi do início de sua fala, ao dizer da importância de o caso estar em repercussão geral, vai na linha da necessidade de se dar um direcionamento mais geral, seria isso?

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS COSTA NETTO (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO) - Sem dúvida, porque, na verdade, como eu me manifestei, a questão é voltada ao direito do esquecimento, mas ela também é indireta e muito importante na fixação que se começou no caso das biografias; eu acredito que pode ser até mais aprofundado agora nesse caso, a que ponto o direito de imagem, tanto de baixo atributo, que seria o nome, aquelas coisas que identificam a pessoa no contexto social, e a imagem retrato que seria basicamente (ininteligível), ou seja, o direito de imagem *lato sensu*, qual é o círculo, qual é o círculo de prevalência que tem em relação a tudo a que existe? E tudo que

existe são geralmente fatos que tiram aquilo da autonomia privada, que são, quando eu falei, a pessoa assume uma responsabilidade pública, vira uma pessoa pública, então, ela automaticamente está também abrindo mão do direito de imagem. Mas até que ponto? Nós vimos, por exemplo, que no caso de comerciais de atividade publicitária, não chega a esse ponto, mesmo que a pessoa seja pública. E hoje acredito que isso tem uma relevância fundamental por isso que acontece dia a dia na imprensa, etc. Até que ponto aqueles direitos de personalidade, e, nesse caso do inciso X da Constituição, até que ponto esse direito prevalece em relação a todos os bens, que foram muito bem definidos aqui?

Então, se há a necessidade de preservação do fato histórico por um lado, há a possibilidade de que aquilo não invada dessa forma, de totalmente tirar todo o contexto do direito personalidade. Até que ponto esse equilíbrio deve ser feito?

Então, no meu sentido, isso está até extrapola a questão dos autos para ser uma questão fundamental de repercussão, no meu entender.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço ao Desembargador José Carlos Costa Netto.

E só divirjo de Vossa Excelência quando iniciou a fala dizendo, com muita humildade - que é uma grande virtude -, que não seria um especialista

no tema, e que não teria muito a contribuir. E contribuiu, penso, muito, como todos estão fazendo.

Agora teremos o último expositor da parte da manhã, a honrosa presença do Prof. Dr. Renato Opice Blum, advogado e economista, mestre pela Florida Christian University, professor coordenador do Curso de Direito Digital do INSPER, MBA em Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito.

Também Vossa Excelência, que está falando pelo INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, disporá de 15 minutos.

O PROFESSOR RENATO OPICE BLUM (INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA - INSPER) - Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, Senhor Subprocurador-Geral Odim Brandão, Excelência Senhor Juiz Richard Kim, Senhora Secretária Doutora Ravena Siqueira, bom dia a todos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão à distância, quero cumprimentar todos pelas excelentes apresentações e cumprimentar, em nome de Vossas Excelências, este Supremo Tribunal Federal pela vanguarda, seja pelas discussões da semana passada do bloqueio do WhatsApp, hoje, nesta discussão envolvendo - vou colocar em aspas - "o chamado direito ao esquecimento", que, para alguns, no direito Norte-Americano, *The Right to Oblivion*, ou *Derecho de ser ouvido*, em espanhol.

Eu vou procurar contextualizar a excelente apresentação do Desembargador Costa Netto no nosso dia a dia. Hoje, a primeira coisa que nós

fazemos quando desejamos obter mais informações sobre alguma coisa é usar uma aplicação, que é o termo técnico hoje, chamada buscador. O mais comum, o mais usado, o melhor é o Google. E, aí, eu questiono e coloco a seguinte questão, o seguinte ponto: as informações que nós procuramos nesses buscadores, as informações recebidas, fornecidas por eles, são informações que definirão a nossa percepção? Eu quero contextualizar a sua excelente colocação Desembargador com relação à vinculação à pessoa, e eu quero vincular ao contexto.

Hoje, nós temos algo que potencializa, que foi objeto da decisão do Tribunal Europeu, a repercussão, e, muitas vezes, dificulta a percepção. Na prática é mais ou menos o seguinte: alguém que seja condenado em primeiro grau, se aquela condenação gera uma notícia, a notícia vai para a internet; na hipótese d ele apelar e ser absolvido, provavelmente a chance na busca do recebimento da informação indexada vai ser da condenação, e não absolvição. E, aí, eu coloco o seguinte questionamento para colaborar, ilustrar, e por que não também apimentar um pouco: isso seria justo? Essa percepção equivocada pela maioria das pessoas, isto seria justo, seria equilibrado?

Ministro Dias Toffoli, inclusive, na segunda-feira, eu procurei mencionar muito a palavra equilíbrio - proporção, percepção, equilíbrio, contexto, evolução tecnológica, e a dificuldade de compreensão do ambiente digital.

Muitos falam, inclusive, que hoje o que comanda o nosso dia a dia, especialmente na internet, são os algoritmos.

Falamos, no início, das *fake news*, das notícias falsas, inclusive, hoje também é o assunto do momento nas eleições norte-americanas, os softwares, os algoritmos podem provocar um acúmulo, um excesso, um verdadeiro enxame de notícias, a princípio, com a conotação verdadeira, mais que podem não ser tão verdadeiras assim. Isso é ruim para todos, sem exceção, para os órgãos jornalísticos, para os buscadores, para as aplicações, para os tribunais, para sociedade, que, muitas, vezes vai até questionar e vai se perguntar: isso que eu estou vendo, que eu estou buscando é verdade ou é mentira?

Cito aqui, Ministro Dias Toffoli, um precedente do Tribunal de Justiça do Paraná, um caso que aconteceu exatamente esta questão: o sujeito foi absolvido em primeiro grau; recorreu; reformou a sentença; e, na busca, aparecia apenas a condenação. O Tribunal de Justiça do Paraná deu duas ordens. A primeira ordem: a atualização daquela notícia; e, nesse caso, aliás, naquele caso, era possível se identificar a fonte. E, muitas vezes, isso não é possível. No caso europeu, também isso era possível. A segunda ordem: a chamada reindexaçao, citada brilhantemente aqui para Cíntia; a questão da veracidade - o Gustavo colocou também muito bem essa questão.

Então, o ponto que eu quero frisar é: a veracidade; o equilíbrio; o resultado; o contexto tecnológico atual; e, acima de tudo, parafraseando um pouco o Tribunal Europeu, essa notícia, essa informação, e aqui não se discute limitação à liberdade de informar, de forma alguma - até porque eu não vejo possibilidades técnicas e legais para isso neste momento -, mas se discute em como se equilibrar esses resultados, essas informações, seja no contexto da veracidade, no contexto do propósito, e no contexto geral, global do propósito da veiculação daquela informação.

Quando a gente fala em direito ao esquecimento, quando a doutrina fala em direito ao esquecimento, eu não posso deixar de citar aqui o Enunciado nº 531 do Conselho da Justiça Federal, que, taxativamente, diz o seguinte: os danos provocados pelas novas tecnologias - que é onde eu quero frisar - vêm-se acumulando nos dias atuais.

O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das condenações criminais - é o 202 da Lei de Execuções Penais, para dar mais uma chance àquela pessoa condenada. Mas aqui vem a parte final que é relevante: não atribui a ninguém o direito de apagar fatos - não se discute isso -, ou reescrever a própria história - também não se discute isso -, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado a fatos pretéritos, mais especificamente ao modo e à finalidade que são lembrados. E, forçando um pouquinho, uma coisa é remoção de

conteúdo, ou de conteúdos ilegais - Doutora Taís citou essa questão eleitoral, que realmente é muito intensa. Outra questão, estamos falando aqui em indenizações em virtudes de um novo contexto, o que seria, citando o que o Guilherme Martins, Promotor no Rio de Janeiro, que tratou do Enunciado nº 531, o "reaquecimento" de algo que, em tese, já estaria na terceira, quarta, quinta página do Google. A gente questiona: "O que que nós lemos?" Primeira e segunda página, quando muito. Muita gente até brinca e fala: "Direito ao Esquecimento, você joga lá para quinta, sexta, e ninguém mais verifica, ninguém mais acessa".

E o interessante é que, no caso da decisão do Tribunal Europeu, que tratou da reindexação do Google, ele manteve, Ministro Dias Toffoli, a circulação original no *La Vanguardia.* O que houve, a nova interpretação, foi essa mudança na forma pela qual a informação era colocada, em virtude do propósito, da desatualização e também do interesse. E por que não do interesse?

Cito também o artigo 11 do nosso Código Civil, que trata, de forma bem pontual, a questão da proteção, dos direitos da personalidade que não podem sofrer restrições voluntárias. Eu citei isso na segunda-feira, reforço aqui novamente, a questão dessa aceitação nossa diária desses termos de uso que nós não lemos. Há uma vedação às restrições voluntárias no nosso Código Civil, artigo 11.

E para chegar ao final, tratando desse trinômio, finalidade vs. interesses vs. licitude, que não tem absolutamente nada a ver com nenhum tipo de censura, nem restrição à liberdade de informar, eu peço vênia para citar Leonardo Parentoni - só um pedacinho do Leonardo, até porque já havia colocado aqui a mesma citação do Desembargador Costa Netto, para não ser repetitivo. Ele falando da decisão do Tribunal Europeu - Ministro Dias Toffoli, eu gosto muito dos precedentes europeus, principalmente pelo tratamento do Regulamento nº 679, tratamento pelo qual a União Europeia vem dando essas questões: O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu: 1- Que o Direito ao Esquecimento pode ser exercido contra motores de busca a internet, e não apenas contra a fonte, contexto; 2 - Esse direito alcança não apenas dados falsos, equivocados ou obtidos ilicitamente, mas também os lícitos e verdadeiros; 3 - Para que se justifique a remoção forçada, não é preciso provar prejuízo concreto, bastando demonstrar o constrangimento ao sujeito envolvido em decorrência da manutenção de dados, além do chamado prazo razoável; e 4 - A remoção forçada dos dados não é cabível caso exista interesse público - sem dúvida - que justifique a sua preservação. E, para encerrar, quando ele fala da busca: por isso foi indeferida a primeira parte do pedido dirigida contra o jornal *La Vanguardia*, porém, a fim de evitar o acesso generalizado a esses dados, fora do contexto a que se refere, o Tribunal acolheu a segunda parte do pedido contra o Google.

Reforçando, então, o precedente do nosso Superior Tribunal de Justiça, em que o Ministro Salomão disse - e aqui ele não fala explicitamente "Direito ao Esquecimento": "As pessoas têm o direito de serem esquecidas pela opinião pública e até pela imprensa" - mas não explicitamente. "Os atos que praticaram no passado distante não podem ecoar...", talvez voltar, reaquecer, ou serem reaquecidos, como se fossem punições eternas.

Uma matéria recente do Estado de São Paulo trouxe essa manchete, esse título: "TJs acatam 1/3 dos recursos por direito ao esquecimento". Gostaria aqui de reforçar um ponto: não é necessariamente o direito ao esquecimento, nós temos questões envolvendo conteúdos nitidamente legais, temos pornografia infantil, violação de direitos autorais e outras questões tão relevantes.

Esse material vai ficar aquim, à disposição. Estou só aqui citando o Regulamento nº 679, antiga Diretiva nº 9.546, que deu origem a toda essa discussão, "*El derecho a ser ouvido*", que está em espanhol; as três hipóteses; um precedente peruano recente, em que uma autoridade administrativa notificou também um buscador numa questão relacionada a uma informação pessoal indevida. E, por fim, aqui para ilustrar alguns casos mais importantes e relevantes

da doutrina, da jurisprudência, da academia sobre essa questão do "Direito ao Esquecimento"

Termino, citando um finalzinho, um pedacinho dessa decisão que eu tanto me reverenciei aqui a respeito da importância dos conteúdos, que inapropriados, irrelevantes, ou não tão relevantes assim, eles podem, em tese, ser removidos, ser objeto desse pedido de remoção por parte dos buscadores. Vejo esse precedente como algo irreversível.

E uma última questão que nós não mencionamos aqui é que existem alguns projetos de lei no Brasil, tentando tratar essa discussão. Eu deixei aqui os principais, para que possamos, pelo menos, registrar o andamento disso e trabalhar para o melhor desfecho possível dessas propostas.

Lembro também que o inciso X do artigo 7º do Marco Civil traz uma reflexão importante com relação à questão da possibilidade que nós temos, o usuário, o consumidor, ou internauta tem de pedir a deleção, a "remoção" - pois o Marco Civil da Internet é lei já em vigor -, quando cessar o propósito que gerou a coleta daquele dado pessoal.

É a terceira vez que eu falo aqui de propósito. Então, quero falar novamente: o propósito é algo extremamente relevante que deve ser sempre considerado.

Com duas referências aos projetos de lei, encerro aqui, trazendo - e sempre trago e faço questão de fazer isso - a oração da serenidade:

> Que Deus nos dê coragem para que nós possamos mudar aquilo que for possível, dentro deste novo contexto legal e fático. Que nós possamos ter a serenidade para aceitar aquilo que não for possível ser alterado, ser mudado. Mas, acima de tudo, a sabedoria para que nós consigamos, pelo menos, chegar próximo ao chamado equilíbrio.

Agradeço novamente ao convite. Cumprimento o Supremo em nome de Vossa Excelência e desejo um excelente debate.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) – Prof. Opice Blum, também gostaria de lhe fazer uma pergunta, diante, inclusive, do próprio quadro que Vossa Excelência trouxe, quanto ao Marco Civil da internet e a essa questão do propósito da divulgação. Nós estamos aqui no âmbito de uma repercussão geral que trata do direito ao esquecimento. Quanto aos conflitos aparentes ou não, isso, depois o Tribunal vai decidir pela douta maioria que vier a se formar no julgamento da causa, em relação ao direito ao esquecimento no Marco Civil - nós estamos no Marco Civil. Vossa Excelência fez referência à internet e aos indexadores, às pesquisas e ao propósito. A pergunta que eu faço se refere ao fato de que, hoje, os grandes órgãos de imprensa escrita, e mesmo os de rádio e televisão, estão digitalizando seus acervos de cem, cinquenta, sessenta anos atrás e os colocando na rede mundial de computadores. Evidentemente, lá se noticiam

crimes, condenações e uma série de acontecimentos que ocorreram em dado momento histórico. Então, eu gostaria de saber de Vossa Excelência, na linha de seu posicionamento, se também caberia a desindexação ou a retirada de algo que está sendo reproduzido na rede mundial de computadores. Nós temos acesso hoje, para fins de pesquisa, a jornais que foram publicados há setenta, cem anos, a revistas, a programas de televisão que foram divulgados há muitos anos.

Eu encerraria com esta pergunta ao Prof. Opice, sem prejuízo de alguém da bancada, desde que todos com o compromisso de serem breves, comentar essa pergunta ou se manifestar. Fiquem à vontade. E assim encerraríamos a parte da manhã.

Por favor, Professor.

O PROFESSOR RENATO OPICE BLUM (INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA - INSPER) - Obrigado pela questão, Ministro Toffoli.

Vou citar, como fiz na segunda-feira, Lawrence Lessig, grande professor de Harvard, que dizia, já em 97, que quem deteria o controle da internet e da informação seriam aqueles que detêm o código, que detêm a programação, que detêm a estrutura como um todo, na realidade o botãozinho, ligar e desligar, "disseminar ou controlar" determinados conteúdos; ele falava isso em 97. Por que é importante fazer essa citação? Eu citei, no início, a questão dessa disseminação

avassaladora de muitos conteúdos, que podem ser ilegais, desatualizados ou até, de uma certa forma, intuitivos ou indutivos, melhor falando.

No exemplo de Vossa Excelência, vou separar em duas situações: uma indexação normal, oportuna, essencial, importantíssima, o registro histórico acessível, dentro até de um conceito de inclusão digital, irreversível, a parte positiva da tecnologia da internet; e a segunda questão, nós podemos ter uma espécie de alteração, uma espécie de impulso indevido em certos conteúdos. Quando digo impulso indevido, hoje através da tecnologia, através de ferramentas específicas, através de *clics* ou de ações específicas, consegue-se regular certos conteúdos, ou indexar melhor certos conteúdos.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Destacá-los.

O PROFESSOR RENATO OPICE BLUM (INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA - INSPER) - Destacá-los, de acordo com a posição no *ranking*, e, dessa forma, trazer mais relevância. Essa seria a segunda possibilidade, quando há uma ação específica diferente do normal.

Nessas circunstâncias, nós efetivamente podemos ter algo um pouco mais sensível, que é a grande dificuldade discutida hoje por parte das aplicações, como separar o que é normal do que decorre de uma ação dolosa, vamos chamar assim. E há uma dificuldade técnica e uma dificuldade legal para isso.

Então, dentro desse contexto hoje, tentando fazer essa separação do conteúdo puro da internet - acho que essa é a palavra - do conteúdo impuro, ou seja, daquele em que há uma ação humana deliberada, na segunda hipótese, parece-me que há um esforço conjunto, comum, de todos os setores em fazer com que a informação seja verídica, pura, e tenha, acima de tudo, credibilidade. Não existe uma resposta no mundo de como resolver isso, a questão legal nasce como uma das possibilidades em se atenuar certas situações dessa natureza, mas não resolver. E acho que não teremos solução efetiva nesse ponto.

Então, separando o conteúdo puro do conteúdo alterado, ou conteúdo forçado, vamos dizer assim, parece-me que a casuística nesse ponto é importante, cada caso terá a sua peculiaridade, vai ter o seu estudo e a sua preocupação. E, aí, não há como dissociar também a questão da parte técnica, da parte pericial e daí por diante.

A discussão do direito ao esquecimento puro na União Europeia ocorreu e ocorre em função da internet, ela veio à tona em função disso. E, dentro da questão formulada por Vossa Excelência, quando eu trago conteúdos físicos contidos em uma biblioteca e coloco isso à disposição do mundo inteiro, através da internet, é aí que muda o potencial; e, quando o potencial é direcionado, aí que nós temos talvez essa discussão do reaquecimento na sua plenitude. Seria mais ou menos essa a dificuldade que nós temos hoje.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Por favor, fiquem à vontade. As mulheres primeiro.

A SENHORA TAÍS BORJA GASPARIAN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO - ABRAJI) - Excelência, só para fazer uma rápida manifestação no sentido, primeiro, que bom que os jornais, as revistas foram digitalizadas. Que bom que nós temos um acesso mais fácil a essas informações, porque estas informações, jornais, revistas, estão arquivadas na Biblioteca Nacional, na Biblioteca Mário de Andrade.

A minha pergunta é a seguinte: se for autorizada, por exemplo, a retirada do registro na internet, nós vamos também determinar que se faça o recolhimento desses exemplares na Biblioteca Nacional, na Biblioteca Mário de Andrade? Vamos lá recortar aquela matéria? Porque não tem efeito essa retirada da internet, mas a manutenção dos arquivos físicos. Eles estarão lá. Não vamos recolher aqueles jornais. Isso em primeiro lugar.

Em segundo lugar, com relação, por exemplo, aos próprios processos que hoje em dia são só digitais. Imaginem se nós formos também retirar esses processos digitais da internet. Porque vai ficar lembrança, você pode ser acesso a processos públicos. Nós vamos não ter mais nenhuma memória desses processos digitais? O apagamento, remoção de arquivo é uma coisa absurda de se fazer numa era que se pretende informativa. Coloca-se todas as alterações que

foram feitas, todas as correções que foram feitas, mas não se pode retirar uma informação.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) – Prof. Gustavo.

O SENHOR GUSTAVO BINENBOJM (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISÃO - ABERT) - Agradeço. Ministro, muito brevemente, é algo que me ocorreu, que não tive tempo de mencionar, a partir da ótima exposição do Professor Renato e desse comentário da Taís.

Em 2012, a Corte de Cassação Italiana julgou uma pretensão de um político italiano que lá, como aqui, pretendia, invocando o direito ao esquecimento, suprimir uma determinada informação sobre um processo criminal a que respondia. Era uma notícia dada pelo jornal "*Corriere della Sera*", e a alegação era de que ele havia sido ulteriormente absolvido. Nessa decisão, a Corte de Cassação da Itália, na decisão posteriormente confirmada pela Corte Constitucional daquele país, decidiu que não havia um direito à supressão nem da matéria do *site* do jornal, nem dos *links* dos provedores de busca, mas, ao contrário - uma velha máxima da Suprema Corte norte-americana -, a solução para os males do discurso, nesse caso para a desatualização, seria a complementação da informação. A solução compromissória da Corte italiana pareceu-me muito interessante na medida em

que não se atendeu ao pleito do demandante para se retirar a matéria do *site*, mas se impôs o dever de atualização para que a informação se tornasse fidedigna àquela realidade.

Então, mais uma vez, o direito ao esquecimento, se fosse atendido o pleito nesse sentido, importaria uma espécie de censura. E ele acabou sendo convolado numa espécie de direito à complementação ou à retificação da informação. Pareceu-me um registro interessante a ser feito.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) – Profª Cíntia também gostaria de falar.

A SENHORA CÍNTIA ROSA PEREIRA DE LIMA (FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) - Sobre essa questão, o julgamento González v. Google entendeu que o direito à desindexação não era oponível às fontes originais. Então, *La Vanguardia* não vai obviamente queimar todo o arquivo que eles possam ter. O direito à desindexação é justamente oponível às ferramentas de busca que realizam o tratamento de dados pessoais.

Então, utilizando-me aqui do raciocínio do Professor de Harvard Jonathan Zittrain, ele fala que este direito à desindexação é para que essas informações não sejam acessadas de maneira trivial e sem essa possibilidade de se opor pelo indivíduo. Então, eu acho que, nesses acervos digitalizados, se tiver, num

caso concreto, novamente essa ponderação, o propósito, e for assim considerado que é um tratamento de dados pessoais, e um indivíduo, então, queira que essa informação não seja de maneira trivial, simplesmente digitando alguns parâmetros na ferramenta de busca, e essa notícia ser retomada, às vezes, desatualizada, porque essas ferramentas não fazem essa revisão qualitativa, ele teria direito. Então, é oponível às ferramentas de busca à indexação, e não aos acervos.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - O Dr. Roberto gostaria de falar; depois, por último, o Desembargador.

O SENHOR ROBERTO ALGRANTI FILHO (ADVOGADO DOS RECORRENTES) - Excelência, existe um fato, que obviamente eu não falei, mas que pontua muito bem o que acontece.

No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, há não muito tempo, aconteceu uma exposição sobre casos célebres, casos judiciais com repercussão e que tiveram alguma relevância. Recebi um telefonema me noticiando isso, conversei com a família, e todos nós concluímos o seguinte: aquilo estava restrito ao Tribunal de Justiça, aquilo estava restrito a pessoas que trabalham, seja academicamente, seja no mister da advocacia ou da magistratura, e que, naquele contexto, a informação tinha seu grau de relevância, tinha seu grau de relevância.

O que a família quis fazer contra isso e qual foi nossa orientação? Fazer nada, fazer nada.

O Doutor Renato colocou na tela uma reportagem, que, se eu não me engano, foi do Estado de São Paulo - não foi? -, com a foto de Aída.

Se me perguntar, poderia ser sem a foto? Eu acho que poderia ser sem a foto, mas também não nos opusemos, não fizemos nada, porque está dentro de um contexto de uma informação relevante sobre o contexto nacional, o que é algo atual.

Então, impositivamente, o direito ao esquecimento, acredito, sim, seja necessária a repercussão geral, mas vai partir sempre de um grande exercício da razoabilidade pelo magistrado diante dos fatos.

O que é necessário é a referência. Até onde vai a legalidade e aonde para a liberdade de expressão? Na ilicitude. Por isso que eu fiz questão de pontuar a questão da saúde.

Mas, insisto, a matéria não pode ser tratada de forma binária: sim ou não, os extremos. Ou tudo é permitido, ou nada é permitido. Não é por aí. Existe uma grande margem entre o sim e o não, entre o zero e o um para se discutir e se aplicar, assim, o direito ao esquecimento.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Desembargador José Carlos Costa.

O SENHOR JOSÉ CARLOS COSTA NETTO (DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO E

ESPECIALISTA EM DIREITO DA PERSONALIDADE) - Senhor Ministro, eu apenas gostaria de lembrar que o direito de personalidade depende da provocação do titular. Então, qualquer questão que o Judiciário venha a decidir é mediante a provocação do titular.

Então, daqueles arquivos, vamos dizer, antigos etc., é claro que haverá muito pouca solicitação de retirada, porque o próprio tempo vai mitigando também. Não é o caso, em si, que estamos aqui discutindo, porque foi algo que foi feito, como bem disse o Doutor Opice Blum, de uma forma de reaquecer, de uma forma muito sensacionalista aqueles fatos, que eram fatos que pesavam muito para as vítimas. Então, nesse sentido, que está sendo analisado.

Agora, em relação às questões dos arquivos etc., nós devemos lembrar que existe regra de proteção a direitos autorais. E, aqui, falando um pouco da minha especialização.

O artigo 31 da Lei vigente diz que a cada nova forma de utilização de obra intelectual demanda uma nova autorização do autor. Então, se o autor deu autorização para o veículo impresso de sair algum artigo seu, vamos dizer, algum trabalho seu numa revista impressa ou num veículo, num jornal etc., aquilo deve ser honrado. Então, o autor deve autorizar.

O que ocorre na área jornalística é que os artigos normalmente veiculados pela imprensa, eles não necessitam autorização. Mas aqueles assinados,

eles pertencem - é o artigo 36 da Lei - ao autor a partir de vinte dias, a partir da periodicidade do veículo. Então, depois de vinte dias, os direitos são recobrados pelo autor.

Então, esses arquivos que circulam, precisa primeiro verificar se eles têm violação de direito autoral ou não. E, aí, o direito autoral tem aquela, vamos dizer, norma de interesse público, que não é um direito permanente. Ele não dura *ad aeternum.* O direito de autor, as obras protegidas caem em domínio público setenta anos a partir da morte do autor.

Então, se esses arquivos, mesmo aí, aí os artigos até assinados e as obras protegidas de direito de autor, já ultrapassaram o prazo legal da proteção dos seus autores, esses arquivos realmente podem circular. Agora, se for um arquivo, ou seja, se for uma utilização vedada pela proteção, pela Lei de Direitos Autorais, aí ela demanda uma autorização do direito de autor.

Era essa a consideração.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Findas as exposições da parte da manhã, agradeço a presença do Subprocurador-Geral da República Dr. Odim Brandão, Senhora Secretária, do Juiz Richard Pae Kim, de meus assessores e em especial dos Expositores: Dr. Roberto, Dr. Gustavo, Drª Taís, Dr. Daniel, Prof. Cíntia, Desembargador José Carlos Costa e Dr. Opice Blum.

Convido a todos para, se puderem, ficar e acompanhar os demais expositores, na parte da tarde. Agradeço a presença de todos.

Como nós avançamos um pouco no horário, e muitos têm que sair para almoçar, se deslocar para fora - não há aqui locais próximos para o almoço -, retomaremos a audiência às 14h15m, ao invés de iniciarmos às 14h, em razão do avanço que tivemos na parte da manhã.

Penso que foi extremamente produtivo o debate.

Muito obrigado a todos!

SEGUNDA PARTE

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) – Boa tarde a todos! Podemos nos sentar. Vamos retomar os trabalhos dessa audiência pública convocada no âmbito do RE 1.010.606/RJ. Em razão de necessidades de voo por parte de alguns expositores, o cerimonial alterou a ordem, para podermos ouvir todos.

Dando sequência à audiência pública, passo a palavra ao Prof. Dr. Anderson Schreiber, em nome do Instituto Brasileiro de Direito Civil (IBDCivil). O expositor é professor de Direito Civil e professor permanente do Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* da Universidade Estadual do Rio de

Janeiro. Possui doutorado em Direito Privado Comparado pela Università Degli Studi Del Molise, na Itália. Vossa Senhoria também dispõe de quinze minutos para sua exposição.

PROFESSOR DOUTOR ANDERSON SCHREIBER (INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL - IBDCIVIL) - Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral da República, Odim Brandão, demais autoridades presentes, meus caros colegas expositores, é um prazer estar neste Supremo Tribunal Federal, representando o Instituto Brasileiro de Direito Civil, uma instituição que tem com o tema desta audiência pública uma relação exclusivamente acadêmica, não representando qualquer das partes, nem qualquer interessado no resultado desse julgamento.

Muito já foi dito aqui, ao longo da manhã, sobre o direito ao esquecimento, mas eu me permito fazer alguns contrapontos que parecem relevantes.

Primeiro, é importante registrar que o direito ao esquecimento é reconhecido em diversos países da Europa continental como desdobramento do direito fundamental à privacidade. É nesse sentido que se fala na Itália em *diritto all'oblio*; na França, em *droit a l'oublie;* e assim, sucessivamente. Nesses países europeus, a noção técnica de direito ao esquecimento corresponde a um direito a não ser perseguido pelos fatos do passado que já não mais refletem a identidade

atual daquela pessoa. Trata-se, assim, essencialmente, de um direito contra uma recordação opressiva dos fatos pretéritos que projete o ser humano, na esfera pública, de forma equivocada, porque não atual, impedindo-o de ser reconhecido pelo público como quem realmente é.

Não se trata, portanto, de um direito a serviço do ocultamento ou da mentira, mas, sim, da verdade. Não se trata de um direito contra a história, mas de um direito a favor da história completa que não apresente o ser humano apenas por meio de um rótulo do passado, o qual não mais corresponde à realidade.

Esse direito da pessoa humana se exerce, quer em face do Estado, quer em face dos sujeitos privados. Exerce-se diante de qualquer entidade que tem a capacidade de efetuar uma projeção da pessoa sobre o espaço público. Tão se aplica, portanto, não apenas no âmbito do direito público, mas também no campo do direito privado.

O exemplo muito claro é o da pessoa transexual. Tendo mudado de sexo, aquela pessoa não deve mais ser apresentada, quer pelo Estado, em repartições públicas, quer pela mídia privada, em reportagens ou entrevistas, como alguém que nasceu homem e se tornou mulher, ou vice-versa, porque, se esse rótulo for constantemente relembrado, se esse fato do passado, embora verdadeiro e público, for constantemente recordado, a sua apresentação à sociedade será

sempre uma apresentação deturpada, que dará excessivo peso a um fato do passado, obscurecendo a sua identidade presente.

O direito ao esquecimento não é, portanto, um direito de apagar os fatos ou de reescrever a história, porém, um direito de que a exposição pública da pessoa humana seja sempre feita de modo contextualizado, e que o seu passado não seja transformado no seu presente sem uma forte justificativa. Trata-se não de um direito contra a liberdade, como chegou a ser sugerido aqui na parte da manhã, mas de um direito indispensável a assegurar a liberdade de todo ser humano de seguir o seu próprio caminho ao longo da vida, sendo visto pela sociedade como quem realmente é.

Isso não quer dizer - isso não quer dizer - que o direito ao esquecimento deva ser um direito guiado pelo capricho ou pela vontade do retratado. É nesse ponto que reside, talvez, a maior dificuldade do estudo dessa matéria no Brasil.

O direito ao esquecimento ganhou entre nós um significado peculiar e bastante distinto do significado europeu original, especialmente quando o nosso Superior Tribunal de Justiça, julgando o conhecido caso já citado aqui na parte da manhã, caso da chacina da Candelária, em 2013, reconheceu a existência de um direito ao esquecimento, que definiu como "um direito de não ser lembrado contra a sua vontade".

Entendido dessa forma, o direito ao esquecimento torna-se um verdadeiro direito de propriedade sobre acontecimentos pretéritos. A recordação pública dos fatos acaba dependendo de o mero querer da pessoa envolvida, o que é flagrantemente incompatível com a nossa Constituição, que, como sabemos, tutela, entre seus direitos fundamentais, não só a privacidade, mas também a liberdade de informação e o direito de acesso da população à informação. Nossa ordem jurídica, em uma expressão, não tolera proprietários de passado.

Essa versão voluntarista do direito ao esquecimento representa também uma ameaça à pesquisa histórica e especialmente à pesquisa na internet, porque acaba por resultar na possibilidade de qualquer usuário de moldar, de acordo com a sua vontade, os resultados relativos à busca do seu nome a fatos públicos no qual se envolveu, o que nos levaria, em última análise, a uma internet de cada um.

Entretanto, o caminho para impedir esse cenário sombrio - eu insisto - não é abolir o direito ao esquecimento na esfera privada, mas sim aplicá-lo de forma criteriosa, atentando não para a vontade do sujeito retratado, não para o que ele quer ou não quer que venha a público, mas sim para a situação objetiva a qual revele que aquela projeção específica do ser humano na esfera pública, com base em uma condição pretérita, efetivamente compromete ou impede a realização da sua personalidade no momento atual.

Isso acontece em hipóteses raras, não frequentes, mas acontece. Uma dessas hipóteses é justamente a dos programas televisivos de relatos ou encenações de crimes históricos envolvendo pessoas ainda vivas. Frequentes em diversos países do mundo, esses programas desempenham uma função híbrida, informativa, histórica e de entretenimento intelectual.

Não se pode cogitar, obviamente, de suprimir a liberdade das emissoras de TV de realizarem tais espécies de programa. De outro lado, não se pode cogitar de suprimir o direito da personalidade das pessoas, ainda vivas, envolvidas na naqueles crimes. A recordação pública de tais crimes revive naturalmente perante a sociedade à condição de criminoso ou de vítima atribuída aos envolvidos na época do fato.

Isso é certo que a reapresentação de uma pessoa na condição de criminoso impõe uma pecha ao indivíduo, também é certo que a sua representação, na condição de vítima, impõe igualmente um rótulo parcial e redutor que, não raro, expõe a pessoa a sentimentos de vergonha ou embaraço, não sendo por outra razão que toda a legislação brasileira mais recente se preocupa em preservar a identidade de vítimas de crime, especialmente de crimes sexuais.

Daí a necessidade de se aplicar, tecnicamente, o método da ponderação, buscando menor sacrifício possível para ambos os interesses protegidos pela ordem jurídica brasileira.

Já é possível, na doutrina nacional e estrangeira, colher diversos critérios ou parâmetros técnicos que devem ser seguidos na análise dessa hipótese.

O tempo é curto para examinar todos esses critérios, mas há alguns que merecem destaque.

O primeiro critério, critério da relevância histórica do fato, segundo qual o intérprete deve se perguntar se o crime retratado constitui crime de efetiva importância histórica, cuja repercussão a seu tempo ou suas consequências para a sociedade justificam sua reapresentação pública, mesmo com risco de abalo à identidade de pessoas ainda vivas. O chamado caso Aída Curi, atualmente sob exame deste Tribunal, representa claramente um crime de importância histórica que não apenas teve vasta divulgação, mas também comoveu a sociedade ao seu tempo.

O dado da importância histórica não basta, todavia, para assegurar a legitimidade da reprodução. Faz-se necessário examinar o modo como crime é reproduzido, o modo como é relatado. Por exemplo, há diversos critérios aí que desempenham algum papel: o intérprete deve se perguntar se, para relatar ou encenar o crime, em toda sua dimensão histórico-informativa, era necessário identificar a vítima e seus familiares; se era necessário detalhar aspectos sensíveis do episódio como a repercussão emocional do crime sobre a vítima ou seus familiares; se era necessário retratar cenas mórbidas, como imagens de cadáveres,

retratos do enterro, do sepultamento daquela pessoa em vida, lápides e assim por diante. São perguntas que cabem ao intérprete analisar no caso da aplicação da técnica da ponderação.

O caso Aída Curi é nesse sentido extremamente difícil - permitam-me voltar a ele. Por um lado, verifica-se que o programa não poderia deixar de identificar a vítima - o caso Aída Curi, não pode ser relatado sem Aída Curi. Por outro lado, o programa não se limitou a relatar o crime, mas descreveu de modo detalhado o sofrimento de Aída, com diálogos dramáticos, imagens fortes, como lançamento do seu corpo do alto do edifício, além de imagens do sepultamento. Também consta do programa cenas de intimidade familiar, como diálogo aflito entre a mãe e o irmão Nelson, e a cena na qual irmão Nelson encontra o cadáver da sua própria irmã na Avenida Atlântica no Rio de Janeiro.

Essa forte retratação do ambiente familiar, no relato televisivo em questão, que permite, no caso concreto, a invocação do direito ao esquecimento pelos familiares da vítima, não apenas em defesa do direito alheio, nos termos dos artigos 12 e 20 do Código Civil, mas também em defesa do direito próprio.

Esse é um aspecto importante. O programa não se limitou ao relato da história, como tanto se disse isso aqui ao longo da manhã, mas relatou também o ambiente familiar e íntimo, o impacto desse crime sobre a esfera íntima

da família da vítima. E esse é um aspecto importante que deve ser levado em conta no juízo de ponderação.

Mais um exemplo de critério relevante, sob o ponto de vista científico, é o da fama prévia, segundo o qual se deve verificar se a vítima em questão ou os seus familiares possuem outras projeções da esfera pública, ou, ao contrário, se se trata de pessoas que somente se tornaram famosos por conta do crime em questão.

Esse critério permite distinguir situações, como o relato do suicídio de Getúlio Vargas ou do assassinato de JFK, de casos em que a pessoa apenas se tornou exposta na esfera pública por conta do crime sofrido.

Também não se pode deixar de considerar que, dentro do tempo, já em sede de exame do nexo de causalidade, essencial ao juízo de reparação civil, pode ter havido, no caso concreto, autoexposição.

O direito ao esquecimento é sempre examinado em contraponto à possibilidade de autoexposição. Ele não pode ser invocado por quem, por ato próprio, projeta aquele acontecimento sobre a esfera pública.

Nossa ordem jurídica tutela o direito à privacidade, à intimidade e à reserva, mas não protege o direito a uma versão única dos fatos, ainda que se trate da versão da própria vítima ou de seus familiares.

O caso Aída Curi também, nesse aspecto, é extremamente delicado, porque um de seus familiares publicou mais de um livro sobre o crime, com sua versão do acontecimento, incluindo fotografias do cadáver da vítima, sendo examinada pelos peritos, bem como fotografias do enterro, além de outros detalhes sobre a vida privada de Aída Curi, muitos dos quais são apenas reproduzidos no programa de TV. Seguramente, essas publicações foram animadas pelos sentimentos mais nobres de expurgação da dor, de enaltecimento da vítima. Porém, mais uma vez, a questão aqui não pode ser a vontade ou a intenção subjetiva dos envolvidos, mas deve ser o fato objetivo de que a discussão pública do crime foi fomentada, de alguma forma, pelo autor das obras, o que impediria teoricamente a invocação do direito ao esquecimento por este ou por esta pessoa.

O tema em discussão, como se vê, é repleto de aspectos que pedem ora a favor da liberdade de informação, ora a favor do direito ao esquecimento.

O sopesamento desses aspectos, de acordo com os vários critérios disponíveis na doutrina, não é obviamente uma tarefa acadêmica, e sim judicial. Mas é importante registrar que o Supremo Tribunal Federal tem, diante de si, uma oportunidade singular de corrigir a definição do direito ao esquecimento, afastando do domínio da mera vontade do retratado, e distrair da ordem jurídica brasileira os critérios que devem, de fato, pautar a tutela da privacidade, da

intimidade, em específico, do direito ao esquecimento na esfera privada em relação aos programas televisivos que relatam crimes reais, envolvendo pessoas ainda vivas.

As vozes contrárias ao direito ao esquecimento muitas vezes argumentam que é necessário atribuir preferência à liberdade de informação, porque, sem isso, haveria uma imprevisibilidade que impediria a realização desses programas.

O argumento não é tecnicamente o melhor. Primeiro, porque o problema da falta de uma previsibilidade absoluta acontece em qualquer hipótese de colisão dos direitos fundamentais, não havendo nenhuma razão para que, nessa situação específica, isso seja obstáculo à aplicação da técnica da ponderação já empregada tantas vezes por esta Suprema Corte. Segundo, porque, ao decidir sobre esse tema, este Supremo Tribunal Federal estará justamente fixando critérios ou parâmetros, de modo a fornecer a cartilha sobre os cuidados que devem ser adotados nessa espécie de programa, como aconteceu em tantos outros países, como, por exemplo, não descrever minúcias da prática de violências sexuais, ou não expor imagens da família em sepultamentos e assim por diante. Vale dizer, os critérios que forem fixados pelo Supremo Tribunal Federal para definir o que prepondera, neste caso concreto, irão se converter em deveres de conduta que, se observados, assegurarão a legitimidade do exercício da liberdade de informação,

suprindo qualquer eventual déficit de previsibilidade. Em terceiro lugar, e ainda que nada disso fosse verdadeiro, o caminho fácil da hierarquização prévia, entre liberdade de informação e privacidade de direito ao esquecimento, simplesmente não é compatível com uma Constituição como a nossa, a qual tutela tanto a liberdade de informação, quanto a privacidade, como direitos fundamentais. Aqui, como em todos os campos da Ciência Jurídica, o caminho intermediário é o melhor trajeto.

Eu uso, Ministro Dias Toffoli, os poucos minutos que me restam para agradecer a Vossa Excelência, ao seu gabinete e ao Supremo Tribunal Federal pela importante iniciativa de convocar esta audiência pública. É muito raro que as posições favoráveis ao direito ao esquecimento, em qualquer medida, tenham espaço nos meios de comunicação, porque há uma natural indisposição a debater esse tema. De modo que a abertura de um espaço privilegiado para se discutir, técnica e cientificamente, essa questão tão relevante é ainda mais oportuna nessa matéria. Falo em o nome de todos os que me antecederam e não tiveram tempo para agradecê-lo, receba o nosso mais genuíno agradecimento em prol da Ciência Jurídica.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço ao doutor Anderson Schreiber.

Convido o Prof. Dr. Marcel Leonardi, bacharel, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo; pós-doutor em Direito pela Berkeley Law; coordenador e professor do curso de Direito Digital Aplicado da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo.

Falará pela Google Internet Brasil Ltda.

O SENHOR MARCEL LEONARDI (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) - Boa tarde a todos!

Excelentíssimo Ministro Toffoli, Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral da República Odim Brandão, demais autoridades. Agradeço em nome da Google Brasil pela oportunidade de falar sobre o suposto direito ao esquecimento.

Pesquiso temas jurídicos ligados à *internet* há vinte anos e trabalho há seis anos na *Google*. Quero oferecer uma visão prática de quem observa os desdobramentos do tema nos tribunais de todo o mundo.

Em minha exposição pretendo abordar três temas principais. O primeiro é que a decisão do caso Costeja, que deu popularidade à expressão "direito ao esquecimento", é problemática, e não serve de paradigma para o Direito brasileiro. O reconhecimento de um direito ao esquecimento no Brasil é, em verdade, absolutamente desnecessário; porque nosso sistema jurídico já oferece os

mecanismos legais necessários para que o Judiciário lide com as colisões entre direitos fundamentais e efetue a imprescindível ponderação, caso a caso.

Meu segundo ponto é que a comunidade jurídica internacional fora da União Europeia rejeita o conceito de um direito ao esquecimento. Considera-o um equívoco, um insulto à memória e à história. Mesmo na Europa, a aplicação desse suposto direito é extremamente controversa e limitada.

E meu terceiro ponto é que o suposto direito ao esquecimento é um nome elegante que, muitas vezes, é utilizado para justificar a censura de conteúdo lícito e de informações verdadeiras. Esse suposto direito, em verdade, apenas servirá de atalho para eliminar o sopesamento entre direitos fundamentais e estabelecer uma preponderância presumida da privacidade de modo genérico, servindo como pretexto para todo pedido de remoção de informações.

Creio ser importante relembrar a origem dessa expressão "direito ao esquecimento" no contexto atual, particularmente aplicada à *internet*. Em 2014, a Corte Europeia de Justiça alargou a interpretação da diretiva europeia sobre proteção de dados pessoais, e determinou que pesquisas efetuadas com o nome de cidadão espanhol Mario Costeja, que direcionassem a notícias antigas sobre um leilão judicial, não poderiam ser exibidas; ainda que a fonte, no caso o acervo *on-line* desse jornal espanhol, continuasse disponível na *web*. Em outras palavras, a Corte Europeia de Justiça entendeu, com fundamento nessa normativa europeia de

proteção de dados - que, diga-se de passagem, não tem equivalente legislativo no Brasil -, que existiria um direito autônomo de um indivíduo em impedir a exibição por mecanismos de busca de resultados de pesquisa contendo o seu nome; direito esse que seria distinto da pretensão, se se remover o conteúdo em si da sua fonte. Ou seja, a informação que se pretende esquecida não é apagada; permanece onde se encontra. Os mecanismos de busca, porém, ficam impedidos de direcionar usuários para essa informação.

É aqui, Ministro Toffoli, que eu queria destacar os tremendos equívocos que essa decisão representa. Por quê? Ela fragmentou elementos indivisíveis que constituem um mesmo direito: o da liberdade de opinião e o de expressão. Tanto a nossa Constituição, em seu art. 5º, inciso XIV, quando assegura a todos o acesso à informação, quanto os tratados internacionais e toda a doutrina jurídica sobre o tema deixam claro que a liberdade de opinião e de expressão engloba buscar, receber e difundir informações e ideias. São elementos interdependentes que constituem um direito indivisível.

Não foi à toa, aliás, que o então Procurador-Geral da União Europeia, em seu parecer expressamente contrário ao reconhecimento de um direito ao esquecimento, nesse mesmo caso Costeja, afirmou que o direito de um usuário de *internet* à informação ficaria comprometido se a busca por informações

a respeito de um indivíduo não gerasse um reflexo verdadeiro das páginas relevantes, mas apenas uma versão pasteurizada como resultado.

Além disso, como se constata, esse suposto direito não configura nenhum esquecimento, ele apenas aumenta a assimetria de acesso a informações e exacerba as diferenças entre quem saberia encontrar o conteúdo diretamente e quem precisa utilizar a busca para encontrá-lo.

O que também causa espanto no caso Costeja é que, apesar de a Corte Europeia de Justiça decidir que a remoção de *links* somente pode ser implementada depois de efetuado o necessário sopesamento entre interesse público e particular, ela também decidiu que esse sopesamento deveria ser feito pelo setor privado, ou seja, pelos próprios mecanismos de busca, e não pelo Poder Judiciário, usurpando a competência do Estado-juiz de decidir, caso a caso, o que é e o que não é conteúdo ilegal.

Então, como se vê, a decisão desse caso Costeja é problemática, não serve de paradigma para o Direito brasileiro, tanto é, Ministro Toffoli, que o Superior Tribunal de Justiça afirmou a respeito, em novembro de 2016, que a jurisprudência oferecida pelo Tribunal de Justiça europeu não seria adequada ao contexto brasileiro, dadas as grandes diferenças nas premissas legislativas de que partem ambas as situações. E sobre a aplicação do artigo 7º, inciso X, do Marco Civil da *internet*, que foi citado aqui mais cedo, deixou claro que o direito à exclusão de

dados pessoais alcança somente as informações que o próprio indivíduo houver fornecido para um determinado serviço *online*, não se confunde com a questão de notícias e o que é dito a respeito dessa pessoa.

Expostos rapidamente esses equívocos da decisão do caso Costeja, eu gostaria de destacar também ao Tribunal como a comunidade jurídica internacional vê essa matéria, a partir da experiência da Google em diversos países.

O primeiro ponto a destacar, é importante lembrar, é que esse suposto direito ao esquecimento não é reconhecido em nenhum tratado ou convenção internacional de direitos humanos nem em nenhuma constituição nacional. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, destacam que a liberdade de pensamento e de expressão compreende a liberdade de novamente buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito etc.

O Professor Eduardo Bertoni, que é Diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados da Argentina, escreveu um artigo em que afirma que o direito ao esquecimento é um conceito ofensivo, um verdadeiro insulto à história da América Latina. Ele é categórico ao dizer que, se aqueles envolvidos nas violações em massa de direitos humanos pudessem solicitar a *sites* e a mecanismos de busca

que tornassem essas informações inacessíveis, argumentando que a informação não é mais atual ou lhes causa desconforto, isso seria um desserviço e um insulto à nossa história.

A jurisprudência internacional fora da Europa também se recusa a reconhecer esse suposto direito ao esquecimento. O Japão, por exemplo, Ministro Toffoli, recentemente negou-se a reconhecer a existência do direito ao esquecimento. O caso concreto tratava de um indivíduo que foi preso e multado, estava envolvido em prostituição infantil no passado, buscava a eliminação de *links* em mecanismos de busca a respeito desse episódio, alegando que muitos anos já haviam se passado e que ele agora tinha mulher e filho, trabalhava há anos na mesma companhia e mantinha uma conduta exemplar. A Suprema Corte do Japão negou o pedido em 31 de janeiro de 2017, poucos meses atrás, destacando que forçar um mecanismo de busca a remover resultados não apenas restringe a expressão, como restringe o acesso do público a informações relevantes, tendo em vista o papel significativo que esses mecanismos exercem para a sociedade moderna obter informações. E destacou que, apesar dos direitos de privacidade do autor, que deseja que outros não saibam a respeito desse assunto, o fato é tema de interesse público, em razão de que a prostituição infantil configura exploração de menores, é fortemente rejeitada pela sociedade japonesa e é punida criminalmente.

E não poderia ser afirmado, então, que seu interesse privado se sobreporia a outros interesses em jogo.

Na Austrália, depois de debater o assunto e avaliar os diversos casos existentes, o Comitê da Reforma Legislativa entendeu que aquele país não precisa do direito ao esquecimento em seu sistema jurídico, rejeitando a ideia de introduzi-lo no ordenamento local.

Na Colômbia, a Corte Constitucional igualmente decidiu ser incabível o reconhecimento de um direito ao esquecimento, entendendo que o controle da expressão ou do acesso à informação consiste em censura.

No Chile, a Suprema Corte confirmou decisão negando o reconhecimento de um direito ao esquecimento, destacando não haver dúvida de que a livre circulação de informações na *web* beneficia toda a sociedade e que o Legislativo, ao contrário, deveria adotar normas impondo o dever ao Estado de assegurar o livre fluxo dessas informações, bem como proteger a honra e a privacidade dos indivíduos, sem adotar mecanismos que permitiriam censura prévia.

E veja só, Ministro Toffoli, mesmo na Europa, há enormes controvérsias a respeito da aplicação desse suposto direito. Em 12 de maio de 2016, por exemplo, a Corte de Cassação francesa entendeu, em um caso muito interessante, que o direito ao esquecimento não se sobrepõe à liberdade de

expressão. Qual era o caso? Dois irmãos pretendiam que um jornal francês eliminasse dos resultados do mecanismo de busca do próprio *site* do jornal, e não do *Google*, ou do *Bing*, ou de outros mecanismos similares, *links* para um artigo que noticiava uma punição imposta a eles, em 2006, pelo Conselho de Estado. A Corte de Cassação entendeu que remover esses *links* do mecanismo de busca do jornal excedia as restrições que poderiam ser impostas à liberdade de imprensa e negou o pedido. Por que esse caso francês é emblemático? Porque ele demonstra claramente a essência do problema. Esses irmãos franceses não tentaram remover o conteúdo em si do *site* do jornal, porque sabiam que o pedido seria negado. Eles tentaram, porém, obter um resultado prático equivalente, com fundamento no direito ao esquecimento, justamente porque a remoção sob essa alegação seria em tese facilitada. Felizmente, a Corte de Cassação impediu que esse atalho indevido fosse utilizado.

Sejamos claros, Senhores. Direito ao esquecimento significa falar em eliminação de informações, seja em sua fonte ou dos *links* que levam a essa informação. Seus defensores costumam mencionar casos extremos para tentar justificar a este Tribunal que seria necessário facilitar de alguma maneira a remoção de informações *online*. Esses argumentos, eu alerto, são equivocados. Mais uma vez, nosso sistema jurídico já oferece soluções perfeitamente adequadas, sem que seja necessário inventar um novo conceito nem estabelecer um novo direito.

Do ponto de vista procedimental, pedidos de remoção de conteúdo, seja qual for o fundamento aplicado, podem inclusive ser analisados via juizados especiais cíveis, sequer se necessita advogado. Já ocorria isso antes agora da previsão existente no artigo 19 do Marco Civil da Internet e segue assim.

Do ponto de vista do Direito Material, esse mesmo artigo 19 do Marco Civil da Internet deixa claro que remoção de conteúdo *online* pode ocorrer voluntariamente, não apenas pela via judicial. Tanto é assim que *sites*, serviços e plataformas *online* têm suas próprias políticas de conteúdo aceitável, que podem ser inclusive mais restritivas até do que autoriza a legislação. Um exemplo da empresa: conteúdo adulto não é permitido no YouTube, ainda que a legislação permita, em tese, sua divulgação, para maiores de idade.

Quando se trata de remoção forçada de conteúdo, portanto, nosso ordenamento jurídico já conta com disposições suficientes, para que o Judiciário faça o sopesamento entre direitos fundamentais. Tanto é que o caso desses autos e diversos outros similares se apoiam no capítulo dos direitos de personalidade do Código Civil e na Constituição Federal, bem como outros casos se apoiam em regras específicas para situações excepcionais.

Casos de imagem de pornografia infantil, por exemplo, já contam com o diploma legal específico, 241 do ECA, que determina a remoção mediante simples notificação. Caso que se convencionou chamar de pornografia de

vingança, ou seja, essas divulgações de imagem de sexo adulto obtidas sem consentimento, também resolvido pelo artigo 21 do Marco Civil da Internet. O mesmo se dá com a reabilitação criminal, prevista tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal. Ou seja, não há no sistema jurídico brasileiro qualquer dificuldade para se justificar pedidos de remoção, nem tampouco há histórico jurisprudencial de negativa de atendimento aos pedidos corretamente fundamentados.

E aqui, Ministro Toffoli, o cerne da minha argumentação é o seguinte: o que os defensores do suposto direito ao esquecimento desejam, em realidade, é um atalho. Em vez de enfrentar o ônus argumentativo e convencer o Judiciário das razões pelas quais um pedido de remoção se justifique, o que se busca aqui, em verdade, é um superdireito, quase que um verdadeiro coringa, que se sobrepõe ao sopesamento. Afastar esse processo de sopesamento entre direitos fundamentais e defender uma preponderância presumida da privacidade de modo genérico, que me parece ser o objetivo aqui, é utilizar esse direito ao esquecimento como pretexto para todo pedido de remoção, como visto, aliás, no caso francês que eu mencionei.

O Supremo Tribunal Federal, aliás, já lida com argumentos muito parecidos. É comum a gente observar a dignidade da pessoa humana ser invocada para justificar posições absolutamente antagônicas. Então, criar uma nova

cláusula aberta, sob o título de direito ao esquecimento representa um enorme perigo para o nosso sistema constitucional de sopesamento entre direitos fundamentais.

Quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que toda informação deva ser encontrada por meio da *internet*. O Google tem políticas, por exemplo, de remoção de informações claramente pessoais, como números de identificação pessoal, contas bancárias, cartões de crédito, etc., etc., bem como imagens de abuso sexual infantil, sexo adulto obtido sem consentimento e outras dessa natureza.

Mas aí eu volto a insistir nesse ponto. Quando se está diante de informações ilegais, dificilmente existe objeção à remoção. Mas o reconhecimento desse direito ao esquecimento vai permitir que informações verídicas e legais sejam removidas de modo facilitado, apenas porque desagradam alguém. Nossa experiência, inclusive, da empresa, em casos judiciais no Brasil, evidencia que a maioria dos pedidos de remoção da busca fundamentados no suposto direito ao esquecimento são de resultados para fontes públicas, como o Diário Oficial e jornais de grande circulação.

Parece-me, então, claramente inconstitucional a imposição de uma proibição genérica de se falar do passado, já que é exatamente o conhecimento sobre o passado que permite a nós refletir sobre o presente - o famoso adágio: quem

não conhece a história está fadado a repeti-la -, sendo impossível definir, de antemão, o que terá ou não significado histórico ou interesse público.

Por fim, já encaminhando para o final da minha intervenção, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem uma longa tradição de balanceamento com critérios consolidados. Não é uma jurisprudência hiper-protetiva da liberdade de expressão e sempre teve muita consideração pelos direitos de personalidade e outros direitos fundamentais. Basta a leitura das decisões como, por exemplo, do caso Ellwanger ou da ADPF 130, entre outros, para constatar que o Supremo trata o tema com a mais absoluta seriedade e serenidade e que mais tribunais, em realidade, deveriam seguir o Supremo Tribunal Federal em casos relacionados à liberdade de expressão.

Espero, então, com esses pontos, ter demonstrado que o Brasil não só não precisa, como deve rejeitar o conceito de um direito ao esquecimento. E insisto, isso posto de direito, apenas serviria de atalho para eliminar o sopesamento entre direitos fundamentais e estabelecer uma preponderância presumida da privacidade, de modo genérico, servindo como pretexto para todo o pedido de remoção de informações.

Precisamos, no Brasil, agora mais do que nunca, de mais informação e de mais memória.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) – Dr. Marcel, uma pergunta.

O SENHOR MARCEL LEONARDI (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) - Pois não, Ministro.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Administrativamente, alguém procura a *Google* para retirar uma determinada notícia. Qual é o critério - deve haver um *standard* já formalizado, um padrão? O senhor poderia falar?

O SENHOR MARCEL LEONARDI (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) - Claro. Normalmente, Ministro Toffoli, o que se passa é uma grande distinção entre o que seria conteúdo manifestamente ilegal, em que não há objeção. O exemplo mais corriqueiro é, por exemplo, imagens de abuso sexual infantil, em que obviamente nenhum povo civilizado mantém uma discussão se isso é lícito ou ilícito e, o contraponto, que é a esmagadora maioria dos questionamentos que a *Google* recebe, que são de conteúdos, cuja legalidade ou ilegalidade tem uma natureza extremamente subjetiva.

Nós vemos isso, por exemplo, até fora do ambiente da *internet*, em muitas matérias jornalísticas, em que, às vezes, há uma demanda, por exemplo, de indenização, em que se diz "foi difamatório, não foi difamatório". E mesmo as

decisões entre primeira instância, segunda instância, tribunais superiores, divergem entre si.

Então, normalmente, quando existem elementos que justificam essa ilegalidade subjetiva, ou seja, não se sabe, de antemão, se aquele conteúdo é lícito ou é ilícito, se aguarda, então, por uma decisão do Poder Judiciário. Mas, produto a produto, a Google tem políticas mais amplas. Mencionei, agora há pouco, o exemplo do Youtube. Imaginar um cenário impensável, mas de pornografia adulta num vídeo do Youtube. Será removido mediante simples denúncia.

Por que isso? Porque simplesmente é a política do produto decidir. Esse tipo de conteúdo não serve para a minha plataforma, não quero isso aqui. Não se confunde isso, porém, com licitude ou ilicitude, que poderia existir num serviço dedicado exclusivamente a isso. Aliás, a *internet* comercial tem, em seus primórdios, muita imagem desse tipo.

Mas o ponto é: há uma série de critérios que são observados e não há nenhuma objeção prévia. Ou seja, se avalia muito essa preocupação de ter certeza de que o que está sendo removido, de fato, justifica a remoção, porque não haveria questionamentos. Se há questionamentos, até pela lógica do Marco Civil da *Internet*, que fala tantas vezes na preponderância da liberdade de expressão, a empresa tende a seguir o critério de aguardar uma decisão judicial para, então, obedecê-la e fazer a remoção desse conteúdo.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - E a própria página do Google já tem esse acesso para quem está usando a *internet?*

O SENHOR MARCEL LEONARDI (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) - Na verdade, é produto a produto para justamente facilitar a encontrar essas informações.

Uma própria pesquisa, no mecanismo - como remover o conteúdo do Google? -, já entrega a página diretamente. Ou, mesmo na parte de baixo, por exemplo, do buscador, tem lá os termos de uso, políticas, o usuário, conforme clica, já encontra essas diretrizes.

No caso do Youtube, que tem vídeos, de uma maneira geral, cada vídeo tem lá uma bandeirinha que indica o que pode ser detectado, o que pode ser denunciado. Mas, aqui, Ministro, há uma diferença muito importante, porque, enquanto a Google faz a indexação do material que existe na *web*, ou seja, conteúdos de terceiros, jornalísticos, *sites*, *blogs*, o Youtube é o conteúdo hospedado pela própria Google. E, aí, remover o conteúdo hospedado tem obviamente um caminho mais simples de recebimento de denúncia *versus* a indexação do que se passa.

E às vezes, Ministro, até um ponto adicional, foca-se muito a discussão na Google por ser o buscador, aí, preferido da maioria dos utilizadores, dos usuários de uma maneira geral. Mas o que se constata é que há diversos outros. Quer dizer, uma vez que esse mercado se expande, e há os próprios buscadores dos

serviços em si, ou seja, dos jornais, dos *sites*, etc. etc., a nossa preocupação, como eu disse, é que o direito ao esquecimento acabe virando um atalho rápido para justificar remoções que normalmente não se sustentariam se fossem utilizadas com o ônus argumentativo da ponderação.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço a atenção e a exposição de Vossa Excelência.

O SENHOR MARCEL LEONARDI (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) - Muito obrigado. Ministro, eu vou pedir licença para me retirar por conta de um voo internacional, que eu preciso apanhar. Mas estamos à disposição para quaisquer questionamentos posteriores.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Convido, agora, para falar o Dr. Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina, graduado e mestrando em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que falará em nome do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM). Vossa Senhoria, também, Dr. Gustavo, tem 15 minutos.

O SENHOR GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA (INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS - IBCCRIM) - Obrigado, Ministro. Uma pequena correção: eu sou graduado pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, da onde minha professora veio aqui falar

conosco, hoje, também. Eu cumprimento o senhor, cumprimento o douto Subprocurador-Geral da República, doutor Kim, Senhora Secretária, os demais presentes e expositores.

Ministro, eu venho aqui, hoje, muito honrado por poder representar o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O IBCCRIM é uma entidade que fomenta o estudo em torno das ciências criminais, há mais de 25 anos. E, como bem lembrou o meu companheiro, o doutor Anderson Schreibe, o IBCCRIM está sempre presente nesta Corte, sempre interessado nas discussões que aqui acontecem. Apesar de essa ser uma discussão, inicialmente, de caráter civil, o IBCCRIM entende que, aqui, há também um fundo penal, que pretendo tratar, aqui, hoje.

Nós do IBCCRIM temos profundo respeito por essa Corte, que sempre deu exemplos de defesa da dignidade, dos direitos humanos, sempre pautada pela legalidade, pela defesa da Constituição. Também nutrimos igual respeito pelo STJ. E aqui é bom que se rememore o voto do Ministro Luís Felipe Salomão, quando tratou dessa questão no Recurso Especial lá. O voto do Ministro é uma verdadeira lição. Nele mesmo, o Ministro diz que não há dúvidas quanto ao reconhecimento do direito ao esquecimento. Por isso mesmo, eu estou aqui, hoje, convicto para a defesa de um único ponto, de uma única tese, que é cara ao IBCCRIM, que é a da regenerabilidade da pessoa humana, da estabilização do

passado. Não é possível, com todo o respeito, que, enquanto sociedade que vive sob os auspícios da Constituição Cidadã, nós possamos admitir que alguém carregue para sempre um "senão", acompanhado ao seu nome, seja ele qual for. Nas palavras do professor Victor Grabriel Rodriguez: "Não se pode afirmar que a liberdade de imprensa e a intimidade não convivam, mas elas certamente se limitam." Segundo ele, a intimidade é um direito fundamental, que garante o livre desenvolvimento da personalidade e o direito à reserva dos momentos que não dizem respeito à manifestação pública e do comportamento social. O IBCCRIM entende que não há espaço para a relativização de direitos, em especial, daqueles mais comezinhos, ao desenvolvimento da pessoa humana, como são os casos da intimidade, da vida privada, da honra e da dignidade.

A Carta da República não é chamada "cidadã" à toa. O constituinte não se furtou em proteger esses direitos, notadamente, nos artigos 1º, III e 5º, X. O caso paradigma que nos traz, aqui, a esta Corte hoje, é a morte da Aída Curi, em 1958, no Rio de Janeiro, em circunstâncias, sem dúvida nenhuma, brutais. Mas essa é uma história que a própria família Curi quer esquecer. As teorias que tratam da intimidade e da vida privada falam do direito de ser deixado em paz, como sendo mais significativo para o desenvolvimento dos homens civilizados. O tempo em que nós vivemos impõe algumas reflexões adicionais quanto ao que é ser efetivamente deixado em paz. Não há dúvida que há uma transformação social

em curso, nunca a história da humanidade experimentou nada como a popularização da *internet* de banda larga e a difusão das redes sociais. Ser condenado, hoje, ou ainda menos, ser investigado, ou processado, ou ligado - de qualquer forma - a um crime, significa a possibilidade de carregar, para sempre, um verbete com o seu nome, disponível o tempo inteiro, e de maneira indefinida, ao alcance de qualquer um com acesso à *internet*.

Os espanhóis, como o senhor bem sabe, chamam de "pena do banquinho", o ato de sentar-se no banco dos réus, como essa sendo mesmo a primeira pena imposta ao réu, que pode ser absolvido depois disso. Mas sofre a pena de sentar no banco. A pena que a sociedade vai lhe impor depois.

Nós podemos estar diante, aqui, de uma nova pena num paralelo, que seria a pena de nunca mais poder ser esquecido. Não pelos *sites* dos tribunais, esses podem esquecer, mas pelos buscadores de *internet* e pelos *sites* de mídia.

Como uma pessoa que carrega um verdadeiro aposto ligado ao nome - a vítima, ou o familiar, ou o agressor do crime tal - vai poder reconstruir sua vida se isso não cessar? É preciso que, em algum momento, nós, enquanto sociedade, sejamos capazes de garantir a devida intimidade aos sujeitos que, de qualquer forma, voluntária ou involuntariamente, tenham tido relação com o ato criminoso.

O processo iniciado pela família de uma vítima nos dá hoje aqui a oportunidade de delinear o direito ao esquecimento de uma maneira geral, não só para os familiares, mas também para as vítimas e para os agressores. Vítimas, familiares e também ofensores merecem ter respeitadas as suas vidas privadas. A intimidade é essencial para a formação da dignidade humana e para a autonomia individual. O direito de informar, tão bem delineado hoje aqui pelos meus colegas, não pode sobrepor-se a outros igualmente constitucionais.

Cumprida a pena, os fatos que cercam o ato criminoso precisam ser superados pela sociedade; não podem ser eternamente reprisados seja lá por quem for, onde quer que for.

É da nossa Constituição a vedação expressa às penas de caráter perpétuo - art. 5º, inc. XLVII - e do nosso Código Penal a imposição de um marco temporal dos efeitos das penas, de cinco anos a contar da data de seu cumprimento ou extinção - art. 64, inc. I. Superado o lapso dos cinco anos, não há critério material apto a valorar o delito cometido. Sua Excelência o Relator, Ministro Dias Toffoli, inclusive reconheceu isso no HC 118.977, do Mato Grosso do Sul. Por isso mesmo, o artigo 93 do Código Penal prevê que o instituto da reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo de condenação, aplicado em combinação com o art. 748 do Código de Processo Penal, que afirma que, concedida a reabilitação, "a

condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo se requisitadas por juízo criminal".

Nós temos que é absolutamente ilegal a lembrança de condenações passadas, salvo por juízo criminal, por quem mais que seja. Aliás, isso é o mesmo que garante o art. 202 da Lei de Execuções Penais. Nada disso, contudo, senhores, significa dizer que o IBCCRIM quer que a história seja esquecida. A trajetória da humanidade, nós sabemos disso, é envolta em atos criminosos que jamais podem deixar de ser recordados. Mas os envolvidos em qualquer crime precisam ver preservada a chance de superar os malefícios, sob pena de, na sociedade em rede em que vivemos, jamais terem o direito de reconstruírem as suas vidas.

O direito de informar e a curiosidade pública não podem se confundir. Crimes que nunca devemos esquecer, para que nunca mais aconteçam, como a ditadura militar no Brasil, são fatos históricos, tragédias da humanidade, em tudo distantes da criminalidade comum que desperta a curiosidade pública, como é o caso em análise. Para fatos históricos, é sim a liberdade de imprensa irmã siamesa da democracia - como assentado nesta Corte na ADPF 130 -, mas não a curiosidade pública. Dessa, a verdadeira democracia defende os cidadãos.

O pretexto da historicidade de um fato não pode significar permissão de abuso da dignidade humana. Nesse caso, o reconhecimento do direito ao esquecimento pode significar, isso sim, um corretivo das vicissitudes do passado, seja de inquéritos policiais ou de processos judiciais pirotécnicos e injustos, seja da exploração populista de um caso pela mídia, seja da dor não respeitada da família ou de uma vítima. Portanto, a questão da historicidade dos crimes, embora, como bem lembrado hoje aqui, relevante, precisa ser ponderada caso a caso.

Crimes midiáticos não são uma singularidade brasileira. Há casos por todo o globo, como foi relembrado aqui hoje. Eu acho que um caso - trouxe alguns, mas vale a pena, porque vários já foram lembrados - vale ser lembrado: em 1993, em Liverpool, na Inglaterra, o caso Bulger. Uma criança de dois anos de idade, James Bulger, foi raptada por dois garotos de dez anos de idade, Ministro, em um shopping. Esses dois garotos levaram a criança para uma linha de trem, torturaram, mataram e deixaram o corpo na linha do trem. Eles tinham dez anos de idade, cumpriram oito anos de medidas socioeducativas e foram libertados em 2001. A juíza do caso, desde o começo, Doutora Elizabeth Gloss, garantiu a esses dois garotos novas identidades e um direito vitalício ao anonimato, para que eles pudessem reconstruir suas vidas. Então, esse caso é de 2001, é recente.

Por isso mesmo, senhores, o IBCCRIM veio a essa tribuna, hoje, para defender que se estabeleça um marco temporal - algo que quando eu cheguei aqui, Ministro, achei que seria chamado de conservador, mas eu vou embora achando que essa é uma tese nossa arrojada, perto do que foi defendido aqui.

O IBCCRIM defende, aqui, hoje, o estabelecimento de um marco temporal. Um marco que, ainda que conservador, dê às pessoas a oportunidade de serem esquecidas em algum momento de suas vidas, serem deixadas em paz. Passados cinco anos do cumprimento, ou extinção da pena, os fatos criminosos não podem contar para efeito de reincidência, como já decidiu esta Corte. E, na nossa visão, não devem contar como maus antecedentes, como ainda decidirá esta Corte em um outro recurso extraordinário, de relatoria do Ministro Barroso. Passados cinco anos do cumprimento, ou extinção da pena de fatos criminosos, o IBCCRIM propõe e defende, hoje, aqui, o entendimento de que, passados cinco anos do cumprimento, ou extinção da pena, os agentes envolvidos nos fatos criminosos, desde que manifestem sua vontade - porque aqui se trata de um direito de personalidade -, também não devem ser alvo de novas reportagem jornalísticas ou documentais. E ainda que não possam ter os seus nomes indexados à novos *links* em buscadores de *internet*, surgidos depois de atingido esse marco temporal.

Os buscadores devem, portanto, segundo essa nossa tese, deixar de carregar ou indicar novos *link*s quando atingido este marco temporal e

desindexar aqueles que forem carregados depois, desde que manifesta a vontade da pessoa, seja ela vítima, familiar ou agressor. A pena, senhores, precisa acabar, para todos, em algum momento.

Em um paralelo, Excelência, podemos dizer que até a prescrição e a decadência são sim direitos a um esquecimento programado, consagrados para que as vidas dos jurisdicionados possam, de alguma forma, seguir adiante. O constituinte de 88 fez da Carta Cidadã um livro de proteções. É preciso revisitá-lo todos os dias. Esse Supremo Tribunal Federal já deu vívidos exemplos de homenagem aos direitos humanos. Esse pode ser mais um, um novo.

O IBCCRIM acredita que a promoção de direitos é o único caminho civilizatório possível. A manutenção de inimigos públicos constantemente relembrados pela mídia, continuamente alvo de reportagem -sejam jornalísticas, documentais, etc., sempre com suas vidas devassadas na *internet* -, não é um bom exemplo para a sociedade brasileira. Todos nós sabemos disso!

Que não se duvide: o estabelecimento do direito ao esquecimento é bloco fundamental na construção de uma sociedade pautada pela crença na regenerabilidade da pessoa humana, como quer a nossa Constituição Federal, não fosse assim seria impossível acreditar na recuperação social dos apenados.

O IBCCRIM então reafirma sua posição, para que fique claro, passados cinco anos do cumprimento, ou extinção da pena, os agentes envolvidos, quer sejam vítimas, quer sejam familiares, quer sejam os próprios ofensores, desde que manifesta vontade, não podem ser alvo de novas reportagem jornalística ou documentais ligadas aos fatos, devendo os buscadores de *internet* e motores de busca verem-se obrigados a deixar de indexar novos *links* quando atingido esse marco temporal. Deve valer aqui, senhores, o adágio de que informação velha não vira notícia nova.

Já caminhando para a conclusão, as Cortes de outros países têm reconhecido, sim, direitos similares. Aqui se usou hoje o exemplo da Califórnia. De fato, ele tem quase cem anos. Um exemplo da Alemanha, de fato, ele tem mais de cinquenta anos. Mas há exemplos na França, há esse exemplo recente na Grã-Bretanha e, de maneira reflexa, há também o julgamento de 2014, da União Europeia, tratando, verdade, da desindexação de conteúdos, mas, de uma maneira reflexa, isso também recai sobre o direito ao esquecimento.

Ao esposar esse entendimento do IBCCRIM, senhores, esta Corte estará cumprindo a Carta de 88 em seu âmago, na medida em que preservará, ao mesmo tempo, o direito de informar porque, segundo a nossa tese, não há, aqui, nenhum óbice para a manutenção de reportagens produzidas dentro do marco

temporal indicado, para *links* carregados e indexados dentro do marco temporal indicado, mas fará valer, também, a vedação a penas perpétuas.

A perseguição perpétua a uma pessoa porque esteve envolta em um fato criminoso. A *internet* não pode impor penas perpétuas no Brasil. Dará, ainda, a intimidade nova e a necessária extensão. Isso foi discutido aqui, hoje, e, de fato, o direito ao esquecimento não é um direito que está escrito na nossa Constituição. Ele é um direito derivado. Por isso estamos aqui hoje. E ele é uma extensão, sim, necessária, da intimidade. Trará, ainda, à lume, o direito ao esquecimento, verdadeira consagração, em termos modernos, da intimidade, dando a todos - vítimas, ofensores e familiares - o direito de, cumprida a pena, seguirem adiante, serem esquecidos, serem deixados em paz.

Obrigado, senhores.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço ao Dr. Gustavo Mascarenhas Lacerda.

Só anotaria uma questão, para não passar em branco, sem fazer nenhum juízo de valor sobre a manifestação de Vossa Excelência, quanto aos efeitos das penas já cumpridas, passados os cinco anos no âmbito penal. Só para registrar que a Lei Complementar nº 64/90, após a alteração da Lei da Ficha Limpa, aumentou os prazos de inelegibilidade de três para oito anos. Então, existem efeitos de uma sanção penal que, depois de cumprida a pena - por exemplo, em crimes

contra a administração pública ou em outros crimes elencados na Lei Complementar nº 64/90 -, projetam-se para tolher a plena cidadania do já condenado, daquele que já cumpriu a pena, não até cinco anos, como se diz na área penal, mas até oito anos, na área eleitoral.

O SENHOR GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA (INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS - IBCCRIM) - Nós buscamos, aqui, uma regra geral e bastante baseada nos maus antecedentes, que está passível de...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Só para deixar esse registro de que, na legislação eleitoral, os efeitos, mesmo depois do cumprimento da pena, para os crimes elencados na Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar nº 64/90, projetam-se por oito anos.

O SENHOR GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA (INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS - IBCCRIM) - Obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Nesse momento, eu passo a palavra, também por quinze minutos, ao Prof. Dr. Carlos Affonso Pereira de Souza, bacharel pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade Estadual do Rio de

Janeiro; professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que falará pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro.

O SENHOR CARLOS AFFONSO PEREIRA DE SOUZA (INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO - ITS RIO) - Boa tarde a todos. Boa tarde ao Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli. Aproveito a oportunidade para saudar, também, o Doutor Odim Brandão, o Doutor Richard King e a Doutora Ravena Siqueira, no início desta exposição, em nome do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS-Rio.

O ITS-Rio é uma associação formada há quatro anos, por professores que se dedicam ao tema de estudos sobre os impactos da tecnologia na sociedade como um todo, mas o trabalho vem desde 2003, dos seus diretores, o professor Ronaldo Lemos, o professor Sérgio Branco e eu. Desde então, desde 2003, fundamos o mais antigo Centro de Pesquisa em Direito e Tecnologia, dentro de uma Faculdade de Direito, no Brasil, e agora seguimos nossas pesquisas através do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Nós tivemos o prazer de atuar como o grupo de pesquisadores que auxiliou o Ministério da Justiça, na consulta do Marco Civil da *internet*, em 2009 e 2010, e mais recentemente o Instituto lançou o aplicativo "Mudamos", que é um aplicativo que permite que as pessoas assinem digitalmente

propostas de projeto de lei a partir do seu dispositivo celular, tentando incrementar o recurso às leis de iniciativa popular.

Dito isso no tempo que me é conferido, gostaria de trazer à discussão dez desafios, dez dilemas da figura do direito ao esquecimento. Para isso, os senhores e senhoras podem ver esses dilemas e esses desafios colocados no *slide.*

Começaria, inicialmente, por uma questão importante envolvendo a definição do tema que nos traz aqui hoje, o chamado direito ao esquecimento, um problema de definição, porque me parece que o direito ao esquecimento não é nem mesmo direito nem mesmo gera o esquecimento. O direito ao esquecimento não seria um direito por três razões. De início, o que faz o direito ao esquecimento é, olhando o ordenamento jurídico brasileiro, percebermos que ali não existe um alicerce, não existe uma disposição, no nosso ordenamento jurídico, sobre o chamado direito ao esquecimento.

Em segundo lugar, percebemos que o direito ao esquecimento é uma máscara para a aplicação de outros direitos fundamentais, de outros direitos da personalidade, como privacidade, honra, nome. Com isso, o direito ao esquecimento acaba mascarando e dificultando a proteção desses outros direitos da personalidade. Numa expressão bastante feliz, parece-me, a ex-relatora para liberdade de expressão da Organização dos Estados Americanos, Catalina Botero,

diz que direito ao esquecimento não é uma categoria jurídica, é uma categoria emocional.

E um terceiro argumento pelo qual não me parece que o direito ao esquecimento seria um direito, é que, na verdade, nós estamos trabalhando os mecanismos que envolvem a remoção de um conteúdo na *internet*, o apagamento de dados ou até mesmo a desindexação de uma informação; e colocar o nome "direito ao esquecimento" nesse debate mais confunde do que explica. Nós estamos aqui numa situação em que chamar direito ao esquecimento de direito confunde a situação que nós temos, que é a proteção da privacidade, da honra, da imagem e do nome através de instrumentos que são o apagamento de dados, a remoção de conteúdo, a desindexação de determinadas informações e que cabe às Cortes colocarem as condições, e que cabem às leis delimitarem, se tanto, a possibilidade dessas ferramentas.

Então, acho que, de início, temos um debate importante, que é a própria definição do que se entende por direito ao esquecimento. Eu disse que não é direito, mas também não é esquecimento. E esse ponto é importante porque nenhuma decisão judicial ou administrativa jamais causará o efeito do esquecimento. Nenhuma decisão judicial tem o poder, como se fosse em um filme de ficção científica, de extrair da mente de cada um de nós a lembrança sobre alguma coisa, extrair parte da memória. Então, parece-me que, na definição direito

ao esquecimento, temos problema tanto na parte do direito como na parte do esquecimento. Esse é um efeito que não decorre necessariamente da ordem judicial. Esse é um efeito social e é importante que se leve isso em consideração.

Um o segundo ponto é arquitetura da rede, e aí passo para falar especificamente de *internet*. Nesse ponto, o ITS, atuando como *amicus curiae*, participou do processo trazendo à luz uma pesquisa feita por nossos pesquisadores desde 2012 até 2016, sobre decisões judiciais em segunda instância, nos tribunais brasileiros que mencionam o chamado direito ao esquecimento. E é interessante perceber que, dos 329 casos encontrados em nossa pesquisa, 114 casos tratam de meios de comunicação, ou seja, isso mostra, quando se trabalha com o tema do direito ao esquecimento, que veículos de comunicação, meios de comunicação aparecem como algo bastante importante. Mas, mais do que isso, se olharmos dentro desse *pool* de casos envolvendo direito ao esquecimento e meios de comunicação, notamos também que, desses 114 casos, 84 deles dizem respeito à *internet*, ou seja, 74% dos casos dizem respeito à *internet*. Isso serve como um alerta, isso serve como um alarme que mostra que a decisão que será encontrada aqui neste Supremo Tribunal Federal é uma decisão que, ainda que analise nesse caso um programa televisivo, certamente enviará a todos os tribunais orientações sobre o tema do direito ao esquecimento, o chamado direito ao esquecimento, que terá

impactos na *internet.* E, aí, esse pequeno espaço de tempo de 4 anos revela essa conclusão.

E, ainda, trabalhando sobre *internet*, acho que vale a pena colocar um ponto que é sempre lembrado de que, na rede, a lembrança é a regra, o esquecimento parece ser a exceção. Isso decorre da própria arquitetura da rede; isso decorre da própria criação na *internet* como uma rede de redes feita para que a informação perdurasse, mesmo que parte dessa rede viesse a se tornar inutilizada. E acho importante lembrar esse desenvolvimento da *internet,* porque junto dela vem o desenvolvimento da digitalização. Lembramos cada vez mais, porque temos um acesso cada vez maior à informação.

E, aí, se nós olharmos um pouquinho, como dialogamos com a questão do tempo, da memória, acho que vale lembrar, quando nós vamos ao museu encontrar com o nosso passado, o que encontramos em um museu? Encontramos tabuletas de argila, papiros e pergaminhos. Esses foram os suportes que num passado, em que o conhecimento era escasso e que os materiais eram escassos, em que ali se optou por consolidar algum conhecimento, se consolidou uma determinada informação, houve uma escolha sobre o que seria consolidado e retratado e o que se perdeu pela história.

A *internet* nos coloca um momento muito importante em que torna possível que as informações sejam consolidadas, organizadas e acessadas

como nunca. Vale pensar se é dado ao direito, nesse momento, criar, através da figura do chamado direito ao esquecimento, uma direção contrária: restringir essa facilidade que a *internet* nos coloca.

O terceiro problema, um terceiro desafio do direito ao esquecimento é a pergunta: podemos definir *ex ante* o que é relevante e o que não é relevante? O que tem interesse público e o que apenas interessa à vida privada? Nesse ponto, acho que importante lembrar, embora não relacionado a casos de direito ao esquecimento, mas, como um exemplo poderoso, que nós tivemos um processo judicial envolvendo um acidente de trabalho de um metalúrgico que perdeu o dedo numa prensa, e esse processo foi incinerado para abrir espaço em arquivos. Como seria interessante, hoje, ter acesso a esse processo, justamente porque é o processo de um metalúrgico que se tornou Presidente da República! Mas esse processo, quando foi incinerado, entendeu-se que não tinha interesse público. Será que nós estamos prontos para decidir *ex ante* sobre o que é interesse público e o que não é interesse público?

Um quarto desafio é um desafio que decorre da decisão europeia do caso Costeja tão citado aqui, que é o desafio da privatização da decisão de critérios sobre remoção de conteúdo. A decisão europeia delega às empresas que recebam notificações e que decidam se determinado conteúdo deve ou não deve ser desindexado. E essa é uma questão problemática, porque, ao fazer assim, a

decisão europeia incentiva tribunais privados, tribunais corporativos; estimula que eu tenha que conhecer a jurisprudência dos principais tribunais do meu país, dos tribunais estrangeiros, e também das empresas de *internet;* a jurisprudência do Google, a jurisprudência do Facebook. Talvez, em sala de aula, tenhamos que, no futuro, ensinar sobre a jurisprudência das empresas e dos tribunais.

Acho importante deixar claro que, no ordenamento jurídico brasileiro, essa solução não prospera. O Marco Civil da Internet, no seu artigo 19, determina que os provedores de aplicação à *internet* apenas serão responsabilizados caso falhem em cumprir uma ordem judicial. Eles podem até remover o conteúdo, caso entendam que esse conteúdo vai contra os seus termos de uso, mas não seriam obrigados a tanto. Então, acho que o artigo 19 do Marco Civil coloca esse assunto numa outra visão.

O quinto desafio, junto com o sexto, trabalha com questões ligadas à efetividade. O primeiro desafio é: implementação global de um chamado direito ao esquecimento, porque uma decorrência da decisão europeia do caso Costeja é o debate sobre se o conteúdo deveria ser dizer desindexado da plataforma do Google ou apenas do país daquela pessoa que ingressa com o pedido de desindexação.

E já que estamos falando de *internet*, esse é um problema crucial: a *internet* atravessa fronteiras, embora os Estados, cada vez mais, através da edição

de suas leis próprias, coloquem ali os limites, coloquem ali a afirmação de direitos do cidadão daquela específica nacionalidade. Mas vale lembrar que a implementação global de um mecanismo de desindexação, de remoção, gera um problema especialmente para o exercício da liberdade expressão. O desafio aqui é: sabemos, por exemplo, que alguns países, como a Tailândia, é um crime criticar a realeza. Se é dado um mecanismo de remoção global de conteúdo, o juiz da Tailândia terá a possibilidade de remover um conteúdo não apenas na Tailândia, mas globalmente. E é bom lembrar que os casos de remoção global já chegaram ao Brasil. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu sobre casos como esse, em um deles o próprio magistrado disse que se recusava a dar a ordem de retirar-se um vídeo globalmente de uma plataforma de vídeos, porque não saberia qual a lei vigente e aplicável na Alemanha ou na Colômbia sobre visualização daquele determinado vídeo.

Então, esse aspecto Global não é desprezível, precisa ser analisado. Vale lembrar que o direito ao esquecimento, conforme decidido na decisão do caso Costeja, gera impactos pelo mundo inteiro. E mesmo nesse ano, por exemplo, a Corte Superior de Karnataka, na Índia, numa decisão sobre direito ao esquecimento, julgou procedente o pedido do autor, dizendo que o direito ao esquecimento é uma tendência de países ocidentais que afirmam esse direito para proteger a modéstia das mulheres. Acho que é importante levantar esse exemplo

para mostrar que diferentes países olham para essa figura, a qual me parece ser uma figura que mais atrapalha do que ajuda a tutela da pessoa humana, e, dali, buscam as mais diferentes de interpretações.

E falando justamente sobre essa efetividade, vale lembrar o chamado dano seletivo ou tutela fragmentada da pessoa humana, porque se o próprio enunciado do Conselho de Justiça Federal vincula o direito ao esquecimento à tutela da dignidade da pessoa humana, vale dizer - faço eco às palavras da Ministra Nancy Andrighi, em alguns dos seus votos no STJ, envolvendo o chamado direito ao esquecimento na *internet:* Que tutela fragmentada seria essa? Ou que dano seletivo poderia ser esse, em que um determinado conteúdo é removido de um determinado provedor, mas continua amplamente disponível no outro? Ou seja, a vinculação à dignidade da pessoa humana parece ser frouxa, no sentido de que o que o direito ao esquecimento oferece à pessoa humana é uma tela fragmentada, seletiva, parcial.

Caminho para o final da minha exposição, trabalhando com meus últimos quatro desafios ao direito esquecimento, nos quais serei rápido. O primeiro, o de nº 7, é o chamado Efeito *Streisand*. O nome vem em homenagem à atriz, cantora americana, que procurou remover a sua casa da *internet*, o endereço da sua casa da *internet*. Ao fazer isso, chamou mais atenção sobre onde era sua casa, o seu endereço. E curiosamente ou paradoxalmente, nós lembramos mais daquilo

que forçosamente somos obrigados a esquecer. E esse é o caso que nos defronta nessa situação que debatemos hoje e em tantas outras. Vale lembrar, o próprio Supremo Tribunal Federal tem um caso para decidir, o de uma professora de Minas Gerais, a qual procurou excluir uma comunidade do Orkut, a "Eu odeio o nome dessa professora". Nós só sabemos dessa professora e que foi criada uma comunidade com o nome dela porque ela ingressou com uma ação de remoção - e indenização - dessa comunidade da extinta rede social Orkut. Enfim, depois, em repercussão geral, o caso chega ao Supremo.

Muito rapidamente, não me deterei muito na questão sobre reescrever a história, porque outros expositores já falaram sobre esse tema.

Gostaria apenas de lembrar, na questão ligada a reescrever a história, que o recente informe do relator para liberdade de expressão da organização dos estados americanos, Edison Lanza, publicado no mês passado, que inclusive faz menção ao caso Aída Curi, que aqui discutimos, diz: "O Direito Internacional dos Direitos Humanos não protege e nem reconhece o chamado direito ao esquecimento, nos termos delineados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Ao contrário, a relatoria especial estima que a aplicação nos países americanos de um sistema de remoção e desindexação privadas de conteúdos *online*, com limites tão vagos e ambíguos, resulta particularmente problemática à

luz da ampla margem normativa de proteção da liberdade expressão constante do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos."

Já falamos da abordagem do Professor Eduardo Bertoni, diretor da agência de projeção de dados da Argentina, e gostaria de trazer também à colação a menção do relator especial à liberdade expressão no seu relatório recém-publicado.

Os meus dois últimos desafios ao direito ao esquecimento são: primeiro, fragilizar a liberdade de expressão. E aqui faço referência à jurisprudência crescente e recente desse Tribunal sobre a liberdade de expressão e também ao trabalho do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que, em um relatório específico sobre o direito ao esquecimento, leva à frente um comunicado importante em que diz que:

> "A melhor reação a um discurso ou a um relato considerado problemático é a resposta a ele na esfera pública; em vez de supressão ou tolhimento, mais discursos, mais versões, mais contraditório; essa é a praxe saudável de uma sociedade que se governa sob um estado democrático de direito."

E, por fim, fazendo uma última menção ao Marco Civil da Internet - já que alguns outros expositores falaram sobre ele -, gostaria de lembrar que a disposição do art. 7º, inciso X, é sobre o apagamento de dados ao final da

relação contratual na vida entre o usuário e um determinado provedor. Essa é a disposição expressa do art. 7º, inciso X, que diz:

> "X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei;"

Ou seja, estamos falando aqui de um direito a apagamento de dados. Não me parece que seja algo relacionado a esse conceito que aparenta trazer mais problemas do que soluções, que é o chamado direito ao esquecimento.

Com isso, eu peço desculpas por ter atravessado talvez um minutinho a mais do meu tempo regimental. E agradeço, mais uma vez, pela oportunidade de poder apresentar aqui esses comentários.

Para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre as pesquisas e as publicações do ITS-Rio sobre direito ao esquecimento, nós fizemos uma página especial para esta audiência pública - https://itsrio.org/pt/projetos/direitoaoesquecimento/. Lá vocês encontrarão bastantes materiais, vídeos, publicações sobre esse tema.

Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar desse debate.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço ao Prof. Dr. Carlos Afonso Pereira de Sousa por suas contribuições.

Agora, convido para falar pela Yahoo! do Brasil Internet Ltda., o Dr. André Zonaro Giacchetta, bacharel e mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo; especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da PUC, São Paulo; professor dos cursos de pós-graduação em Propriedade Intelectual e Direito de Entretenimento da Escola Superior da Advocacia e da Fundação Getúlio Vargas.

O SENHOR ANDRÉ ZONARO GIACCHETTA (YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA) - Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, Senhor Subprocurador-Geral da República Doutor Odim Brandão, demais autoridades, meus colegas advogados, e todos os presentes.

Em primeiro lugar, agradeço, como já feito aqui - mas não poderia deixar passar -, pela iniciativa de se tratar de maneira aberta e clara de tema tão importante; ainda mais quando nós imaginamos que esse tema é de inarredável intersecção com a *internet*.

Começaria, por aqui, a dizer e a lembrar de algumas coisas interessantes, especialmente, que há um projeto de lei na Câmara dos Deputados, de número 2.712, de 2015, que propõe já a alteração do aqui falado Marco Civil da Internet para se introduzir o conceito de direito ao esquecimento. Mas isso seria traduzir e inserir o direito ao esquecimento, diria a Vossas Excelências, da pior maneira possível, que é, como o meu colega Carlos Affonso mencionou, a

privatização do direito ao esquecimento. Eu vou me permitir ler, pois está dentro do rol de direitos de todos os usuários da *internet:*

> "XIV – remoção, por solicitação do interessado, de referências a registros sobre sua pessoa em sítios de busca, redes sociais ou outras fontes de informação na internet, desde que não haja interesse público atual na divulgação da informação e que a informação não se refira a fatos genuinamente históricos. (NR)"

Portanto, a se considerar essa proposta legislativa, estaremos diante da criação de um direito - se é que direito há - ao esquecimento, mas cuja implementação se dará absolutamente de maneira privada.

Também me lembraria que, pela atuação também em processos eleitorais relacionados à *internet*, muito tem se buscado, especialmente na esfera do Tribunal Superior Eleitoral, a interferência mínima, quando se trata de remoção de conteúdo na *internet,* justifica-se, dentre tantas razões, para se possibilitar o amplo debate e o acesso não só à má informação, mas para que os usuários possam ter o acesso a uma informação ou até à contrariedade daquela própria informação.

O que me parece, nessa breve introdução, é que o paradigma diante do qual estamos hoje trata quase que de uma polarização, mas nos esquecemos que, ao final de tudo isso, há situações que serão abarcadas na implementação do direito ao esquecimento das liberdades individuais. Muito se tem dito aqui a respeito de matéria jornalística, de fato jornalístico, mas - e aqueles que endereçam o direito ao esquecimento - não estamos falando exclusivamente de

fatos ou matérias jornalísticas, estamos falando também das liberdades individuais à expressão.

É extremamente comum que usuários ou cidadãos comuns, ao quererem manifestar sua opinião ou sua crítica a determinadas pessoas, façam referência a fatos antigos. Parece, portanto, que a abrangência daquilo que vier a ser indicado pelo Supremo Tribunal Federal não abrangerá exclusivamente questões relacionadas a matérias jornalísticas.

Farei menção aqui - encerrando esta breve introdução - que a Yahoo! Brasil, ao longo dos últimos anos, possui mais de 400 ações judiciais relacionadas exclusivamente a pedidos de remoção de conteúdo em seus mecanismos de busca. É interessante notar que muito se tem dado ênfase nos mecanismos de busca, como se fossem eles que pudessem oferecer algum tipo de solução no âmbito da *internet*, relacionado ao apagamento de fatos e de resultados.

Mencionaria, como já dito aqui, que este Supremo Tribunal Federal tem dado soluções adequadas, independentemente de se valer do chamado direito ao esquecimento. Embora se reconheça, em inúmeras decisões deste Tribunal, que a liberdade de expressão poderia usufruir de uma posição privilegiada, de onde várias outras liberdades dela emanariam, isso não significa tratar-se de uma liberdade ou de um direito absoluto que não possa ser, em algum momento, contraposto.

E aqui faria a observação também de que, quando se propõe o direito ao esquecimento, parece-me, Ministro, que se quer a fundamentalização ou a criação de um direito pós-ponderação. Então se trataria do final de um procedimento, de um exercício de ponderação entre direitos e liberdades, e se partiria da conclusão como o início de caminho para o direito ao esquecimento. Não se quer dizer com isso, é bom esclarecer, que cabe, sim, a todo cidadão o direito de requerer ao Poder Judiciário que se faça a avaliação da tensão entre direitos e liberdades, mas não parece haver necessidade nem mesmo conveniência para que se crie, de antemão, a ponderação desses direitos e dessas liberdades.

Algo que me parece também importante é que, quando vários se referem ao direito ao esquecimento, haveria uma única hipótese de aplicação, seria naquelas situações onde estaríamos diante de fatos públicos, verídicos, onde não haveria contemporaneidade em relação ao momento da divulgação, e que traria algum tipo de turbação moral, ou turbação aos seus titulares. Dito isso, parece-me que, até pelas decisões deste Tribunal, todas as demais hipóteses vêm sendo adequadamente tratadas, seja pelo reconhecimento da prevalência dos direitos à personalidade, seja a prevalência da liberdade de expressão e de informação, a depender do caso.

E a minha proposta, nesta segunda parte da apresentação, é tentar trabalhar quase como uma continuidade do que meu colega que me

antecedeu, Carlos Affonso, de dilemas associados exclusivamente ou essencialmente à *internet*.

Então, quando se fala do direito ao esquecimento, muito se diz da desindexação dos mecanismos de busca. Tem quem diga que isso se trataria do direito ao esquecimento procedimental; procedimental porque ele não vai no âmago do problema, porque ele não resolve, porque ele não traz o esquecimento e nem, de outro lado, traz a remoção definitiva daquele conteúdo.

Mas é bom que se diga que a afetação não é só de mecanismos de busca. Há afetação a toda e qualquer plataforma que possibilite aos usuários a disponibilização de conteúdo. Então, é importante contextualizar que não se trata exclusivamente de mecanismos de busca. E há algo extremamente importante. Todos nós usuários, enquanto utilizando determinado mecanismo de busca, temos uma justa expectativa de que aqueles resultados apresentados traduzam um resultado verídico, traduzam a integralidade daquilo que se tem disponibilizado através da *internet*.

Tenho aqui uma passagem do desembargador Ênio Zuliani do Tribunal de Justiça de São Paulo em que ele diz que, hoje em dia, a *internet* trabalha como se fosse o autor de uma biografia em turno de 24 horas a respeito de todos nós. Portanto, me pergunto, inclusive na questão da contemporaneidade, se o recente julgamento deste Tribunal a respeito das biografias não autorizadas, como

haveria a harmonização daquela decisão sobre contemporaneidade com o direito ao esquecimento. Uma vez que, se se decidir, se se entender que haverá esse direito ao esquecimento, a biografia não autorizada terá que ser contemporânea. Do contrário, não se poderia mais falar em biografias não autorizadas, independentemente de autorização, se traduzisse ou se se referisse a fatos históricos, a fatos não contemporâneos.

Portanto, eu gostaria de tratar aqui de pelo menos dois desafios bastante concretos e que dizem respeito à implementação de um direito que venha eventualmente a ser reconhecido. Como se disse, não é de hoje, há solicitações para remoção de conteúdo de toda ordem e de toda natureza. Mas aqui, para nossa reflexão, eu pensarei somente em dois desafios reais. A quem a ordem judicial, determinando o bloqueio, determinando a remoção de determinado conteúdo, deveria ser dirigida? Ora, se estamos tratando da turbação dos direitos da personalidade dos seus titulares, dirigir a ordem ao provedor da informação, ou seja, ele é só um mecanismo de busca, seja ele aquele que produz o próprio conteúdo, na primeira situação, no mecanismo de busca, me parece não haver a amplitude necessária na discussão sobre a veracidade do fato, sobre a contemporaneidade e sobre até o próprio caráter público daquela informação ou daquele conteúdo.

E é muito interessante notar que as ações judiciais hoje têm se dedicado a atingir quase que com exclusividade os provedores de serviço de *internet*. Não se tem buscado o verdadeiro autor do conteúdo. Não se tem buscado efetivamente o verdadeiro autor de determinada conduta ilícita. Se tem onerado o provedor de informação para que ele exerça direito de defesa em relação a conteúdo que ele não produziu. Parece-me que nessa situação a própria discussão a respeito da ponderação de direitos e liberdades, no caso concreto, será prejudicada. Ao passo que, se a demanda for dirigida àquele que produziu o conteúdo, ao próprio usuário que decidiu se manifestar e expressar o seu pensamento, teríamos garantida a amplitude, sim, da defesa, a possibilidade da defesa daquele conteúdo.

Parece-me, então, que, quando tratamos aqui de uma questão absolutamente corriqueira e pragmática de a quem deve ser dirigida a ordem judicial, nos deparamos com um problema que me parece de extrema gravidade. E há que se mencionar que, em muitas das vezes, Ministro Dias Toffoli, quando o provedor decide, de qualquer maneira, tentar ampliar ou dar à discussão, sobre remoção de conteúdo, a amplitude necessária, muitas vezes se vê tolhido ao se afirmar que não cabe ao provedor, ao mecanismo de busca, ao provedor ou à plataforma digital, não cabe a ele dizer se aquele conteúdo é lícito, não cabe a ele dizer se ele é verídico, se ele é contemporâneo. Portanto, se está diante de uma

situação na qual o provedor se vê tolhido e a própria discussão, igualmente, tem a mesma destinação.

E a segunda observação, muito rápida, é: Qual seria o conteúdo dessas ordens e o que se observa hoje, do ponto de vista pragmático? Então, pensando aqui no mecanismo de busca, algo que tem sido extremamente comum é o pedido, aos autores, do bloqueio de palavras chaves. Então, seria o exemplo de bloquear a palavra pedofilia, a palavra ou nome de uma determinada pessoa. Existem inúmeros casos onde o pedido é que o resultado sequer indique a existência daquela pessoa.

Então, é como se - lógico que nós estamos falando aqui do extremo - não houvesse qualquer informação, qualquer conteúdo a respeito de determinada pessoa. E a consequência é muito grave. Imagine que se esteja aqui diante de uma ordem judicial que proponha o bloqueio da palavra, do nome, ou do André Jaqueta, relacionado a audiência pública. Eu não só eliminaria resultados que trariam algum tipo de desconforto a mim, mas eliminaria resultados que não guardam qualquer relação com o tema em discussão. Parece-me, então, que o bloqueio - de forma muito pragmática - de palavra-chave poderia trazer consequências muito graves. Ao passo que o Marco Civil já trouxe uma solução interessante, no seu art. 19, quando diz que, visando assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, impôs a necessidade de ordem judicial para se

obrigar a remoção de qualquer conteúdo ilícito. Então, por mais que não haja previsão específica, o Marco Civil, o legislador infraconstitucional já impregnou o próprio Marco Civil com a ponderação, ou indicando que há, no caso a caso, a necessidade dessa ponderação.

Eu iria para o último aspecto, que é o bloqueio de palavra-chave associada a um determinado fato.

Então, imaginemos aqui que, diante do paradigma, determinássemos, aos mecanismos de busca, o bloqueio da expressão Aída Curi e crime em Copacabana. Certamente, aquilo que todos nós veríamos abrangeria não só aquilo que os autores, os seus herdeiros, não gostariam de ver, mas também eliminaríamos a possibilidade de acesso a dezenas, eu chegaria a afirmar, centenas de resultados que não guardariam relação com a turbação indicada pelos titulares.

Eu só faço menção aqui - e com isso finalizando - a algumas decisões judiciais espalhadas pelo Brasil, que têm enfatizado que a solução dessa tensão permanente entre direitos e liberdades tem se dado de maneira casuística.

Finalizo dizendo que a discussão, novamente, não se atém a este caso paradigma, porque estamos dentro de um mundo dinâmico. E, no dinamismo da *internet*, não se pode imaginar que o usuário, diante da expectativa de veracidade e integralidade do resultado, e mesmo das consequências desses dois

aspectos - a quem a ordem deve ser dirigida e qual a extensão e abrangência da própria ordem - não vá gerar efeitos bastante graves no ambiente da *internet*.

Com isso, agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui diante de Vossas Excelências.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço as palavras do Dr. André Giacchetta.

Agora, convido para falar, pela Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Conselheiro Coriolano Aurélio de Camargo Santos, que é doutor em Direito e certificado internacional em Direito Digital pela *Caldwell Community College and Technical Institute*; além de Professor e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito Digital e *Compliance* da Faculdade Damásio. Também Vossa Excelência terá quinze minutos.

O SENHOR CONSELHEIRO CORIOLANO AURÉLIO DE CAMARGO SANTOS (SECCIONAL DE SÃO PAULO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL) - Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, Excelentíssimo Subprocurador-Geral da República Odim Brandão, Excelentíssimo Senhor Juiz Instrutor Richard Pae Kim, Excelentíssima Senhora Secretária Ravena Siqueira. Eu presido, na OAB/São Paulo, Excelência, a Comissão de Direito Digital e Compliance e, lá, juntamente com a TV Cultura, por ordem do nosso Presidente Marcos da

Costa e do nosso Vice-Presidente Fábio Romeu Canton, realizamos um estudo que se reverteu num programa de televisão sobre o Direito ao Esquecimento. E chegamos à conclusão que diversas famílias, no conceito puro de dano moral, vêm sofrendo dores, angústias e aflições, que atingem a sua esfera íntima e valorativa, e que possui uma repercussão no tecido social, na nossa consciência ética coletiva. E esse conteúdo necessita, em algum momento, ser retirado das redes sociais. O caso Aída Curi se trata, realmente, de um caso emblemático, que temos acompanhado com muito cuidado e temos algumas ponderações a fazer. Por orientação, de algum dos nossos integrantes, será que nós não poderíamos propor uma medida conciliatória, Excelência, entre o veículo de comunicação e a família. Por que a família não foi chamada previamente, como diz Bauman: "o senso de pertencer"? Por que a família não foi integrada no debate, nessa era da conciliação que nós vivemos?

Falando do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o Desembargador Carlos Teixeira Leite Filho e o Desembargador Francisco Eduardo Loureiro declararam inconstitucional o Marco Civil da Internet. Se nós seguirmos a jurisprudência anterior do Superior Tribunal de Justiça, ao notificarmos o Facebook, ao notificarmos Yahoo!, ao notificarmos o Google para remoção ou desindexação de um certo conteúdo, nascia ali o momento da Responsabilidade Civil. As empresas não podem fazer um filtro mínimo do conteúdo ilícito que sobe

todos os dias nas redes sociais? Pela primeira vez na história, nós temos, no artigo 1º, a defesa, a proteção da dignidade da pessoa humana. E, na discussão, aqui, nesta Corte, dos temas relativos à proteção da família homoafetiva, nós percebemos que a Corte trouxe o princípio da dignidade da pessoa humana como regra de aplicabilidade imediata. O direito ao esquecimento é um valor constitucional como o valor da família homoafetiva, como o valor do cidadão de poder gozar uma vida plena. Shakespeare dizia que a verdade é como o cristal, depende do lado que enxergamos através dele. Mas o importante, dizia Shakespeare, é que o homem não perca a pureza do seu olhar. O cristal representa a força do homem que foi perdida. Cada um de nós sente, na sua esfera moral, por um determinado ângulo desse mesmo cristal. O esquecimento, dizia Albert Einstein: "quero ser deixado em paz." Huberto Rohden, filósofo brasileiro, catarinense, perguntou ao seu Professor Einstein: "Professor, o que queres dizer com sua frase emblemática de penso noventa e nove vezes e nada descubro"? Então, mergulho num profundo silêncio e a verdade me é revelada". Einstein disse: "No meu silêncio, na minha solidão, quero ser deixado em paz, tenho o direito ao meu silêncio ". E o que é verdade senão o som das palavras? A verdade pode ser escrita num pedaço de papel? Ou a verdade é aquela que você sente no fundo da sua alma? E o Direito não é isso, o nosso sentimento de justiça?

A Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil reconhece o direito ao esquecimento como um valor, um valor constitucional do homem, que precisa ser balizado, precisa ser tutelado por esta Corte. E Lhering dizia que devíamos lutar não pelo miserável objeto do litígio, mas, sim, por um fim ideal, de paz, equilíbrio, solidariedade e, principalmente, pela afirmação da nossa, da nossa própria pessoa e do nosso - cada um tem o seu -, do nosso sentimento de justiça. Por isso, Excelência, somos tão complexos.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço ao Dr. Coriolano Aurélio de Camargo Santos.

Tivemos a sequência de seis Expositores, vou fazer um breve intervalo, temos ainda mais três escritos e, também, a finalização com o Dr. Odim Brandão, Subprocurador-Geral da República.

Declaro suspensa a audiência pública.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Boa tarde a todos! Vamos sentar. Declaro reaberta esta sessão de audiência pública. Dando continuidade às exposições, passo agora a palavra, neste momento, para o Prof. Dr. Pablo de Camargo Cerdeira, que fala em nome do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. O Expositor é advogado formado pela Universidade de São Paulo, Professor e

Coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV/Rio. Terá quinze minutos.

O SENHOR PABLO DE CAMARGO CERDEIRA (CENTRO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DA ESCOLA DE DIREITO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS DO RIO DE JANEIRO) - Muito obrigado. Boa tarde, Ministro, Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli; Excelentíssimo Subprocurador-Geral Odim Brandão; Doutor Richard Kim; Doutora Ravena Siqueira.

É um prazer estar aqui, novamente. Tive a oportunidade de estar na semana passada quando a gente discutiu a questão do WhatsApp, o bloqueio e o direito ao uso da criptografia. Gostaria de ressaltar, Ministro, a importância que tem esta realização de audiências públicas para nós que somos da academia e para toda a sociedade. Essa abertura do Supremo não só na influência na tomada de decisão, mas, no processo de construção das suas decisões, é importantíssimo não só para a legitimação de todo o processo que a gente já tem mais presente, naturalmente, no Executivo e no Legislativo, mas também no Judiciário. Um antigo Presidente desta Corte dizia que o Supremo não julga com os pés na Lua. E, enfim, isso parece que vem se tornando cada vez mais presente, com o Supremo atuando na questão da dignidade da pessoa, inviolabilidade do lar, casos muito importantes com impactos diretos na nossa sociedade.

Eu vou começar, Ministro, falando que é uma tarefa muito difícil falar sobre direito ao esquecimento, se é que existe o direito ao esquecimento. Vou endossar essa linha, sem falar de casos específicos.

Nós estamos tratando do caso da Aída Curi, mas esta decisão que vai ser tomada pelo Supremo afetará toda a nossa sociedade.

Mas eu gostaria de começar com um passo atrás, Ministro.

A Professora Ada Pellegrini, recentemente em um evento, estava alertando sobre a necessidade de como as decisões jurisdicionais precisam ser efetivas, é do papel do magistrado tornar efetiva suas decisões, para que o Direito, de fato, exerça o seu papel na sociedade. Então, não apenas julgando os textos frios da lei, mas preenchendo as lacunas que o tempo e o legislador deixaram, mas também cuidando para que as suas decisões sejam amparadas na realidade que cerca a nossa sociedade. Isso aconteceu no caso da anencefalia; aconteceu no caso do casamento homoafetivo.

Mas eu queria começar falando sobre uma diferença muito grande... A minha área é especificamente trabalhar a tradução da tecnologia. Já trabalho com tecnologia mesmo, com programação, com banco de dados há muitos e muitos anos, programando, mesmo, computadores, e posso falar com bastante propriedade da distinção entre o mundo da tecnologia da *internet* e o mundo para o qual foi feita a legislação que nós temos às mãos para fazer o julgamento deste

caso. Então, o meu foco, ao invés de tratar das questões como os artigos 18 e 19 do Marco Civil, que tratam da responsabilidade no caso de remoção de conteúdo, vou me focar especificamente nos artigos 5º, 10 e 12 da Constituição, que tratam do direito à privacidade, focarei mais na tentativa de traduzir a tecnologia para o direito, para compreendermos as diferenças entre cada um desses ambientes.

Eu represento o CTS - Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas -, que é considerada a 9ª *Think Tank* no mundo, hoje, em desenhos de políticas públicas, a primeira na América Latina já há 8 anos. Começarei com esta distinção, Ministro: o direito à vida privada *versus* direito à informação e à liberdade de expressão.

Eu não vou entrar nos detalhes de cada um dos artigos citados, mas tem-se colocado a discussão como se fosse casos antagonistas, casos opostos em que vai se prevalecer ou o direito à informação ou o direito à vida privada. Mas, de fato, todos os casos que a gente for analisar de direito ao esquecimento ou de remoção de conteúdo, eles vão se enquadrar mais ou menos em uma outra categoria. A gente não tem uma forma, hoje, de definir, no caso de um conflito de princípios como esse, e a gente tem que se valer de Alexis para resolver isso. Quanto mais intensiva uma intervenção em um direito fundamental, dizia ele, tanto mais graves devem ser as razões para que a justifiquem. Então, em um caso que envolve

um conflito de princípios como esse, a gente teria que analisar caso a caso, individualmente, e ver qual o conflito, qual direito mais afetado.

Eu vou me focar mais a partir daqui. Serei bastante objetivo.

Nossa legislação e nossa formação jurídica foram todas voltadas para esse ambiente pré-*internet*. Nesse ambiente pré-*internet*, a gente tem poucos atores produzindo conteúdo - os jornalistas, enfim -, poucos distribuindo conteúdo, poucos armazenando esse conteúdo - estou fazendo referência às bibliotecas -, poucos indexando esse conteúdo - os bibliotecários e o âmbito restrito da indexação. A indexação ficava restrita à biblioteca ou ao jornal, enfim.

Hoje a gente tem uma realidade absolutamente diferente. Qualquer pessoa produz conteúdo; tira uma foto com *smartphone;* grava alguma coisa; coloca em uma rede social, ou um blog, ou um ambiente que vá fazer a distribuição; armazena isso de forma dispersa. Eu, quando salvo um dado no Google ou no Facebook, não necessariamente estou salvando em uma máquina no Brasil e nem necessariamente em uma máquina nos Estados Unidos. Eventualmente, embora minha conta seja no Google, mas o *data center* dele está no Chile por uma questão de proximidade de cabos, enfim, de conexões. Talvez o meu dado esteja sendo armazenado no Chile ou qualquer outro país, enfim. Esse ambiente exige essa pluralidade...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Muitas redes sociais dizem que elas mesmas não sabem onde ficam armazenados os dados.

O SENHOR PABLO DE CAMARGO CERDEIRA (CENTRO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DA ESCOLA DE DIREITO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS DO RIO DE JANEIRO) - Muitas vezes não sabem, quando trabalham com CDNs. Você contrata terceiros para replicar o seu conteúdo, exatamente para reduzir o seu tráfego. Então, se eu coloco um vídeo no YouTube, por exemplo, e esse vídeo começa a ter muito acesso, por alguma razão, na Índia, existem prestadores de serviço - a Akamai, por exemplo, é uma dessas prestadoras que a gente não conhece, o grande público não conhece, mas que ela pega aquele conteúdo de um vídeo que eu coloquei no YouTube, e, enfim, se ele está com um grande acesso na Tailândia, por alguma razão, ele vai copiar para uma máquina na Tailândia e as pessoas da Tailândia vão acessar de lá, não estão nem acessando a máquina no Brasil ou nos Estados Unidos. Essa é uma estrutura que faz com que a *internet* funcione da forma que ela funciona hoje.

E essa indexação tem que ser automática. Vou mostrar o porquê. O modelo para *internet* era uma cadeia bem delimitada: produtor, distribuidor e sociedade. Na internet, a gente tem um fluxo bastante diferente: a pessoa que produz conteúdo pode escolher uma série distribuidores e o usuário final pode acessar esse conteúdo, tanto direto daquele estão distribuindo, seja WhatsApp, seja

Facebook, seja qualquer ambiente, quanto através de indexadores. E aí a gente está falando de um Google, de um Yahoo, de um Bing; são *sites,* as ferramentas que varrem a *internet* para indexar conteúdo.

A nossa estrutura tradicional - usei essa imagem na audiência pública sobre do WhatsApp - era baseada nessas redes de estrela, a gente chama de topologia de rede isso, a topologia de estrela. Você tem um ator central que controla como é feito o tráfico dessa informação.

No caso da *internet*, a nossa topologia algo desta forma: absolutamente distribuída, com os nós espalhados por todo lado, um fazendo ligação com o outro, que não tem um órgão administrador, um agente administrador central.

Por isso, a melhor forma de indexar esse modelo, foi o que fez o Google virar um sucesso, como virou, foi o *pagerank*. O *pagerank,* na verdade, é um modelo de indexação e classificação de conteúdo, hoje já evoluiu, está usando um outro modelo, um outro algoritmo, decorrente desse, mas bem mais avançado, que é segredo inclusive, eles não revelam qual é, mas funciona da seguinte forma: se eu, Pablo, coloco num blog pessoal uma determinada matéria, meu blog tem baixo índice. Se o Google passar no meu blog ver que eu estou citando fulano de tal, essa citação a fulano de tal vai aparecer de forma muito pouco relevante no ranking. Agora, se um outro *site,* como um *site* UOL, Ig, Globo publica a mesma matéria,

esses são *sites* com um grande peso, porque outros *sites* replicam muito conteúdo daquele *site*. Com isso, se cria uma rede em que a relevância do conteúdo é dada pela quantidade de acessos que aqueles *sites* recebem e a quantidade de interreferências, interlinks entre esses materiais - é mais ou menos o que está ali.

Se por acaso - nesta nessa ilustração - o meu *site* passar a receber muitas referências, ele for muito compartilhar no Facebook, no YouTube, em outros locais, o meu ranking sobe, e, aí, qualquer publicação que eu coloco lá ganha mais relevância.

Isso permitiu a criação dos primeiros mapas que a gente consegue fazer sobre as relações entre *sites* na internet. Esse é um mapa feito através desse tipo de correlação entre citações de conteúdo, é uma *open source*, uma *Internet map*, que mostra os principais *sites* em tamanho do círculo e os outros *sites* próximos que fazem referência àquele.

É importante notar que o Brasil está lá em baixo, pequenininho, mas os seus *sites* estão também espalhados - se repararem a cor laranja aí, a do Brasil -, eles aparecem também no meio de *sites* dos Estados Unidos, no meio do *site* da Europa, porque algum *site* eventualmente dos Estados Unidos referenciou uma matéria que saiu talvez no Uol, no Globo.

Reparem só que a China é o único país que aparece bem mais isolado do lado esquerdo, quase sem referência, porque a China é o único país que

conseguiu adotar um modelo de segregação de sua internet quase 100% efetivo, é possível burlar, mas a China consegue fazer com que os seus *sites* não estejam misturados ali esse conteúdo.

E aí vem a questão: Como cumprir decisões atreladas a jurisdições específicas, no caso, do direito ao esquecimento, que, na verdade, é o direito à remoção? Porque de direito ao esquecimento, enfim, eu tenho direito a esquecer, eu esqueço que eu quiser, eu não posso ser obrigado, não é uma obrigação, não é um direito de esquecer em relação ao outro - não é? -, como o Carlos Affonso já alertou aqui. Como se vai determinar um direito à obrigação de remoção de conteúdo que estão espalhados nesse que é o mapa-múndi da *internet* de fato? Seria preciso disparar, enfim, cartas precatórias para todos países envolvidos que tenham conteúdo que talvez a gente nem saiba para conseguir algum tipo de efetividade.

O segundo ponto: como evitar a distribuição e indexação para o futuro? Tem alguns números sobre a quantidade de conteúdo produzido na *internet* todos os dias. São 4 bilhões de postagens no Facebook, enfim, os números por aí vão, 830 milhões de *sites* novos todos os dias. Isso tudo é o que precisa ser indexado, a cada dia, pelas ferramentas que fazem a indexação de *websites. S*ignifica que isso não é feito por humanos, mas por robôs, por algoritmos que estão varrendo esse conteúdo e fazendo aquela classificação que comentei anteriormente. Se uma

decisão judicial determinar que casos, como o de Aída Curi, não podem ficar indexados e não podem estar na internet. A indexação e o conteúdo são ser retirados da internet. Nós teríamos aquele primeiro problema da efetividade da jurisdição e um segundo problema que seriam matérias que citem casos polêmicos ocorridos no Rio de Janeiro e, lá no meio, tem o de Aída Curi, esse também seria desindexado, cerceando a liberdade, cerceando o direito à informação de outros. Não há menor possibilidade de uma pessoa ficar filtrando, humanamente dizendo que isso é um conteúdo afeta a Aída ou não. Delegaríamos para robôs essa censura de conteúdo na internet. Isso é extremamente perigoso, na visão do Centro de Tecnologia e Sociedade.

O modelo onde funciona a distribuição de conteúdo da internet é muito parecido com nossa própria memória. Eu gosto de fazer essa analogia para ficar mais claro. Como o conteúdo é todo espalhado pela internet, com relações, e quando o mesmo conteúdo é reforçado por outros *links*, esse conteúdo se consolida. Para explicarem a analogia do funcionamento do cérebro, costumam dizer que um gramado, porque, quando muita gente passa em um determinado caminho, vai marcando o gramado. Nossa memória funciona da mesma forma, quando lembramos muito de um determinado assunto, aquilo vai se fixando, e o que não lembramos com muita frequência vai se apagando. O ranqueamento de conteúdo da internet funciona exatamente da mesma forma. Aquele conteúdo que está

sempre sendo reciclado, ou comentado, aparecerá naturalmente no começo, e o que não for, ao longo do tempo, ficará para trás.

E aí entramos em dois aspectos que estão de fato por trás do direito ao esquecimento. Primeiro, é a remoção, impedir que o conteúdo chegue à internet; e, o segundo, impedir a circulação desse conteúdo. Como podemos impedir que o conteúdo violador seja disponibilizado em redes sociais, *blogs* e *website*? Como retirar esse conteúdo, uma vez que ele já tenha sido armazenado? Impedir a circulação, caímos naquele outro problema, o qual estava mapeando, das conexões muito diversas que formam a internet.

Dois modelos foram propostos, um é o *notice and takedown*, que se discute muito se administrativamente os indexadores podem retirar o conteúdo; e o outro é a ordem judicial. O Brasil optou pela ordem judicial no Marco Civil, afastou o *notice and takedown* exatamente pelos riscos de delegar a um ente privado o controle de fato, a censura da circulação de conteúdo na internet, e optamos por deixar esse complexo arranjo de prevalência de princípios na mão do Judiciário. Resolvemos o primeiro problema, mas não o segundo, que será a efetividade de qualquer decisão que reconheça o direito ao esquecimento de forma geral e restrita. Claro, em algumas decisões, não tenho a menor dúvida, os atores envolvidos batalhariam para torná-la efetiva. Quando se fala de crimes muito violentos, como

o caso citado agora há pouco, de pessoas jogadas na linha do trem, ou casos de degola por terroristas, eu não tenho dúvida que, se o Judiciário determinar a retirada do conteúdo, os atores envolvidos farão o maior esforço para impedir que esse conteúdo circule. Agora, ao determinar a retirada de sutilezas com relação ao conteúdo de um fato - o caso Aída é um exemplo desse -, como separar o que causaria danos à família, que causaria danos a esse direito ao esquecimento, daquele conteúdo que seria meramente informativo, ou que seria meramente de pesquisa acadêmica, que lista fatos criminosos ocorridos no Rio de Janeiro, na década de 1950? Isso é impossível de ser feito, hoje, essa distinção de forma automática. A única forma que vejo de fazer prevalecer um direito à retirada de conteúdo, e não direito ao esquecimento, seria em casos pontuais em que o interesse de retirada seja maior, inclusive, da sociedade, e não só dos indivíduos envolvidos, do que o direito a ter acesso a esse conteúdo.

Enfim, encerrando, fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Muito obrigado Prof. Dr. Pablo de Camargo Cerdeira.

Convido, agora, o Prof. Dr. Alexandre Pacheco da Silva, Professor e Coordenador do Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas.

O SENHOR ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (GRUPO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS) - Boa tarde a todos!

Queria, enfim, fazer um primeiro registro do privilégio de estar aqui e de acompanhar as discussões ao longo do dia. Tenho aprendido profundamente a respeito dos debates. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, na pessoa do Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli e dos demais Membros da Mesa.

Gostaria de reforçar que o Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação é um grupo que funciona como um braço da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, que busca entender, em primeiro lugar, qual é o relacionamento e quais são os problemas derivados da relação entre Direito e novas tecnologias; e, em um segundo momento, entender quais são os impactos que não apenas novas tecnologias, mas novos comportamentos sociais advindos da nova tecnologia podem impor a meios de comunicação e a dinâmicas sociais.

Nesse sentido, a minha apresentação aqui diz respeito, em primeiro lugar, a não coincidir com vários dos argumentos que foram trabalhados

aqui, mas tentar fazer a árdua tarefa de agregar, adicionar algum ponto novos. Dentre eles, um ponto que para nós é muito caro: entender qual é a relação entre narrativas - e aí pensando a ideia do interesse jornalístico como "coração" do caso que está sendo discutido agora - e democracia, como um ponto introdutório da minha fala.

Em um segundo momento, vamos entender qual seria a regra a ser pleiteada, aqui no caso em questão, relacionada a direito ao esquecimento. Eu e outros pesquisadores do Grupo elaboramos um enunciado não para dizer que o direito ao esquecimento é um direito tutelado pelo ordenamento jurídico, mas para entender quais seriam os elementos dessa regra, caso uma vez nós a realizássemos, em uma ponderação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da liberdade de expressão. Conseguimos extrair, pelo menos, a regra que vem sendo debatida do ponto de vista do direito ao esquecimento.

Quero discutir também as condições de aplicação dessa regra e as condições com relação às quais, dentro dos fatos do caso, nós conseguiríamos ponderar elementos necessários para uma tomada de decisão. Nesse sentido, a nossa contribuição dará um elenco de critérios que podem ser utilizados para uma decisão posterior.

Então, nesse sentido, acho que a primeira ponderação que pode ser feita aqui é em relação a um caso já mencionado e debatido aqui, mas uma ideia

que escapou dos debates, tanto da manhã quanto da tarde, que é o caso das biografias não autorizadas.

A Ministra Cármen Lúcia menciona na sua decisão, sendo ecoada por outras decisões como a do Ministro Barroso, que a ideia dentro de uma democracia é que o fluxo não apenas de ideias, mas de reflexões, de ponderações, de opiniões sobre determinados assuntos, dentro de um ambiente democrático, deve respeitar não só um princípio da liberdade de expressão, mas uma ideologia de "mercado livre" de ideias. O que é esse "mercado livre" de ideias? É a possibilidade de que narrativas sobre um determinado fato possam conviver e, em alguma medida, competir, dentro da esfera pública, por um sentido não só do convencimento puro e simples, mas por um sentido de verdade para fins relações sociais.

Nesse sentido, eu vou resgatar essa ideia de "livre mercado" de ideias, para ponderar algumas questões que vou orientar em relação ao que nós conseguimos extrair, dentro dos autos, de uma regra possível pleiteada de direito ao esquecimento.

Nesse sentido - para já passar para o meu segundo ponto -, qual seria a regra de direito ao esquecimento? Eu vou me dar a liberdade aqui de poder ler o que seria esse anunciado do direito ao esquecimento, pelo menos, pleiteado para fins do debate que a gente vem travando ao longo do dia. A regra é a seguinte:

Se a divulgação de um determinado fato causa sofrimento psicológico a uma pessoa ou a um grupo, e não há vantagens que justifiquem essa divulgação, então a pessoa ou o grupo se pode requerer a restrição de acesso ou uso de informações sobre o fato. Então a ideia que podemos discutir - como muito bem debatido ao longo do dia, principalmente na parte da tarde - é o acesso a determinado conjunto de informações e fatos, quando se fala em direito à desconexão, em fenômenos voltados ao ambiente digital, ao ambiente virtual, à *internet* em si, ou podemos discutir o uso de fatos e informações para a construção de uma narrativa.

E uma primeira pergunta que já se fez, e já se respondeu muito bem na primeira parte da manhã: a veiculação do programa Linha Direta causa sofrimento aos familiares de Aída Curi? Penso que ficou muito claro de manhã, não só por elementos que podem prejudicar a saúde de familiares ou outros que, em alguma medida, mostram que esse sofrimento foi manifestado de várias formas, não apenas pela propositura de uma ação relacionada ao tema; dá para pensarmos que, num sopesamento, o sofrimento existe e precisa ser levado em consideração.

Agora, num segundo ponto, uma pergunta que busquei, ao longo do dia, para tentar encontrar uma resposta, e essa talvez seja a ideia da nossa adição para fins desta audiência: há alguma contribuição trazida pela veiculação do programa Linha Direta para o debate público? Quando menciono uma vantagem, qual seria a efetiva contribuição do formato e da narrativa criada pelo

programa Linha Direta-Justiça para o debate público? E, na nossa visão, há pelo menos duas contribuições claras que eu gostaria de ressaltar aqui e trabalhá-las pormenorizadamente, tendo em vista essa ideia de um livre mercado de ideias.

A primeira contribuição é a de narrativa de alerta, ou, como em alguns ordenamentos jurídicos de língua inglesa fazem alusão, inclusive na teoria literária, de *cautionary tale*. A ideia de uma narrativa que traz um alerta sobre um determinado tipo de comportamento, história ou perigo a ser observado. Podemos pensar desde contos voltados à nossa infância, como "O Pedro e o Lobo", a obras literárias, por exemplo, que tenham o mesmo propósito, como a obra literária "O Crime do Restaurante Chinês", do historiador Boris Fausto, que possui elementos muito próximos da forma como foi contada a história do Linha Direta Justiça, da forma como foi estabelecido o Linha Direta-Justiça.

E qual é a função de uma narrativa alerta? A ideia é abstrair elementos de uma narrativa que pode ter vazão em fatos históricos, pode ter vazão em fontes fidedignas, pode valer-se de recursos relacionados a fatos verdadeiros, mas também à ideia de que ela tem uma mensagem a ser estipulada ao final da narrativa, ao final da história.

E qual seria a mensagem? Eu vou aproveitar para ler um trecho, que está disponível no *site* do programa Linha Direta, a respeito do caso Aída Curi, que sintetiza, na minha visão - e podemos avaliar se positiva ou negativamente -, a

mensagem a ser passada pelo programa. E podemos dizer se concordamos ou não com a mensagem, mas que existe um propósito na narrativa, nós conseguimos extrair dali:

> "Apesar de receber visitas da mãe, Aída praticamente não teve contato com o mundo exterior. Inocente, casta e religiosa, ela se tornou um alvo fácil para os rapazes da chamada 'juventude transviada', que começava a despontar em Copacabana. Entre eles o playboy Ronaldo Guilherme de Souza Castro, 19 anos."

A síntese que permeou toda a narrativa criada pelo programa Linha Dire-a Justiça, a ideia por trás dessa narrativa era: de um lado, você tem uma moça que, para os fins da leitura que se fazia da sociedade carioca na década de 50, era uma moça não apenas de grande respeito - sem fazer nenhum juízo de valor diante dos fatos e das transformações que a sociedade ali passou -, mas dá ideia de oposição entre essa menina e alguém que poderia, vamos dizer assim, cumprir os requisitos e as características do estereótipo de um *playboy*, alguém mal intencionado, que, por fim, acabou ocasionando o ato trágico que todos nós discutimos e sentimos hoje, ao longo da manhã e da tarde.

Então nesse sentido dá para perceber que existia não apenas uma mensagem, mas que ela respeita uma estrutura narrativa própria dessas histórias em que se gera um alerta. Portanto, ao perguntar se há uma contribuição ao debate público, do ponto de vista do conteúdo dessa mensagem, dá para

perceber que podemos estabelecer vários traços de conexão com outras histórias, mesmo que ela possa não ter sido da melhor forma contada, mas que, desde que ela respeite fatos e fontes fidedignas, nós devemos nesse sentido respeitá-la.

E mais do que isso. A estrutura não apenas exclusiva do programa referente ao Caso Aída Curi, mas de vários outros programas Linha Direta-Justiça, e o próprio Linha Direta, como uma linha mais ampla, era a ideia de que existia ali uma crítica ao final do programa voltada a, por exemplo, problemas relacionados ao sistema de Justiça Criminal. Seja por vezes porque se constatava a não punição, a não sanção ali a quem se consideravam suspeitos, mas, para fins de programa, muitas vezes eram apontados como reais autores de um determinado crime, seja porque, por um detalhe processual, não se puniram determinados suspeitos que o programa poderia levar a crer, pelos fatos e outras opiniões ali envolvidas no caso, não efetivamente sancionou aquelas pessoas. Então, essa crítica também, por mais que nós possamos ser a favor ou contra, estava presente dentro do caso concreto.

Nesse sentido, eu consigo já fazer uma conexão direita com a terceira condição de elementos dessa potencial regra que a gente consegue abstrair dos autos do caso, que seria uma terceira condição para um potencial direito ao esquecimento, que seria se a vantagem traída por essa contribuição ao debate

público, que o programa tenta que ensejar, supera o sofrimento imposto pela divulgação do fato ou pela divulgação dessa narrativa propriamente dita.

Na nossa visão, a gente tem que levar em consideração fatores e critérios já expostos ao longo tanto da manhã quanto da tarde, dentre eles, o contexto da mensagem, a adequação do formato da mensagem, a contribuição pretendida, o alcance do programa e a influência do fato narrado ao cotidiano da audiência.

Uma das coisas que a gente pode pensar é que a mensagem em si pode ter um papel significativo para a sociedade como uma história universal que consegue ter um parâmetro transversal entre as mais diversas histórias que a gente pode pensar, desde contos infantis até, por exemplo, registros históricos que se misturam ali com uma parcela de ficção, como o caso do "Crime do Restaurante Chinês", obra literária de Boris Fausto.

Então, nesse sentido, cabe-nos perguntar se a história de Aída Curi, independentemente do tempo em que ela ocorreu, se essa história não tem elementos pelos quais nós podemos ali pensar que ela servirá para novas gerações. Mesmo que a gente possa considerar que a sociedade tenha se transformado ao longo do tempo, ela traz elementos que podem trazer um alerta para populações que ainda não se viram frente à frente com casos que, por mais que trágicos,

invariavelmente podem implicar ali aprendizado para parcelas significativas da nossa população.

Por fim, eu vejo que meu tempo já está se esgotando, passando para meu terceiro ponto, vale à pena pensar o quanto que as transformações na sociedade têm trazido dificuldades para a gente trabalhar narrativas, como muito bem explorado pelos meus antecessores aqui.

Em primeiro lugar, essas narrativas concorrem hoje, só que concorrem a partir de tecnologias e formatos de caminho e acesso a determinadas mensagens muito distintos de uma era pré-*internet*. Nesse sentido, cabe-nos indagar aqui até que ponto uma intervenção judicial relacionada à contenção desse tipo de conteúdo no final das contas poderia sequer ser efetiva, olhando na verdade a contribuição que ela, em si, já pode dar, mesmo que nós achemos que, pelo nosso gosto pessoal, eventualmente um programa como esse não merecesse a nossa audiência, não merecesse o nosso tempo.

Então, para concluir aqui a minha intervenção, acho que vale à pena a gente pensar em não repetir no final das contas algumas percepções que a gente tem a respeito de um debate abstrato em relação à liberdade de expressão e ao princípio da dignidade da pessoa humana, mas nos questionar se não há uma contribuição efetiva daquele conteúdo, se, no final das contas, o sofrimento, tendo em vista que um dos próprios familiares da Família Aída Curi também já conseguiu

criar a sua própria narrativa ao explorar determinadas obras tratando ali do tema, dos fatos relacionados ao caso da irmã, mas uma das coisas que nos chama muito a atenção é a ideia de que hoje, para nós pensarmos numa sociedade democrática, não apenas o Poder Judiciário, mas o ordenamento jurídico como um todo, tem que se resguardar da possibilidade de garantir ali com que narrativas possam concorrer entre si. Nesse sentido, independentemente da nossa opinião específica sobre uma narrativa, eu e, acredito, uma parte significativa de pesquisadores que não apenas trabalham comigo, mas dialogam conosco, lá, na FGV, São Paulo, conseguem extrair uma mensagem clara dentro do conteúdo disponibilizado pelo Programa Linha Direta Justiça.

É isso. Eu queria agradecer muito ao privilégio de poder estar aqui e, muito, ao privilégio de poder acompanhar as discussões ao longo da manhã e da tarde. Para nós foi um momento muito importante e emocionante para fins, aqui, do Grupo de Ensino e Pesquisa da FGV, em São Paulo.

Obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço ao Doutor Alexandre Pacheco da Silva, Professor e Coordenador do Grupo de Ensino e Pesquisa de Inovação da Escola de Direito de São Paulo da FGV.

Agora, a última expositora que vamos ouvir. Trata-se da advogada, professora e pesquisadora, Drª Mariana Cunha e Melo de Almeida Rego,

bacharela em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela New York University, Doutoranda em Direito pelo UniCEUB. Também terá seus quinze minutos para a exposição.

A SENHORA MARIANA CUNHA E MELO DE ALMEIDA REGO (PROFESSORA E PESQUISADORA) - Muito boa-tarde a todos! Gostaria inicialmente de parabenizar o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli pela organização da audiência e agradecer também a oportunidade de estar aqui e participar deste debate. É uma grande honra estar aqui e é um efetivo privilégio de poder discutir em concreto este tema, que eu tenho dedicado a minha vida acadêmica para estudar.

Cumprindo o combinado com a organização da audiência, eu falarei sobre o Direito americano para apresentar uma perspectiva diferente, um ponto de comparação com tudo que já foi dito aqui pelos demais Expositores.

Antes de entrar na experiência americana, no entanto, vou contextualizar, um pouco, o debate - a exposição que eu vou fazer no debate geral do direito ao esquecimento - para facilitar a compreensão geral e também para evitar quaisquer confusões.

Então, existem duas possíveis abordagens para o direito ao esquecimento, que já foi dito aqui anteriormente, uma perspectiva material e uma procedimental.

Na perspectiva material, discute-se se as pessoas têm o direito de restringir a divulgação de determinados fatos públicos em determinadas circunstâncias. Já a dimensão procedimental coloca em foco contra quem as pessoas poderiam pleitear o exercício desse direito.

Na dimensão procedimental, o foco principal é saber se seria legítimo pedir a remoção de conteúdo contra intermediários, e não contra o efetivo responsável pela publicação do conteúdo. Na dimensão procedimental, o direito ao esquecimento apresenta uma dificuldade muito clara de devido processo legal, porque limita as formas de acesso a uma informação e, portanto, restringe a liberdade de expressão daqueles que publicam a notícia. Mas responsáveis pela publicação, que podem ser jornais, emissora de TV, *blogs*, enfim etc., muitas vezes sequer participam do processo.

Então, há uma restrição da liberdade de expressão, mas não há participação daquelas cujas liberdades estão sendo restringida. E isso fere de morte o devido processo legal.

Além disso, quando o postulante ao direito de esquecimento aciona o buscador, ao invés do responsável pelo conteúdo, altera-se o cerne da discussão. Então, ao invés de se estabelecer uma discussão sobre direitos fundamentais, ao invés de ficar claro esse conflito de direitos fundamentais, a questão se coloca como um conflito de interesses comerciais do buscador, o

intermediário, e os interesses da personalidade do autor da demanda. E isso mitiga o ônus argumentativo da restrição.

A discussão procedimental foi objeto de diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça, mas, para a discussão do recurso extraordinário posto aqui, em discussão, nesta audiência pública, a destinação material é mais relevante e é a ela que eu passo a discorrer, com a perspectiva do Direito americano.

Não existe na jurisprudência da Suprema Corte um precedente específico sobre direito de esquecimento e é difícil que venha ter, porque os precedentes que impulsionaram o desenvolvimento da doutrina da liberdade de expressão, nos Estados Unidos, são incompatíveis com o instituto do direito ao esquecimento, a pretensão do direito ao esquecimento. Em síntese, eu pretendo demonstrar três pontos.

Um, que a consagração do direito ao esquecimento representaria a restrição sobre o conteúdo do discurso, atraindo maior rigor na aferição de sua constitucionalidade.

Dois, o direito ao esquecimento não seria compatível com a jurisprudência desenvolvida em matéria de difamação e defesa da privacidade, ou seja, defesa da honra e defesa da privacidade.

E, por fim, três, o direito ao esquecimento dificilmente seria visto como meio adequado e menos restritivo para proteger os interesses daqueles que requerem sua aplicação.

Pois bem, em primeiro lugar, a doutrina da liberdade de expressão nos Estados Unidos tem, em sua essência, uma ideia central, a de que a constitucionalidade das restrições sobre o conteúdo das manifestações, dos discursos, em geral, é avaliado com o máximo rigor, *strict scrutiny,* trata-se de exigência de neutralidade, que tem fundamento no princípio anticensura da igualdade. Isso quer dizer que o Estado, e aqui inclui-se o Poder Judiciário, não pode discriminar discursos em razão do ponto de vista daquele que participa do discurso público, nem do tópico abordado pelos discursos. Isso, enfim, a ideia geral por trás dessa regra de não discriminação foi bem sintetizada pelo *Justice* Powell, em Gertz *vs* Welch, quando disse que por mais perniciosa que uma opinião possa parecer, nós dependemos, para sua correção, não da consciência de juízes e jurados, mas da competição de outras ideias. É a ideia de que a liberdade para publicar significa a liberdade para todos, e não para alguns. Por outro lado, a constitucionalidade das regulações de tempo, modo e lugar do discurso é analisada com um rigor bastante inferior, foi definido em Estados Unidos *versus* O'brian. Um exemplo, apenas para ilustrar, se seria possível, seria inválido, seria inconstitucional, na jurisprudência americana, vedar discursos políticos em um

parque público, mas seria perfeitamente válido estabelecer uma limitação de horário ou de decibéis, porque essa limitação seria aplicável a qualquer tipo de discurso, e não apenas sobre um tópico específico. Portanto, seria neutro em relação ao conteúdo, e a regulação seria válida.

Portanto, a primeira conclusão é que, na jurisprudência americana, na doutrina americana de liberdade de expressão, protegem-se, de forma muito mais intensa, as regulações sobre o conteúdo. E, no caso do direito ao esquecimento, a discussão seria efetivamente sobre o conteúdo. Seria uma regulação, portanto, que deveria ultrapassar o maior rigor constitucional para a sua validade. A ideia por trás dessa exigência foi retomada pelo *Justice* Keneddy, no mais recente United States *versus* Alvarez, em que disse que o remédio para o discurso que é falso é o discurso que é verdadeiro. É esse o curso ordinário em uma sociedade livre. A resposta para o insensato é o racional; para o desinformado, o esclarecido; para a mentira descarada, a simples verdade. A Primeira Emenda, em si, garante o direito de responder aos discursos que não gostamos, e por uma boa razão, a liberdade de expressão e de pensamento flui não da benevolência do Estado, mas do direito inalienável da pessoa. E a suspensão do discurso pelo Governo pode fazer a exposição da falsidade mais difícil, nunca mais fácil. A sociedade tem o direito e o dever cívico de engajar em um discurso e racional, aberto e dinâmico. Esses fins não são bem servidos quando o Governo procura

orquestrar a discussão pública por meio de mandados baseados no conteúdo. Então, a primeira conclusão é que no caso do direito ao esquecimento a restrição que se pretende é baseada no conteúdo e, portanto, deveria respeitar o *strict scrutiny*.

Em segundo lugar, como suscitado nos autos do caso sobre a apreciação desta Corte, o direito ao esquecimento é caracterizado pela tentativa de limitar a circulação de fatos verdadeiros em domínio público. Nessa formulação, no entanto, o direito ao esquecimento não se enquadra em nenhuma categoria pré-definida a discurso restringível à luz da Constituição americana e é abertamente incompatível com a jurisprudência sobre difamação e direito à privacidade. Nesse ponto, é importante dar um passo atrás para contextualizar essa observação. Um dos grandes pilares do sistema de liberdade de pensamento dos Estados Unidos é a definição de um domínio de proteção de liberdade de expressão, que é definido por exclusão. A definição do domínio de proteção, portanto, consiste em separar os casos em que, pela experiência, se verificou que as restrições à liberdade de expressão são legítimas em homenagem a outros interesses e identificar os requisitos mínimos para restrição seja válida a luz da Constituição. Ou seja, como vimos para que supere o *strict scrutiny*.

O que se pretende demonstrar aqui é que as limitações constitucionais impostas nessas duas categorias de discurso restringível

inviabilizam a consagração ao direito ao esquecimento. Para configuração da difamação, a jurisprudência exige que haja divulgação de um falso que ofenda a reputação de alguém, ou seja, não se aplica: 1) quando se tratar de manifestação de opinião - deve ser um fato; 2) quando a informação divulgada é verdadeira - não deve ser falsa; 3) em razão de qualquer desconforto, mas de uma mácula à reputação de alguém. Essas limitações foram desenvolvidas na sequência nos casos muito conhecidos, do New York Time *vs* Sullivan, Curtis Publishing *versus* Butts, Gertz *vs* Welch. Como se vê, na medida em que o direito ao esquecimento admita a restrição de fatos verdadeiros, não é compatível com a jurisprudência sobre a proteção da honra e difamação nos Estados Unidos.

Na categoria do discurso invasivo da privacidade, adotada apenas por alguns dos Estados americanos, não todos, admite-se a restrição do discurso verdadeiro, mas apenas sob severas limitações. Trata-se de divulgação pública de fatos privados; é uma das categorias de violação à privacidade. Para validade das restrições nesses casos, foram estabelecidos quatro requisitos constitucionais cumulativos: deve haver a publicação de um fato privado cuja divulgação seja altamente ofensiva para uma pessoa de sensibilidade média, e não haja interesse público na divulgação. Nessa matéria, o ponto decisivo que impõe obstáculo ao direito ao esquecimento são as exigências de que o fato seja efetivamente privado e que não haja interesse público na sua divulgação. Uma

linha interessantíssima de jurisprudência demonstra o fato, que é o que eu passo a expor.

Em Smith *vs.* Daily Mail, a Suprema Corte dos Estados Unidos analisou a constitucionalidade de lei estadual que criminalizou a divulgação, por jornais, de nomes de menores infratores sem autorização judicial formal. A Corte entendeu que, ainda que se entenda que os interesses nessa proibição sejam relevantes e tão relevantes quanto à liberdade de expressão, a medida não passaria pelo teste de adequação e necessidade, na medida em que a informação publicamente disponível e de interesse público se espalha por diversos meios. No caso específico, quando o réu, que era um jornal, divulgou o nome do menor infrator, três emissoras de rádio já haviam também divulgado o nome. Em resumo, entendeu-se que, se um jornal obtém legalmente uma informação sobre questão de significância pública, então, os agentes estatais não podem constitucionalmente punir a publicação de informações, ausente uma necessidade de proteger o interesse público da mais alta ordem.

Aqui, portanto, a lógica é que o fato divulgado não seria propriamente privado, afastando a pretensão da privacidade.

Na linha de casos de Cox Broadcast Corp *v.* Cohn, Florida Star *v.* BJF e Oklahoma Publishing *v.* District Court, da década de 70 e 80, todos eles, a Suprema Corte afirmou que, uma vez que a informação verdadeira esteja revelada

publicamente ou em domínio público, a Corte não poderia constitucionalmente restringir sua disseminação, mesmo que a informação seja altamente ofensiva para uma pessoa de sensibilidade média. Em resumo, em matéria de informações sensíveis, a solução adequada é intervir para evitar o acesso a esses fatos, e não punir a divulgação uma vez que esteja disponível para o público, tanto por uma questão de proteção da liberdade de expressão quanto por uma avaliação pragmática da utilidade dessa segunda forma de restrição.

Dessa forma, é simples perceber a incompatibilidade dessa linha de *leading cases* com o direito ao esquecimento. Na medida em que informações estejam disponíveis ao público, sua restrição tampouco se justifica com fundamento na privacidade, portanto, ou seja, nem com fundamento na honra, nem com fundamento na privacidade. Em oposição à garantia contra a divulgação pública de fatos públicos, o direito ao esquecimento representaria a proibição da divulgação pública de fatos públicos.

Pois bem, a esta altura, já foi dito que o direito ao esquecimento como restrição sobre o conteúdo do discurso precisaria superar requisitos de *Standard Strict Scrutiny* e que o direito ao esquecimento é incompatível com a jurisprudência americana sobre o tema.

Antes de encerrar, em terceiro lugar, vale questionar se, por qualquer outro fundamento, o direito ao esquecimento superaria o *Standard Strict*

Scrutiny, ou seja, demonstrar que está em jogo o interesse jurídico da mais alta ordem e que há uma correlação perfeita entre meios e fins.

Nesse ponto, pela limitação de tempo, vou ficar em uma única circunstância, também extraída da jurisprudência americana, que levaria à restrição, enfim, à rejeição do direito ao esquecimento, que é a inadequação da medida.

Um caso famoso de segurança nacional nos Estados Unidos ajuda a ilustrar o ponto. Trata-se do caso WikiLeaks, que divulgou segredos militares estratégicos do Governo americano, colocando em risco operações militares. Nesse caso, Julian Assange foi responsável pela obtenção ilegal, foi processado criminalmente, mas o Governo americano não tentou sequer obter uma ordem de exclusão de conteúdo. O motivo pode ser remontado a um caso anterior, que também envolveu o WikiLeaks.

Nesse caso, o WikiLeaks divulgou informações sigilosas sobre o Banco Julius Baer, acusando seus dirigentes de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. O Banco conseguiu uma liminar com um juiz federal na Califórnia para retirar totalmente o *site* WikiLeaks do ar. O resultado foi a multiplicação desse conteúdo por diversos outros *sites* em todo o planeta - o efeito *Streisand*, já mencionado pelo Professor Carlos Afonso. Depois que se verificou a absoluta ineficácia da ordem judicial, ela foi revogada. O juiz entendeu que o deferimento de ordem de remoção

de conteúdo teve o exato efeito oposto ao pretendido e que a "imprensa" gerada pela concessão dessa medida judicial aumentou a atenção do público ao fato de que a informação estava facilmente disponível *online.* Assim, concluiu que o autor da demanda não demonstrou adequadamente que qualquer medida restritiva nesse caso serviria aos seus propósitos pretendidos, uma vez que - esta é uma citação direta - "o gato está fora do saco".

A mesma constatação da inviabilidade de se deter a dispersão de informações foi verificada no caso Daily Mail, já mencionado anteriormente, quando, em 1979, um jornal foi processado pela divulgação do nome de um suspeito juvenil, mas a mesma informação já havia sido divulgada por diversos outros meios - e isso em 1979, sem a ajuda da internet. Como se vê, a jurisprudência americana reconhece a inocuidade da tentativa de deter o avanço das informações públicas e de interesse público, mesmo em casos em que há a defesa da privacidade quando a obtenção de dados é ilícita ou mesmo quando se trata de matéria de segurança nacional.

Tudo que foi dito até aqui pode ser resumido em uma proposição simples: as informações públicas não são restringíveis nem do ponto de vista jurídico constitucional nem do ponto de vista fático.

Se me permitem uma última colocação. Os Estados Unidos desenvolveram uma doutrina à liberdade de expressão nesse sentido, porque

acreditam que apostar em liberdade de expressão e em liberdade em geral é apostar no primado da razão, da participação e da busca pelo consenso. E que não apostar na liberdade de expressão é preferir uma ordem pública baseada na força e na autoridade.

E se eu puder concluir com uma última passagem do magnífico voto do *Justice* Brandeis, Whitney *v*. California: "O medo de sérios danos não pode, por si só, justificar a supressão da liberdade de expressão ou de assembleia. Os homens temeram bruxas e queimaram mulheres. É a função do discurso libertar o homem das amarras e dos medos irracionais".

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço à professora e pesquisadora Drª Mariana Cunha e Melo de Almeida Rego. Com isso encerramos a participação dos expositores e nos encaminhamos para o final da audiência pública. Passo a palavra, então, ao Subprocurador-Geral da República Dr. Odim Brandão.

O SENHOR ODIM BRANDÃO (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Eminente Presidente, eminente Professores, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, gostaria, verdadeiramente, de agradecer a gentileza do convite para participar desta Audiência Pública, primeiro, em nome da Instituição que represento, que assim se vê dignificada pelo Supremo Tribunal

Federal; segundo, por mim mesmo. Acho que uma das vantagens do meu emprego é ter a oportunidade de ser pago para ter excelentes aulas como essas. Poucos, acho, que têm essa vantagem.

O segundo registro que gostaria de fazer sobre os debates do dia todo é que a tarefa que alguém terá, o Tribunal terá e, de alguma maneira, talvez, a Procuradoria-Geral da República tenha, mais uma vez, de revisar o caso, foi muito facilitada pelo levantamento escrupuloso e extenso de quase todos os tópicos jurídicos relativos ao caso, que se poderia imaginar e, muitas vezes, expostos sob ângulos diferentes o mesmo aspecto. Isso, realmente, quem tem um catálogo tão extenso de tópicos jurídicos tem condições muito melhor de examinar.

Saio daqui com o meu repertório de teses jurídicas sobre direito ao esquecimento grandemente enriquecido. E acho que assim também a sociedade brasileira.

Se pudesse avançar alguma coisa, em relação ao que se poderia imaginar como sendo uma solução adequada para causa, eu faria três apanhados: ela não pode, sobretudo que se trata hoje de um processo de repercussão geral, assim como hoje se trata de súmulas vinculatórias, não se pode perder de vista o enfoque metodológico, bastante estrito, na função desse pronunciamento judicial que terá na ordem jurídica brasileira.

Saindo de Kelsen, passando por Fickenscher, chegando, hoje, ao Professor Lepsius. O Professor Lepsius chama atenção para um caso que muito julgados do Tribunal Constitucional alemão - e isso se repete aqui, ao meu ver, de maneira bastante clara - situam-se, em alguma medida, entre a constituição e a sentença. Então é preciso delimitar, com absoluta precisão, o que está se discutindo, para se evitar depois extrapolações absolutamente impróprias daquilo que se decidiu.

Então, acho que hoje, a partir de um catálogo de tópicos tão grande, como esses minuciosamente explicados e desenvolvidos, a dificuldade é: quais são de verdade os fatos aqui postos em discussão? Decidir quais são os aspectos dele relevantes; e, depois, quase que como selecionar entre os tópicos expostos aqueles que, talvez, mereçam precedência e acrescentar algo mais.

Não gostaria de cansar a plateia, mas falou-se muito em dignidade humana neste caso, tanto de manhã e de tarde, mas vi pouco a discussão da ponderabilidade. Está em discussão aqui a dignidade humana? Se estiver, nós temos um problema seriíssimo que eu não vi sendo discutido. Se ela estiver, ela pode ser sujeita a ponderações, ou ela é o objeto de uma proteção absoluta que não admite ponderações. Isso não vi discutido!

Um terceiro ponto - e esse perpassou o lado de ambos os antagonismos -, ora se fala em precedência do direito ao discurso, agora o fecho da

Colega foi bastante enfático nisso, de nítido perfil anglo-americano. E, de outro lado, falou-se também na precedência absoluta dos direitos de personalidade. Como armazenar isso, ou como colocar qualquer dos direitos de precedência de um ou outro campo num texto constitucional, em que ambas as normas têm o mesmo nível hierárquico? São ambos direitos fundamentais, ao menos do ponto de vista formal, eu tenho muita dificuldade com uma teoria, talvez possa-se desenvolver a partir de critérios materiais, ou, o que é pior, talvez a partir de uma pré-compreensão não jurídica, simplesmente informando a decisão jurídica, que depois, simplesmente, ratifica aquilo que, de antemão, já decidi eu como sendo prevalente.

Então, essa discussão de precedência unilateral de qualquer dos valores, a meu ver, enfrenta, de saída, uma objeção gravíssima, que é a da paridade normativa entre ambos. Quem negar a paridade normativa terá que ir para uma disparidade material. E, aí, eu queria ver alguém conseguir me apresentar um padrão de disparidade material jurídico, e não pré-jurídico.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Se me permite, o Professor e sempre Ministro Eros Grau, quando em seus votos ou em alguns debates em julgamentos, se deparava com a ideia de conflito de princípios constitucionais, costumava até brincar: como que dois artigos vão se levantar,

brigar num ringue até que um nocauteie o outro se ambos são da mesma estatura? Ele dizia que essa ideologia, essa teoria, na visão dele, não era possível.

O SENHOR ODIM BRANDÃO (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Simplesmente para encerrar, uma coisa que me ocorreu, se me permite, é que sempre se disse que o discurso é sempre, invariavelmente, a melhor solução. Em princípio, eu estaria de acordo com a ampla liberdade de discurso, mas é preciso lembrar a quem invoca isso: regimes totalitários nasceram com discurso.

Então, a liberdade tem um problema que é um paradoxo dela: a liberdade não é um mecanismo que anda com suas próprias pernas. Em alguma medida, os limites extremos da liberdade têm que ser garantidos, porque são eles, afinal de contas, que permanecerão mantendo a liberdade de pé.

Adolf Hitler não começou sua carreira, por exemplo, simplesmente tomando o poder; ele começou com um discurso.

Esse foi um apanhado rápido daquilo que me ocorreu como problemática, mas sobretudo gostaria de saudar a iniciativa de Vossa Excelência na convocação desta Audiência Pública e agradecer as ponderações, o desenvolvimento desse abundante e muito valioso catálogo de tópicos jurídicos.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Agradeço a manifestação do Dr. Odim Brandão. E, mais uma vez, agradeço a presença de

todos os expositores que falaram na parte da manhã e, agora, as Senhoras e os Senhores que falaram na parte da tarde; agradeço a presença das Senhoras e dos Senhores Advogados; aos representantes da imprensa e, em especial, à Assessoria da Turma, na pessoa da Dra. Ravena; do Cerimonial, na organização, na pessoa da Dra. Célia; agradeço a todos os servidores que fizeram possível esta Audiência Pública; e à TV Justiça, que transmitiu, ao longo de todo o dia, os debates aqui realizados. Agradeço, por fim, a honrosa presença, na abertura, da Senhora Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministra **Cármen Lúcia**.

Declaro, então, encerrada esta sessão de audiência pública.

Muito obrigado a todos.

****